

스터디파이터 2차 보상법규 개별법 핵심요약서

2026년 개정판

감정평가사
2차 합격을
위한
보상법규
개별법
핵심요약서

제1판

01

PART

공용수용

제1장 공용수용

제1절	공용수용	1
제2절	공공적 사용수용 (사적 공용수용, 사용수용)	3

제2장 공익사업, 당사자, 목적물

제1절	수용적격사업으로서 공익사업	5
제2절	당사자	6
제3절	목적물	8

제3장 공익사업의 준비

제1절	의의와 법적 성격	14
제2절	타인 점유토지에의 출입	14
제3절	장해물의 제거 등	16
제4절	권리구제	17

제4장 사업인정 전 협의취득

제1절	토지조서·물건조서의 작성(제14조)	19
제2절	보상계획의 공고 및 열람(제15조)	20
제3절	보상액의 산정(제68조)	21
제4절	사업인정 전 협의	21

제5장 사업인정

제1절	사업인정	23
제2절	사업인정 의제제도	27
제3절	사업인정의 실효와 사업의 완료	28

제6장 사업인정 후 협의 및 협의성립확인

제1절	토지조서 및 물건조서의 작성(제27조)	31
제2절	사업인정 후 협의(제26조)	33
제3절	협의성립확인	37

제7장 재결

제1절	재결신청청구권	39
제2절	재결신청	41
제3절	수용재결	42
제4절	재결의 실효	43
제5절	화해	45

제8장 약식절차

47

제9장 공용수용의 효과

제1절	공용수용의 일반적 효과	51
제2절	보상금 지급 또는 공탁	52
제3절	수용목적물의 인도·이전 의무 및 그 의무이행 확보수단	55
제4절	위험부담의 이전	58
제5절	담보물권자의 물상대위	59
제6절	환매권	60

제10장 권리구제(재결의 불복)

제1절	개설	69
제2절	이의신청(토지보상법 제83조)	70
제3절	행정소송(토지보상법 제85조)	71

제11장 토지수용위원회와 보상협의회

제1절	토지수용위원회	75
제2절	보상협의회	77

02

PART

손실보상**제1장 손실보상 일반론**

제1절	손실보상 개요	79
제2절	헌법 제23조 제3항의 해석	81
제3절	손실보상의 요건	84
제4절	손실보상의 원칙	87
제5절	채권보상	88
제6절	대토보상	89

제2장 토지보상법상 손실보상 기준

제1절	정당보상	91
제2절	토지의 보상평가기준	92
제3절	공시지가기준 보상	93
제4절	그 밖의 요인 보정	95
제5절	개발이익배제	96

제3장 손실보상의 내용

제1절	재산권 보상	99
제2절	생활보상	100

제4장 손실보상액의 산정과 평가각론

제1절	공법상 제한받는 토지 평가	101
제2절	무허가건물 등의 부지와 불법형질변경된 토지의 평가	103
제3절	미지급용지의 평가	105
제4절	도로부지의 평가	107
제5절	잔여지에 대한 보상평가	109
제6절	건축물 등 물건에 대한 보상평가	113
제7절	영업손실보상	115
제8절	이주대책	118
제9절	간접손실보상	123
제10절	주거이전비	128
제11절	건축물의 잔여부분에 대한 보상평가	131
제12절	개간비의 보상과 평가	132
제13절	토지에 대한 소유권 외의 권리에 대한 보상	133
제14절	사용하는 토지에 대한 보상평가	133
제15절	농업손실보상	134

03

PART

기타 개별법

제1장 부동산 가격공시에 관한 법률

제1절	표준지공시지가	137
제2절	개별공시지가	141
제3절	토지가격비준표	147
제4절	부동산가격공시위원회	149
제5절	타인토지출입	149
제6절	주택가격공시제도(생략)	150

제2장 감정평가법

제1절	감정평가사의 법적지위	151
제2절	감정평가사의 자격등록 및 갱신등록	155
제3절	감정평가법인등	157
제4절	징계 및 징계위원회	160
제5절	감정평가	165
제6절	기타(과징금, 과태료, 한국감정평가협회)	167

제3장 도정법

제1절	정비사업의 기초	170
제2절	조합설립인가	170
제3절	사업시행계획인가	172
제4절	관리처분계획인가	173
제5절	매도청구 및 수용재결	175
제6절	분양신청 통지 및 이전고시 관련 판례	177

PART 01

공용수용

Chapter 01 공용수용

Chapter 02 공익사업, 당사자, 목적물

Chapter 03 공익사업의 준비

Chapter 04 사업인정 전 협의취득

Chapter 05 사업인정

Chapter 06 사업인정 후 협의 및 협의성립확인

Chapter 07 재결

Chapter 08 약식절차

Chapter 09 공용수용의 효과

Chapter 10 권리구제(재결의 불복)

Chapter 11 토지수용위원회와 보상협의회

제1절

공용수용

01 공용수용과 공용수용제도

공용수용이란 특정한 공익사업을 위해 사업주체가 국가권력으로 타인의 재산권을 강제적으로 취득하는 것

02 근거

1) 이론적 근거

사유재산불가침 원칙에 대한 특례, 공공복리를 위한 국가권력의 발동

2) 헌법적 근거

공공필요에 의한 재산권의 수용·사용 또는 제한 및 그에 대한 보상은 법률로써 하되, 정당한 보상을 지급하여야 한다(헌법 제23조 제3항).

3) 실정법적 근거

- ① 공용수용의 일반법으로서 토지보상법
- ② 그 외 개별법률 규정

03 특징

- 1) 목적의 특징 : 공익사업을 원활하게 수행하여 공익 증진을 도모
- 2) 수단의 특징 : 강제적 취득
- 3) 목적물의 특징 : 토지소유권 및 그외 물건
- 4) 효과의 특징 : 원시취득
- 5) 손실보상의 전제 : 정당한 보상

04 요건

1) 공공필요가 있을 것

공공필요란 대표적 불확정개념으로, 공익을 위해 재산권의 수용·사용·제한이 불가피한 경우를 말한다.
공공필요의 판단은 비례의 원칙에 따라 공익사업으로 달성하려는 공익과 이로 인하여 침해되는 사익을 이익형량하여 판단한다.

2) 재산권에 대한 공권적 침해일 것

- ① 재산권이란 법에 의해 보호되는 모든 재산적 가치 있는 권리를 말한다.
- ② 이러한 재산권에 대해 공권력에 의한 침해, 즉 재산권의 수용*사용*제한이 있어야 한다.

3) 재산권 침해의 법적 근거가 있을 것

침해가 법률에 근거한 것이어야 하며 법률에 위반하지 말아야 한다.
법률의 근거가 없거나 법률에 위반하여 행하여지는 경우에는 국가배상의 원인이 된다.

4) 특별한 희생이 발생할 것

재산권의 사회적 제약을 넘어서는 특별한 희생이 발생해야 한다. 사회적 제약과 특별한 희생을 구별하는
기준으로는 형식적 기준설과 실질적 기준설이 있으며, 구체적인 사정을 종합적으로 고려하여 판단해야 한다.

5) 보상규정이 존재할 것

보상규정이 존재해야 손실보상이 가능하다. 보상규정이 존재하지 않는 경우의 손실보상에 대해서는 견해가
대립한다.

05 공용수용의 유형

- ① 본래수용
- ② 확장수용 : 완전수용(제72조), 잔여지 등의 매수 및 수용청구(제74조), 이전수용(제75조 제1항)

06 공용수용과 공공필요

1) 공공필요의 의미

대표적 불확정개념, 공익 목적을 달성하기 위해 재산권의 수용·사용·제한이 불가피한 경우, 가변적

2) 수용과 공공필요의 관계

(1) 헌법 제23조 제3항의 공공필요

공공필요는 공용침해의 실질적 허용요건이자 본질적 제약요소

(2) 토지보상법 제4조 및 별표, 제4조의2 수용적격사업

(3) 공공필요의 판단기준

공용침해를 통하여 얻어지는 공익과 재산권자의 재산권 보유이익 간에 이익형량을 통해서 그 여부가 결정

(4) 수용에 있어 공공필요의 확대 경향

최근 민간의 이윤·동기까지 포함하는 시설의 설치 등을 목적으로 하는 사업에 대하여도 점차 공공필요를 인정

07 최근 공용수용제도의 동향

1) 공익사업의 확대와 공익성 검증 강화

- ① 공익사업의 확대 : 개별법률에서도 수용권 부여
- ② 공익성 검증 강화 : 중앙토지수용위원회의 심의제도(제4조의3), 사업인정시 중앙토지수용위원회의 협의(제21조)

2) 공적 수용수용의 확대

공공적 수용수용은 공익상 필요, 공익사업의 증대, 민간 활력의 도입, 공행정의 민간화 등에 의해 그 필요성이 인정

3) 보상금에서 개발이익의 배제

개발이익은 불로소득으로 환수필요

4) 정당보상과 생활보상의 확대

(1) 정당보상의 확대

부대적 손실보상과 생활보상 확대

(2) 생활보상의 확대

수용이 없었던 것과 마찬가지로의 생활상태를 회복시키기 위해 생활보상 확대(이주대책)

제2절

공공적 수용수용 (사적공용수용, 수용수용)

CASE

1. 사기업인 A회사의 비료공장건설사업에 대한 사업인정의 적법 여부 및 위법하다고 인정되는 경우의 권익구제방법을 논술하시오.(10점)(10회 1번)
2. 사적(私的) 공용수용의 의의 및 요건에 대하여 설명하시오.(20점)(19회 3번)

01 제도의 배경

민간 활력의 도입필요, 사적주체에게도 수용권 부여

02 의의·취지 및 요건

- ① 공공필요 ② 법률의 근거 ③ 정당한 보상 + ④ 사적주체에게 수용권 부여

03 인정여부

- ① <대법원>은 어떤 사업이 공익사업인가의 여부는 그 **사업자체의 성질**에 의하여 정할 것이고, 사업주체의 여하에 의하여 정할 것이 아니라고 판시
- ② <헌법재판소>도 관공진흥법 위헌소원사건에서 재산권의 수용의 주체를 한정하지 않고 있는바 합헌 판결

04 사용수용과 공공필요

1) 대상사업과 공공필요

- ① 토지보상법 제4조 및 별표, 제4조의2는 공익사업을 규정하고 있으며, 개별법률은 사업인정 의제조항을 두고 있다.
- ② 수용권이 부여되려면 공공필요를 근거로 사업인정을 받아야 한다.

2) 공공필요의 판단기준인 비례의 원칙

공공필요는 비례의 원칙에 따라 이익형량

05 계속적 공익실현의 보장책

1) 보장책 마련의 필요성

사적주체는 이윤추구의 목적도 함께 가지고 있음

2) 보장의 수단

(1) 토지보상법상 환매권 및 사업인정의 실효

- ① 환매권(제91조)
- ② 사업인정의 실효(제23조), 사업의 폐지 및 변경(제24조)제도

(2) 입법적 통제 및 사법적 통제

- ① 입법적 통제
각 개별법에서 사업시행자에 대한 감독명령과 처분, 위반시 벌칙 등을 규정
- ② 사법적 통제
행정쟁송의 제기, 위헌법률심판, 헌법소원 등의 방법으로 사법적 통제가 가능

3) 문제점

실효성 확보수단으로는 미흡, 보완 필요

제1절

수용적격사업으로서 공익사업

01 의미

수용적격사업이란 수용주체가 수용할 수 있는 적격을 갖는 공익사업을 말한다.

02 토지보상법 제4조, 별표, 제4조의2의 설정방법

제한열거주의

03 내용

(생략)

04 공익사업 신설 등에 대한 개선요구 등

1) 토지보상법 제4조의2

수용(또는 사용)할 수 있는 사업은 제4조 또는 별표에 규정된 법률에 따르지 않고는 정할 수 없고(제1항),
별표는 토지보상법 외의 다른 법률로 개정할 수 없다(제2항).

2) 토지보상법 제4조의3

- ① 중앙토지수용위원회는 사업인정이 의제되는 공익사업의 신설, 변경 및 폐지 등에 관하여 개선요구 등을 할 수 있고, 중앙토지수용위원회의 개선요구 등을 받은 관계 행정기관은 정당한 사유가 없으면 이를 반영하여야 한다.
- ② 또한, 중앙토지수용위원회는 개선요구 등을 위하여 관계 기관 소속 직원 또는 관계 전문가 등에게 의견진술이나 자료제출을 요구할 수 있다.

01 의미

토지수용의 당사자는 수용권의 주체인 수용자와 수용목적물인 재산권의 주체인 피수용자가 된다.

02 사업시행자와 수용권의 주체

1) 사업시행자의 의미

사업시행자란 공익사업을 수행하는 자를 말한다(제2조 제3호).

2) 국가 이외의 자가 수용권자인 경우 수용권의 주체 논의

(1) 문제점

국가 이외의 공공단체나 사인(공무수탁사인)이 사업시행자인 경우 수용권의 주체가 누구인지 견해가 대립

(2) 학설

- ① <국가수용권설> 수용권이란 수용의 효과를 야기할 수 있는 능력
- ② <사업시행자수용권설> 수용권이란 수용의 효과를 누리는 능력(다수설)

(3) 판례

대법원은 사업인정을 일정한 절차를 거칠 것을 조건으로 수용권을 설정해 주는 **설권적 형성처분**이라 판시하여 **사업시행자수용권설**의 입장이다.

(4) 검토

수용권은 수용의 효과를 누릴 수 있는 능력, 사업시행자수용권설 타당

03 사업시행자의 법적 지위

1) 권리

- ① 사업준비를 위한 타인 토지에의 출입권(제9조)
- ② 장애물 제거권(제12조)
- ③ 사업인정 신청권(제20조)
- ④ 토지 및 물건에 관한 조사권(제27조)
- ⑤ 재결신청권(제28조)
- ⑥ 협의성립확인 신청권(제29조)
- ⑦ 토지나 물건을 원시취득할 권리(제45조)
- ⑧ 토지나 물건의 인도 또는 이전이 없는 경우 대항신청권(제44조)
- ⑨ 재결에 불복하는 경우 행정쟁송권(제83조 및 제85조)
- ⑩ 의무 불이행 등에 대한 대집행신청권(제89조)

2) 의무

- ① 타인 토지에의 출입 등에 의한 측량·조사, 장애물 제거 등으로 인한 손실보상의무(제9조 제4항, 제12조 제4항)
- ② 협의 불성립시 피수용자의 재결신청청구에 응할 의무(제30조 제2항)
- ③ 피수용자의 고의·과실 없이 수용목적물의 멸실·훼손으로 인한 손실부담의 이전(제46조)
- ④ 재결로 인한 토지 등 취득시 손실보상의무(제61조)

3) 권리·의무의 승계

- ① 사업승계란 사업이 이전되면 사업시행자의 권리·의무는 그 사업을 승계한 자에게 이전되는 것을 말한다(제5조 제1항).
- ② 절차승계란 이 법에 따라 이행한 절차와 그 밖의 행위는 사업시행자·토지소유자 및 관계인의 승계인에게도 효력이 미치게 되는 것을 말한다(제5조 제2항).

04 피수용자

1) 의의

피수용자란 수용의 목적물인 재산권의 주체 및 수용에 의해 영향을 받는 기타 관계 권리자를 말한다.

2) 토지소유자와 관계인

(1) 토지소유자

(2) 관계인

- ① 토지에 관하여 소유권 외의 권리를 가진 자
- ② 그 토지에 있는 물건에 관하여 소유권이나 그 밖의 권리를 가진 자
- ③ 다만, 사업인정의 고시(제22조)가 된 후에 권리를 취득한 자는 기존의 권리를 승계한 자를 제외하고는 관계인에 포함되지 아니한다(제2조 제5호).

3) 피수용자의 법적 지위

(1) 권리

- ① 사업인정시 의견을 제시할 수 있는 권리(제21조)
- ② 재결신청에 따른 열람시 의견을 제시할 수 있는 권리(제31조 제2항)
- ③ 협의 불성립시 재결신청청구권(제30조 제1항)
- ④ 사용하는 토지의 매수청구권(제72조)
- ⑤ 잔여지 등의 매수 및 수용청구권(제74조 제1항)
- ⑥ 비용보상에 대한 협의 불성립시 재결신청권(제80조 제2항)
- ⑦ 환매권(제91조)
- ⑧ 재결에 불복시 행정쟁송권(제83조 제1항, 제85조 제1항)

(2) 의무

- ① 사업시행자의 토지출입에 따른 행위의 인용의무(제11조, 제27조 제1항)
- ② 토지 등의 보전의무(제25조 제1항)
- ③ 토지 또는 물건의 인도와 이전의무(제43조 제1항)

(3) 권리·의무의 승계

절차승계만 인정

제3절

목적물

01 의미

공익사업의 목적물이란 공익사업을 위해 독립하여 취득의 대상으로 다루어질 수 있는 토지, 물건 등에 관한 소유권 및 기타 권리이다.

02 종류

1) 토지보상법 제3조 적용대상

2) 토지소유권과 토지소유권 외의 권리

(1) 토지소유권

(2) 토지에 관한 소유권 외의 권리

3) 토지에 정착한 물건 및 이에 관한 소유권 외의 권리

(1) 토지에 정착한 물건의 소유권

(2) 토지에 정착한 물건의 소유권 외의 권리

4) 광업권·어업권·양식업권 및 물의 사용에 관한 권리

5) 토지에 속한 흙·돌·모래 또는 자갈에 관한 권리

03 목적물의 제한

1) 수용제도 본질상 제한

비대체적인 목적물, 필요한 최소한도

2) 토지세목에 따른 제한

토지세목에 기재되지 아니한 토지 등은 수용의 목적물이 될 수 없다.(잔여지는 예외)

3) 목적물의 성질에 따른 제한

(1) 사업시행자 소유의 토지

(2) 공익사업에 이용되고 있는 토지

① 수용권의 충돌

공익사업에 수용되거나 사용되고 있는 토지 등은 특별히 필요한 경우가 아니면 다른 공익사업을 위하여 수용하거나 사용할 수 없다(제19조 제2항).

② 판단기준

‘특별한 필요’가 인정된다면 수용의 목적물이 될 수 있다.

(3) 외국대사관 등의 부지·건물

(4) 국·공유재산

국·공유재산 중 일반재산은 그 성질상 당연히 수용의 목적물이 될 수 있으나, 행정재산이 수용의 목적물이 될 수 있는가에 대하여는 한마디로 말하기 어렵다.

(5) 공물의 수용가능성 논의

CASE

물음 3) 한편, 丙이 소유하고 있는 토지(이하 ‘이 사건 C토지’라 한다)는 문화재보호법 상 보호구역으로 지정된 토지로서 이 사건 시설 조성사업의 시행을 위한 사업구역 내에 위치하고 있다. 甲은 공물인 이 사건 C토지를 이 사건 시설 조성사업의 시행을 위하여 수용할 수 있는가?(15점) (31회, 1번)

① 문제점

공물의 수용시 별도의 용도폐지가 요구되는가와 관련하여 특별한 필요의 해석이 문제

② 학설

- ① <공용폐지 불요설> 용도폐지 없이 예외적으로 수용을 허용
- ② <공용폐지 필요설> 용도폐지를 선행해야 한다

③ 판례의 태도

대법원은 지방문화재로 지정된 토지가 수용대상이 된다고 판시하였고, 헌법재판소도 특별한 필요가 있는 경우에는 예외적으로 현재 공익사업에 이용되고 있는 토지도 수용의 목적물이 될 수 있다고 판시하였다. 다만, 최근 대법원은 (구)국유림법과 관련해서 (구)국유림법에 따른 절차와 방법을 우선적으로 취하지 아니하고 요존국유림의 소유권을 재결을 통해 취득할 수 없다고 판시하여, 용도폐지가 선행되어야 한다고 보았다.

④ 검토

생각건데, 공물은 현재 공익목적에 제공되고 있지만, 특별한 필요가 있다면 다른 공익사업에 수용될 수 있다고 본다. 특별한 필요는 비례의 원칙에 따라 종래의 공익과 새로운 공익을 비교형량하여 판단해야 한다. 다만 이 경우에도 국유재산법 등 관련 법률의 규정에 따라 공물의 용도폐지가 선행되어야 한다고 본다.

04 목적물의 확장

1) 확장수용의 의미 및 취지, 종류

- ① 확장수용은 특정한 공익사업을 위하여 목적물의 필요한 범위를 넘어서 수용하는 것
- ② 피수용자에 대한 권리구제에 이바지하며, 사업의 원활한 실시를 위해 인정
- ③ 완전수용(제72조), 잔여지수용(제74조), 이전수용(제75조)

2) 확장수용의 법적성질

(1) 문제점

확장수용이 일반적으로 피수용자의 청구에 의해 이뤄진다는 점에서 그 법적성질이 문제

(2) 학설

- ① 사법상 매매설, ② 공법상 특별행위설, ③ 공용수용설

(3) 판례의 태도

대법원은 잔여지수용청구권이 그 요건을 갖춘 때에는 토지수용위원회의 특별한 조치를 기다릴 것 없이 청구에 의하여 수용의 효과가 발생하므로, 이는 형성권적 성질을 가진다고 판시하여 **공용수용설** 입장이라고 할 수 있다.

(4) 검토

확장수용은 공용수용의 효과가 발생하므로, 공용수용설이 타당

3) 완전수용

(1) 의의

사용에 갈음하는 수용'이라고도 한다.

(2) 요건

사업인정고시 후

- ① 토지사용기간이 3년 이상인 경우,
- ② 토지사용으로 인하여 토지형질이 변경되는 경우,
- ③ 사용하려는 토지에 그 토지소유자의 건축물이 있는 경우에 매수청구 또는 수용청구

(3) 완전수용청구권 및 관계인의 권리존속 청구

완전수용청구권은 토지소유자만 갖는다. 이 경우 관계인은 사업시행자나 관할 토지수용위원회에 대하여 그 권리의 존속을 청구할 수 있다(제72조 제2문).

4) 잔여지수용

(1) 의의

잔여지수용이란 동일한 토지소유자에게 속하는 수용 목적물인 일단의 토지 일부가 매수되거나 수용됨으로 인하여 잔여지를 종래 목적에 사용하는 것이 현저히 곤란한 때 토지소유자의 청구에 의해 사업시행자가 해당 토지의 전부를 매수하거나 수용하는 것을 말한다.

(2) 매수·수용의 절차

사업인정 이전 : 매수청구

사업인정 이후 : 매수청구 후 협의가 성립되지 아니하면 수용청구

(3) 매수·수용의 효과

- ① 관계인의 권리존속 청구
- ② 사업인정 및 사업인정고시의 의제

5) 이전수용

(1) 의의

이전수용이란 물건 등의 이전을 강행하는 것이 소유자나 사업시행자에게 과중한 손실을 가져올 우려가 있는 예외적인 경우 수용할 수 있도록 하는 제도이다.

(2) 이전비보상의 원칙과 예외

① 원칙

건축물 등은 이전비로 보상하여야 한다(제75조 제1항 본문).

② 예외

a. 물건가격 보상

- ① 건축물 등을 이전하기 어렵거나, 그 이전으로 인하여 건축물 등을 종래의 목적으로 사용할 수 없게 된 경우,
- ② 건축물 등의 이전비가 그 물건의 가격을 넘는 경우, ③ 사업시행자가 공익사업에 직접 사용할 목적으로 취득하는 경우

b. “이전 곤란”의 의미

물리적 곤란 뿐만 아니라 사회적·경제적 곤란도 포함

(3) 절차 및 효과

사업시행자는 관할 토지수용위원회에 그 물건의 수용재결을 신청

6) 확장수용재결에 대한 불복

(1) 문제점

확장수용 거부시 불복방법이 문제

(2) 이의신청

재결서正本 송달일로부터 30일 이내에 이의신청을 할 수 있다.(제83조), 임의주의

(3) 확장수용 거부(수용재결 중 기각재결)에 대한 보상금증감청구소송 가능성

① 문제점

보증소로 다룰 수 있는지 문제

② 학설

- ① <부정설>은 확장수용에 대한 다툼은 보상금액의 문제가 아니라 보상의 범위에 관련된 문제이므로 불가
- ② <긍정설>은 보상금액과 보상범위는 밀접한 관련이 있어 긍정

③ 판례

잔여지 수용청구권은 형성권적 성질을 가지므로, 잔여지 수용청구를 받아들이지 않은 토지수용위원회의 재결에 대하여는 사업시행자를 피고로 하여 토지보상법 제85조 제2항에 규정되어 있는 “보상금의 증감에 관한 소송”을 제기해야 한다고 판시하였다.

④ 검토

보상금증감청구소송의 제도 취지가 분쟁의 일회적 해결, 긍정 타당

(4) 민사소송의 가능성

불가

공익사업 절차 및 관련 규정

구분	절차(토지보상법 조문)	
공익사업 준비절차	타인토지출입(9), 방해물 제거(12) 등	토지보상법 9조~13조
	토지 및 물건조서 작성(14)	
	보상계획공고 및 열람(15)	
사업인정 전 협의절차	협의(16) 계약체결(17)	- 협의는 수용재결 전 반드시 거쳐야 함 - 사업인정 전 협의(임의), 후 협의(필수) - 협의 손실보상금을 위한 감정평가 진행
강제수용 취득절차	사업인정(20), 협의 및 의견청취 등(21)	- 주체 : 국토부장관 - 절차 : 중앙행정기관 장, 시도지사, 중토위(공공성판단)와 협의 이해관계자 의견청취 - 비고: 22조 사업인정은 고시한 날부터 그 효력이 발생/ 25조 사업인정고시가 된 후 누구든지 토지보전의무 발생
	사업인정후 협의(26): 사업인정 전 절차(14~16) 준용	26조 필수조항
	수용재결(34)	- 주체 : 관할 토지수용위원회 - 절차 : 사업시행자의 재결신청(28) (피수용자의 재결신청청구(30) 가능) - 화해(33), 협의성립확인(29) 가능 - 소유권 원시취득(45)과 가격시점(67①) - 수용재결 손실보상금을 위한 감정평가 진행
	이의재결(84)	- 주체 : 중앙토지수용위원회 - 절차 : 수용재결에 이의있는 자의 이의신청(83) 〈특별법상 행정심판〉 - 이의재결 손실보상금을 위한 감정평가 진행
	행정소송(85)	- 취소소송(1항), 무효등확인소송(판례) - 보증소(2항), 보증소 손실보상금을 위한 감정평가 진행

의의와 법적 성격

01 의의

공익사업 준비란 공익사업을 위해 조사·측량 및 장애물의 제거 등을 하는 일련의 준비행위

02 법적 성격

공용사용

제2절

타인토지출입

심화

		9조 사업인정 전 타도출	27조 사업인정 후 타도출
차 이 점	목적	공익사업 준비 & 조서작성	분쟁예방(조서작성, 감정평가), 심리와 재결의 신속
	절차	사업인정 전 (허가 필요)	사업인정 후 (허가 불요)
	출입근거	특시군구장 허가	사업인정 효과
	내용	장해물 제거 및 시굴권 등 동의 얻어 가능	준용규정 없어 장해물 제거 및 시굴권 등 불가능
	권리구제	허가를 대상으로 쟁송 가능 (사업인정에 대한 쟁송불가)	사업인정을 대상으로 쟁송 가능
공 통 점	법적근거	① 토지보상법 근거 ② 10③, 13조 준용(절차상 공통점), 11조(수인의무)	
	법적성격	① 사용제한 중 일시적 사용 ② 행정조사	
	손실보상	§9⑤~⑦준용	
관련문제		직접적인 실효행위 불가	

구분		토지보상법(9)상 타토출	부동산공시법(13)상 타토출
공통점		특허 & 타인토지출입행위의 법적성질(권력적 사실행위·행정조사) & 출입제한 및 증표 휴대	
차 이 점	목적	공익사업 준비 & 조서작성	표준지 가격 조사·평가 & 개별공시지가 산정
	수인의무	수인의무 규정 있음 & 벌칙규정 있음	수인의무 규정 없음 & 벌칙규정 없음
	장해물 제거 및 출입의 통지기간	장해물 제거 규정 있음 & 5일전	장해물 제거 규정 없음 & 3일전
	손실보상	손실보상 규정 있음	손실보상 규정 없음

01 출입의 허가과 통지

1) 의의 및 근거

- ① 사업시행자는 공익사업을 준비하기 위하여 타인이 점유하는 토지에 출입하여 측량하거나 조사할 수 있다 (제9조 제1항).
- ② 특별자치도지사, 시장·군수 또는 구청장의 허가를 받아야 한다.

2) 출입허가의 법적성질 및 권리구제

강학상 특허, 재량행위

02 출입 측량·조사 행위

1) 의의 및 취지, 근거

타인토지에 출입하여 측량·조사하는 행위는 그 지역이 해당 공익사업에 적합한 지역인지 판단하는 행정조사행위이다(제9조).

2) 법적 성질

권력적 사실행위에 해당하고, 처분성이 인정된다.

3) 요건 및 절차

- ① 특별자치도지사, 시장·군수 또는 구청장의 허가를 받아야 한다(제9조 제2항).
- ② 다만, 사업시행자가 국가일 때에는 그 사업을 시행할 관계 중앙행정기관의 장이 특별자치도지사 등에게 통지
- ③ 특별자치도지사 등은 위 허가 또는 통지를 받은 때, 공고·통지
- ④ 출입하려는 날의 5일 전까지 그 일시 및 장소를 특별자치도지사 등에게 통지하여야 하고(제10조 제1항), 통지를 받은 특별자치도지사 등은 이를 공고·통지

4) 효과

① 사업시행자

권리 : 타인토지출입권, 장애물 제거·시굴허가 신청권(제12조 제1항)

의무 : 손실보상 의무, 사용기간 만료시 반환 및 원상회복의무(제48조)

② 피수용자

권리 : 손실보상청구권(제9조 제4항), 행정쟁송권

의무 : 토지점유자의 인용의무(제11조)

5) 실력 행사의 가부

(1) 문제점

상대방이 조사를 거부하는 경우 직접 실력행사를 통해 필요한 출입 측량·조사를 할 수 있는지 문제

(2) 학설

긍정설, 부정설

(3) 검토

국민의 신체나 재산에 대한 실력행사는 명문의 근거가 있어야 하므로 부정설이 타당

6) 위법한 측량·조사와 그에 따른 사업인정의 효력

(1) 문제점

내용상으로는 정확하나 측량·조사가 절차를 위반한 경우, 그 측량·조사에 의해 수립된 정보에 기초하여 내려진 사업인정이 위법한 것으로 되는지 문제

(2) 학설

(3) 판례

판례는 위법한 세무조사에 기초한 부가가치세 부과처분은 위법하다고 하여 적극설을 취하고 있다.
다만, 행정조사 절차하자가 경미한 경우에는 위법사유가 되지 않는 것으로 본다.

(4) 검토

사업인정에 필요한 정보를 수집하기 위해 행해진 측량·조사에 절차상 하자가 있는 경우 당해 행정행위의 절차하자가 있는 것으로 볼 수 있다.

제3절

장해물의 제거 등

01 장해물 제거 등을 위한 허가

1) 의의 및 근거

측량·조사시 장해물 제거 등을 해야 할 부득이한 사유가 있는 경우 소유자 및 점유자의 동의를 얻어야 하고, 동의를 얻지 못한 때에는 허가를 받아 장해물 제거를 할 수 있다(제12조 제1항).

2) 법적성질 및 권리구제

강학상 특허, 재량행위

02 장해물 제거 등 행위

1) 의의 및 취지, 근거

장해물 제거란 측량·조사시 부득이하게 장해물을 제거하고 토지의 시굴·시추를 해야 하는 경우를 말한다(제12조 제1항).

2) 법적 성질

권력적 사실행위

3) 요건 및 절차

- ① 사업시행자는 소유자 및 점유자의 동의를 얻어야 하고, 동의를 받지 못할 경우에는 사업시행자는 허가를 받아 장애물 제거 등을 할 수 있다(제12조 제1항).
- ② 특별자치도지사 등이 허가를 하거나 장애물 제거 등을 하려면 미리 그 소유자 및 점유자의 의견을 들어야 한다(제12조 제2항).
- ③ 장애물 제거 등을 하려는 자는 장애물 제거 등을 하려는 날의 3일 전까지 그 소유자 및 점유자에게 통지하여야 한다(제12조 제3항).

4) 효과

- ① 사업시행자
권리 : 장애물 제거권(제12조 제1항)
의무 : 사용기간 만료시 반환 및 원상회복의무(제48조)
- ② 피수용자
권리 : 손실보상청구권(제12조 제4항), 행정쟁송권
의무 : 토지점유자의 인용의무(제11조 준용)

제4절

권리구제

01 사업시행자의 권리구제

1) 허가신청 거부에 대한 권리구제

허가는 강학상 특허로 처분이므로, 허가거부도 처분 → 항고쟁송 제기가능

2) 허가신청 부작위에 대한 권리구제

의무이행심판·부작위위법확인소송 제기 가능

02 토지소유자의 권리구제

1) 사전적 권리구제

사전통지, 의견청취

2) 사후적 권리구제

(1) 손실보상 (제9조 제4항, 제12조 제4항)

- ① 손실의 보상은 손실이 있음을 안 날부터 1년이 지났거나 손실이 발생한 날부터 3년이 지난 후에는 청구할 수 없다(제9조 제5항).
- ② 손실의 보상은 사업시행자와 손실을 입은 자가 협의하고, 협의불성립시 재결신청

(2) 손실보상의 재결에 대한 불복

- ① 토지보상법 제9조 제7항에 의한 재결은 보상금만에 대한 재결이나, 제34조의 수용재결과 동일한 절차, 심리과정을 거쳐 결정되므로, 양자의 불복수단을 일관성 있게 봄이 타당하다.
- ② 따라서 토지보상법상 이의신청(제83조), 보상금증감청구소송(제85조 제2항)으로 권리구제가 가능하다.

(3) 수용재결절차 없이 사업시행자를 상대로 손실보상청구 가능한지

① 견해 대립

보상재결은 단순한 보상견적액 제시에 불과하므로 민사 또는 당사자소송으로 다뤄야 한다는 견해, 재결절차를 반드시 거쳐야 한다는 견해가 있다.

② 판례

판례는 재결절차를 거친 후 재결불복시 비로소 토지보상법 규정으로 권리구제를 받을 수 있을 뿐, 재결절차를 거치지 않고 곧바로 사업시행자에게 손실보상을 청구할 수 없다고 하였다.

③ 검토

생각건대, 보상재결은 수용재결과 주체, 형식, 절차 등이 동일하므로 양자를 같은 처분으로 보아, 토지보상법상 규정된 절차에 따라 손실보상청구를 해야 한다고 보는 것이 타당하다.
따라서 일반적인 보상과 마찬가지로 토지보상법상 절차에 따라 보상이 이루어지는 것이 타당하다.

(4) 측량·조사 및 장애물 제거에 대한 행정쟁송

권력적 사실행위이므로 협의 소익이 없어 각하될 가능성이 높다.

(5) 기타 (위법한 조사와 사업인정, 손해배상 및 결과제거 청구권 등)

- ① 행정조사의 위법을 이유로 후행처분의 취소를 구할 수 있다.
- ② 국가배상청구, 위법한 상태가 계속되는 경우 결과제거청구권 행사가 가능

제1절

토지조서·물건조서의 작성(제14조)

01 의의 및 취지

- ① 토지조서와 물건조서란 공익사업을 위해 수용 또는 사용할 필요가 있는 토지와 그 토지 위에 있는 물건의 내용을 기재한 사업시행자가 작성하는 문서이다.
- ② 당사자간 분쟁소지 예방, 공익사업의 신속한 진행, 원활한 수용재결 진행 목적

02 협의취득을 위한 조서의 작성

1) 조서의 작성 방법 및 내용

공익사업의 계획이 확정된 때에는 용지도 작성 후 조서작성

2) 서명 및 날인

(1) 서명 또는 날인하는 경우

토지소유자와 관계인의 서명 또는 날인을 받아야 한다.

(2) 서명 또는 날인을 거부하는 경우 등

- (a) 토지소유자 및 관계인이 정당한 사유 없이 서명 또는 날인을 거부하는 경우,
- (b) 토지소유자 및 관계인을 알 수 없거나
- (c) 그 주소·거소를 알 수 없는 등의 사유로 서명 또는 날인을 받을 수 없는 경우에,
조서에 그 사유 기재

01 보상계획의 공고

사업시행자는 조서를 작성하였을 때에는, 보상계획을 일간신문에 공고하고, 토지소유자 및 관계인에게 통지하고, 특별자치도지사, 시장·군수 또는 구청장에게도 통지하여야 한다.

02 보상계획의 열람

사업시행자는 공고나 통지를 하였을 때에는 그 내용을 14일 이상 일반인이 열람할 수 있도록 하여야 한다.

03 보상계획에 대한 이의신청

- ① 이의가 있는 토지소유자 또는 관계인은 열람기간 이내에 사업시행자에게 서면으로 이의를 제기할 수 있다.
(제15조 제3항)
- ② 다만, 사업시행자가 고의 또는 과실로 보상계획을 통지하지 아니한 경우, 협의가 완료되기 전까지 서면으로 이의제기 가능
- ③ 이의제기시 이의를 부기하고 그 이의가 이유 있다고 인정할 때에는 적절한 조치

제3절

보상액의 산정(제68조)

01 감정평가법인등의 선정

사업시행자는 보상액을 산정하려는 경우 감정평가법인등 3인(예외 2인)을 선정하여 토지 등의 평가를 의뢰하여야 한다.

02 재평가의 의뢰(칙 제17조)

1) 당해 감정평가법인등에게 재의뢰(칙 제17조 제1항)

- ① 그 평가가 관계법령에 위반하여 평가되었거나 합리적 근거 없이 비교 대상이 되는 표준지의 공시지가와 현저하게 차이가 나는 등 부당하게 평가되었다고 인정하는 경우
- ② 필요하면 보상전문기관에 검토 의뢰 가능

2) 다른 2인 이상의 감정평가법인등에게 의뢰(칙 제17조 제2항)

1. 사업시행자는 보상평가가 관계 법령에 위반 또는 부당하게 평가되었다고 인정될 때 당해 감정평가법인등에게 평가를 요구할 수 없는 특별한 사유가 있는 경우
2. 대상물건의 평가액 중 최고평가액이 최저평가액의 110퍼센트를 초과하는 경우(대상물건이 지장물인 경우 최고평가액과 최저평가액의 비교는 소유자별로 지장물 전체 평가액의 합계액을 기준으로 한다)
3. 평가를 한 후 1년이 경과할 때까지 보상계약이 체결되지 아니한 경우

제4절

사업인정 전 협의

CASE

1. 공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률상 사업인정 전 협의와 사업인정 후 협의의 차이점에 대하여 설명하시오.(10점)(25회 문4번)
2. 토지보상법상 다음의 법적 성격을 설명하시오.(10점)(36회 문1)
 - ① 사업인정 전과 후의 '보상에 관한 협의'
 - ② 사업인정 후 '협의취득'

01 의의 및 취지

- ① 수용재결신청 전에 사업시행자로 하여금 수용대상 토지에 관하여 권리를 취득하거나 소멸시키기 위하여 토지소유자 및 관계인과 교섭하도록 하는 절차이다.
- ② 최소침해 원칙, 공익사업의 신속·원활한 진행 도모

02 법적성질

1) 학설

(1) 사법상 계약설

(2) 공법상 계약설

강제수용절차 예정, 공공목적 달성을 위해 체결되는 계약이므로, 공법상 계약

2) 판례

협약은 공공기관이 사경제주체로서 행하는 사법상 계약의 실질을 가지는 것으로, 당사자 간의 합의로 같은 법 소정의 손실보상 기준에 의하지 아니한 매매대금을 정할 수 있다고 판시하였다.

3) 검토

사업인정을 받기 전에 행한 협의행위는 행정상 법률관계를 형성한다고 보여지지 않는바, 사법상 계약으로 봄이 타당

03 절차 및 내용

사업시행자는 협의를 하려는 경우에는 보상협의요청서를 토지소유자 및 관계인에게 통지하여야 한다.

04 효과

1) 협의 성립시 효과

- ① 협의성립시 계약체결
- ② 승계취득
- ③ 법률행위로 인한 물권의 득실변경에 해당하므로 소유권이전등기를 마쳐야 소유권을 취득

2) 협의 불성립시 효과(령 제8조 제5항)

- ① 협의경위서를 작성하여 토지소유자 및 관계인의 서명 또는 날인을 받아야 한다.
- ② 서명 또는 날인의 거부나 불능시 그 사유를 기재
- ③ 국토교통부장관에게 사업인정을 신청할 수 있다.

제1절

사업인정

CASE

A대도시의 시장은 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 따른 도시관리계획으로 관할구역 내 ○○동 일대 90,000㎡ 토지에 공영주차장과 자동차정류장을 설치하는 도시계획시설사업결정을 한 후 지방공기업법에 따른 A대도시 X지방공사를 도시계획시설사업의 시행자로 지정하고, X지방공사가 작성한 실시계획에 대해 실시계획인가를 하고 이를 고시하였다. 이에 따라 토지보상법에 의해 사업인정 및 고시가 이루어졌다.

토지보상법상의 사업인정과 사업인정고시의 법적 성질에 관하여 설명하시오.(10점)(34회 문1)

01 의미 및 취지(토지보상법 제20조)

- ① 사업인정이란 공익사업을 토지 등을 수용하거나 사용할 사업으로 결정하는 것을 말한다.(제2조 제7호)
- ② 수용행정의 적정화, 사전적 권리구제

02 법적성질

1) 처분성(행정행위)

사업인정은 사업시행자와 토지소유자 등에게 일정한 구체적 법적효과가 발생하므로 행정행위이자, 항고소송의 대상인 <처분>이다.

2) 형성행위 여부

(1) 학설

① 형성행위설

수용권을 설정하여 주는 형성행위라고 보는 견해

② 확인행위설

토지를 수용할 수 있는 사업인지 확인하는 확인행위로 보는 견해

(2) 판례

사업인정은 그 후 일정한 절차를 거칠 것을 조건으로 하여 일정한 내용의 **수용권을 설정**해 주는 행정처분의 성격을 띠는 것이라고 판시하였다.

(3) 검토

단순한 확인행위가 아니라, 사업의 공익성 여부를 판단하여 수용권을 설정해 주는 것으로 <설권적 형성행위>로 보는 것이 타당(강학상 특허)

3) 재량행위 여부

(1) 학설

설권적 형성행위설은 재량행위, 확인행위설은 기속행위로 본다.

(2) 판례

그 사업이 공용수용을 할 만한 공익성이 있는지의 여부를 모든 사정을 참작하여 구체적으로 판단하여야 하는 것이므로 사업인정의 여부는 행정청의 재량에 속한다고 하였다.

(3) 검토

- ① 1차적으로 법문언에 따를 때, 토지보상법 제20조는 “사업시행자는 ~ 사업인정을 받아야 한다.”라고 되어 있어 판단이 불분명하나,
- ② 토지보상법의 입법 목적, 취지, 행위의 성질, 공익 관련성 등을 종합적으로 판단할 때, <재량행위>로 봄이 타당하다.

4) 제3자효 행정행위

사업인정은 사업시행자에게 수용권을 설정하는 수익적 효과를, 피수용자에게는 재산권을 침해하는 침익적 효과를 발생시키는 바 <제3자효 행정행위>이다.

03 요건

1) 성립요건

(1) 주체

- ① 국토교통부장관
- ② 허가·인가·승인권자 등이 사업인정의 권한을 갖는다.

(2) 내용

- ① 공익사업이 토지보상법 제4조의 각 호 중 하나에 해당하여야 한다.
- ② 공공필요
- ③ 사업시행자에게 해당 공익사업을 수행할 의사와 능력이 있어야 한다.

(3) 절차

a. 사업인정의 신청(령 제10조)

b. 의견청취 등(법 제21조)

- ① 국토교통부장관은 사업인정을 하려면 관계 중앙행정기관의 장 및 시·도지사 및 중앙토지수용위원회와 협의하여야 하며, 미리 사업인정에 이해관계가 있는 자의 의견을 들어야 한다.
- ② 사업인정권자는 중앙토지수용위원회가 사업인정 등에 동의하지 않은 경우에는 이를 보완하여 다시 협의를 요청할 수 있다(칙 제9조의3).

c. 중앙토지수용위원회의 검토

의견수렴절차 이행여부, 허가·인가·승인대상 사업의 공공성, 수용의 필요성, 사업시행자의 재원 및 사업수행능력 여부 등을 검토하여야 한다.

d. 중앙토지수용위원회의 의견 제시

협의를 요청받은 날부터 30일 이내

e. 사업인정의 고시(법 제22조)

국토교통부장관은 사업인정을 하였을 때에는 지체 없이, 토지의 세목을 관보에 고시하여야 한다.

(4) 형식

2) 효력발생요건

(1) 사업인정의 고시

- ① 사업인정고시란 사업인정 효과가 미치는 범위를 누구나 확인할 수 있도록 나타내는 절차이다.
- ② 사업인정은 고시한 날부터 그 효력이 발생한다.(제22조 제3항)
- ③ 사업인정은 통지가 있었다 하더라도 고시가 없으면 효력이 발생되지 아니한다.

(2) 토지세목고시 누락이 사업인정처분의 절차하자인지

- ① 토지세목의 고시는 구체적으로 수용할 수 있는 목적물을 결정하는 행위로서, 이를 통해 사업인정이 현실화 되고 구체화된다.
- ② 토지세목고시를 누락한 것은 절차상 위법으로서 사업인정의 취소사유가 된다.

04 사업인정고시의 효과 [수목관보조]

1) 토지수용권의 발생

2) 수용목적물의 확정

3) 관계인의 범위 제한

4) 토지 등의 보전의무

사업인정고시가 된 후에는 누구든지 고시된 토지에 대하여 사업에 지장을 줄 우려가 있는 형질의 변경이나, 물건을 손괴하거나 수거하는 행위를 하지 못한다.(법 제25조)

5) 토지·물건조사권의 발생

(사업인정 전과 달리) 허가 없이도 해당 토지나 물건에 출입하여 측량하거나 조사할 수 있다.(법 제27조 제1항)

05 권리구제

1) 사업시행자입장에서의 권리구제

(1) 사업인정 신청 후 거부시 권리구제

- ① 행정심판에서는 의무이행심판과 거부처분취소심판이 가능할 것으로 보인다.
- ② 거부처분취소소송 가능, 의무이행소송은 현행법상 불가

(2) 사업인정신청 후 부작위시 권리구제

부작위위법확인소송이 가능, 의무이행소송은 현행법상 불가

2) 피수용자입장에서 권리구제

- ① 사업인정이 위법한 경우에는 행정쟁송 및 손해배상청구가 가능
- ② 인근주민(제3자)의 원고적격 : 환경영향평가 대상지역 내 주민 <추정>, 밖의 주민은 <입증>필요

01 의미

개별법에서 별도로 규정하고 있는 지구지정·실시계획승인 등이 있을 경우, 이를 토지보상법 상의 사업인정이 있는 것으로 보도록 하는 것을 말한다.

02 취지

절차의 중복을 방지, 개별 법률에 따른 공익성의 특성 반영 취지

03 사업인정 의제제도의 문제점

1) 사업인정제도의 형해화

개별법에서 정한 간소한 절차에 따라 사업인정을 받은 것으로 의제하는 것은 사업인정제도를 형해화하는 문제점

2) 재결신청기간 장기화

많은 개별법에서 재결신청기간의 특례를 인정하여 사업이 장기화되는 문제점

04 사업인정의제 제도의 개선방안

1) 사전적 권리구제 강화

공익사업의 홍보를 통한 지역주민의 참가

2) 사업인정의제 제도 최소화

사업인정의제 제도를 최소한으로 제한, 토지보상법 규정에 의한 표준적인 절차로 일원화, 재결신청기간의 제한 등의 입법적 개선이 필요

CASE

[공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률] 제23조에 의한 사업인정의 실효가 있는 경우 이로 인하여 불이익을 받게 되는 피수용자에게 손실보상청구권이 있는 여부를 논하시오.(40점) (6회 문1)

01 재결신청기간의 경과로 인한 실효(제23조)

1) 실효의 사유 및 실효시기

사업시행자가 사업인정의 고시가 된 날로부터 1년 이내에 재결신청을 하지 아니한 경우에는, 사업인정고시가 된 날로부터 1년이 되는 날의 다음날에 사업인정은 그 효력을 상실한다.(제23조 제1항)

2) 취지

피수용자의 권리보호, 공공성의 계속성을 확보 목적

3) 실효의 효과

사업시행자는 사업이 실효됨으로 인하여 토지소유자나 관계인이 입은 손실을 보상하여야 한다.

4) 관련 문제

개별법의 재결신청기간 특례

02 사업의 폐지 및 변경(제24조)

1) 의의 및 취지

사업인정고시 후 공익사업의 폐지 또는 변경 등으로 인하여 토지를 수용하거나 사용할 필요가 없게 된 경우, 시·도지사가 사업시행자의 신고 또는 직권으로 이를 고시하여 사업인정을 실효시키는 제도이다.

2) 내용

- ① (필요 없게 되었을 때) 사업시행자는 시·도지사에게 신고하고, 토지소유자 및 관계인에게 이를 통지하여야 한다.
(제24조 제1항)
- ② 시·도지사는 신고를 받으면 이 내용을 관보에 고시

3) 실효 시기 및 고시의 법적성질

고시가 된 날부터 효력을 상실

4) 실효의 효과

- ① 사업시행자에게는 손실보상 의무 발생
- ② 사업시행자는 재결신청을 취하여야 하고, 취하지 않으면 그 재결은 각하
- ③ 재결이 있고, 수용의 개시일 이전에 사업인정 취소고시가 있으면, 재결은 실효되는 것으로 해석

구 분	재결신청기간 경과	사업의 폐지·변경
근거	제23조	제24조
절차	사업인정고시일부터 1년 되는 날 다음 날 실효	사업시행자의 신고, 통지 → 시도지사의 고시, 국토교통부장관에게 보고
법적성질	조건 성취로 인한 실효	강학상 철회와 유사(단, 시도지사가 실효 고시)
공동점	◎ 취지 : 공공성 계속적 담보 및 피수용자 보호 ◎ 손실 발생시 손실보상청구 가능(제9조 제5~7항)	

03 사업의 완료(제24조의2)

- ① 사업이 완료된 경우 사업시행자는 지체 없이 사업시행자의 성명이나 명칭, 사업의 종류 등을 사업지역을 관할하는 시·도지사에게 신고하여야 한다.(제24조의2 제1항)
- ② 시·도지사는 신고를 받으면 관보에 고시하여야 한다.(제24조의2 제2항)

제1절

토지조서 및 물건조서의 작성(제27조)

01 조서의 의의 및 성질

1) 의의 및 취지

2) 법적성질

- ① 타인토지출입 측량·조사행위는 <권력적 사실행위>,
- ② 조서작성행위 자체는 <비권력적 사실행위>

02 조서의 작성절차

1) 토지 및 물건에 관한 조사권

(1) 의의

사업인정고시가 된 후에는 사업시행자 또는 감정평가법인등은 허가 또는 통지 없이,
해당 토지나 물건에 출입하여 측량하거나 조사할 수 있다(제27조 제1항).

(2) 법적성질

공용사용의 일종, 사업준비를 위한 타인토지출입에 비해 간단한 절차

2) 작성절차 및 작성의 특례

사업인정 이전에 토지조서 및 물건조서의 작성 등의 절차를 거쳤으나, 협의를 성립되지 아니하고 사업인정을 받은 사업으로서, 토지조서 및 물건조서의 내용에 변동이 없을 때에는 토지조서 및 물건조서의 작성 등의 절차를 거치지 아니할 수 있다.(제26조 제2항 본문)

3) 손실보상의무

4) 장애물 제거 관련 논의

사업준비를 위한 장애물 제거 등에 관한 규정(제12조)은 사업인정 후 조서작성에도 준용된다고 보는 것이 타당

03 조서의 효력

1) 사업인정고시일 이전

사업시행자에게 수용권 없음. 조서에 <진실의 추정력> 인정 안됨.

2) 사업인정고시일 이후

(1) 이의를 제기하지 않은 경우

a. 원칙

- ① 토지소유자나 관계인이 조서의 내용에 대하여 이의를 제기하지 않은 경우에는 그 이후 협의 또는 재결단계에서 이에 대해 이의를 제기할 수 없다.
- ② <진실의 추정력> 인정

b. 예외

- ① 이의를 제기하지 않은 경우에도, 조서의 내용이 진실과 다르다는 것을 입증할 때에는 <진실의 추정력> 부정
- ② 토지소유자 또는 관계인이 반대의 증거를 제시하여 입증해야 한다.

(2) 이의를 제기한 경우

이의가 제기된 사항에 대해서는 <진실의 추정력> 부정

(3) 서명 또는 날인을 거부한 경우

<진실의 추정력> 인정

04 절차상 하자 있는 조서의 효력

1) 원칙

절차상 하자가 있는 조서는 적법하게 작성된 조서가 아니므로 원칙적으로 조서로서의 효력이 없다.
(진실의 추정력 부인)

2) 조서 작성의 하자와 재결과의 관계

<판례>는 절차상 하자 있는 조서는 증명력에 관하여 추정력이 인정되지 않는 것일 뿐, 재결의 효력에 영향을 미치는 것은 아니라고 판시한 바 있다.

05 내용상 하자 있는 조서의 효력

- ① <진실의 추정력> 인정
- ② 열람기간 내에 이의를 제기하거나, 조서내용이 진실과 다르다는 것을 입증해서 <진실의 추정력> 차단 가능

06 피수용자의 권리구제방안

1) 행정쟁송

- ① 조서작성행위는 <비권력적 사실행위>
- ② 조서작성을 위한 타인토지출입 측량*조사행위는 권력적 사실행위, 협의의 소익이 문제(집행정지 신청 필요)

2) 손실보상

토지보상법 제9조 제5항에서 제7항을 준용한다.

CASE

1. 공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률상 사업인정 전 협의와 사업인정 후 협의의 차이점에 대하여 설명하시오.(10점)[25회 문4번]
2. 토지보상법상 다음의 법적 성격을 설명하시오.(10점)[36회 문1]
 - ① 사업인정 전과 후의 '보상에 관한 협의'
 - ② 사업인정 후 '협의취득'
3. 「공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률」제26조는 수용재결 신청 전에 사업시행자로 하여금 수용 대상 토지에 관하여 권리를 취득하거나 소멸시키기 위하여 토지소유자 및 관계인과 교섭하도록 하는 협의제도를 규정하고 있다. 이에 따른 협의가 수용재결 신청 전의 필요적 전치절차인지 여부와 관할 토지수용위원회에 의한 협의성립의 확인의 법적 효과를 설명하시오. (10점) (30회 문4)

01 의의 및 취지

1) 의의

수용재결신청 전에 사업시행자로 하여금 수용대상 토지에 관하여 권리를 취득하거나 소멸시키기 위하여 토지소유자 및 관계인과 교섭하도록 하는 절차이다.

2) 취지

가급적 상대방의 협력을 구하여 사업의 원활을 기하기 위한 취지

02 필수절차인지 여부

- ① 필수절차이나, 예외적으로 생략할 수 있도록 하였다.
- ② 다만, 생략가능한 경우라 하더라도, 협의 요구시 협의해야 한다.

03 법적성질

1) 논의의 실익

법적성질에 따라 적용법규와 쟁송형태가 달라지므로 논의의 실익이 있다.

2) 학설

(1) 사법상 계약설

(2) 공법상 계약설

국가적 공권의 주체로서 기득의 수용권을 실행하는 방법의 하나이므로 공법상 계약

3) 판례

- ① 사법상의 법률행위
- ② 다만, 최근 판례에서 협의취득의 배후에는 수용에 의한 강제취득 방법이 남아 있어 토지 등의 소유자로서는 협의에 불응하면 바로 수용을 당하게 된다는 심리적 강박감이 자리 잡을 수밖에 없으며 협의취득 과정에는 여러 가지 공법적 규제가 있는 등 **공익적 특성**을 고려하여야 한다고 판시하였다.

4) 검토

- ① 협의는 공익사업을 통해 공공복리를 증진하는 것을 목적으로 한다는 점,
- ② 사업인정 후 협의는 사업인정 전 협의와 달리 사업시행자에게 사업인정을 통하여 수용권이 주어진 상태에서 이루어지는 협의라는 점,
- ③ 협의에 불응하면 수용재결을 당하게 된다는 심리적 강박감이 있는 공익적 특성을 고려하여 **공법상 계약**으로 보는 것이 타당하다.

04 협의의 성립절차

1) 상대방

전원을 대상으로 협의하여야 한다.

2) 협의기간

특별한 사유가 없는 한 30일 이상으로 하여야 한다.

3) 협의의 내용

재결사항(제50조)과 내용적으로 거의 같다

4) 협의의 절차(령 제8조 제1항)

05 협의 성립 및 불성립의 효과

1) 협의 성립의 효과

- ① 협의성립시 계약체결
- ② 사법상 계약의 효과, 승계취득

2) 협의 불성립의 효과

(1) 재결의 신청

사업인정고시일로부터 1년 이내

(2) 재결신청의 청구

- ① 사업인정고시 후 협의불성립시 토지소유자와 관계인은 서면으로 사업시행자에게 재결을 신청할 것을 청구할 수 있다.(제30조 제1항)
- ② 재결신청청구를 받은 날부터 60일 이내에 재결을 신청하여야 한다.(제30조 제2항)

06 사업인정 후 '협의취득'의 법적성격

승계취득이나 협의성립확인을 받으면 수용재결과 같은 효력을 부여(원시취득)

07 관련 문제

1) 협의절차하자와 재결의 관계

판례는 기업자가 토지소유자와 협의를 거치지 아니한 채 토지의 수용을 위한 재결을 신청하였다는 등의 하자는 절차상의 위법 → 무효사유 아님

2) 위험부담의 문제

- ① 그러나 토지보상법 제46조(위험부담)를 협의 후 목적물 멸실 등 경우에도 적용할 수 있는지 문제
- ② 대법원은 협의성립 후 보상금이 지급되기 전에 그 입목이 홍수로 멸실되었다 하더라도 매수 또는 보상하기로 한 자는 이행불능을 이유로 위 보상약정을 해제할 수 없다고 판시
- ③ 위험부담이전 규정 취지는 피수용자 권리보호를 위한 것이므로, 협의에도 적용 가능

3) 사업시행자의 손실보상의무 불이행시 재결실효규정 적용여부

- ① 토지보상법상 재결실효규정(제42조, 보상금미지급시 재결실효)을 유추 적용하여 협의의 실효를 주장할 수 있는지가 문제
- ② 그러나 토지보상법상 명문 규정 없어 적용 곤란

08 사업인정 전·후 협의의 비교

구분	사업인정 전 협의(제16조)	사업인정 후 협의(제26조)
공통점	최소침해원칙, 협의내용(법50조 재결사항)	
필수적 전치절차 여부	임의절차 성신허의의무만 있음	예외적 경우 제외하고 반드시 거쳐야 하는 필수절차
법적성질	사법상 계약(판례) & 사법상 계약(다수설)	사법상 계약(판례) & 공법상 계약(다수설)
협의성립 확인제도 유무	없음	있음
협의성립시 효과	승계취득	- 협의성립확인 받기 전 승계취득, - 확인 후 재결간주 원시취득
협의 불성립시 효과	사업인정 신청	- 사업시행자 재결신청 - 피수용자 재결신청청구
권리구제	민사소송	- 판례 민사소송 - 다수설 공법상 당사자소송
양자의 관계	① 절차상 선후관계 ② 사업인정 전 협의 불성립하고 조서내용불변이면 당사자 협의 요구 없을 시 사업인정 후 협의 생략가능	

CASE

「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제26조는 수용 재결 신청 전에 사업시행자로 하여금 수용대상 토지에 관하여 권리를 취득하거나 소멸시키기 위하여 토지소유자 및 관계인과 교섭하도록 하는 협의제도를 규정하고 있다. 이에 따른 협의가 수용재결 신청 전의 필요적 전치절차인지 여부와 관할 토지수용위원회에 의한 협의성립의 확인의 법적 효과를 설명하시오.(10점) [30회 4번]

01 의의 및 취지 (토지보상법 제29조)

- ① 사업인정 후 협의가 성립하면 사업시행자가 피수용자의 동의를 받거나 또는 공증을 받아 관할 토지수용위원회의 확인을 받는 제도이다.
- ② 계약 불이행에 따른 분쟁 예방, 공익사업의 원활한 진행에 규정취지가 있다.

02 법적성질

특정한 사실관계 또는 법률관계에 대해 의문이 있는 경우 공권적으로 그 존부 또는 정부를 판단하는 행위이므로 <확인행위>로 봄이 일반적이다.

03 확인의 절차

1) 일반적 확인절차 (제29조 제1항)

- ① 협의가 성립되었을 때 사업시행자는 재결신청기간 내에 피수용자의 동의를 얻어 관할 토지수용위원회에 협의성립의 확인을 신청할 수 있다.(제29조 제1항)
- ② 토지수용위원회는 협의성립확인신청서를 접수한 때 → 공고·열람
- ③ 열람기간 동안 의견제시 가능
- ④ 열람기간 종료시 해당 신청에 대한 조사 및 심리, 14일 이내에 확인

2) 공증에 의한 확인절차 (제29조 제3항)

- ① 사업시행자가 「공증인법」에 따른 공증을 받아 협의 성립의 확인을 신청하였을 때에는, 관할 토지수용위원회가 이를 수리함으로써 협의성립이 확인된 것으로 본다.(제29조 제3항)
- ② 수리가 있어야 협의성립확인 효과 발생

04 확인의 효과

- ① 협의성립에 대한 확인이 있게 되면 재결로 간주되어, 재결과 동일한 효과가 발생
- ② 확인된 협의의 성립이나 내용에 대하여 다툴 수 없는 확정력이 발생(제29조 제4항)
- ③ 재결의 실효규정(제42조) 적용

05 불복

1) 확인에 대한 불복

재결로 간주, 재결의 불복과 동일(제83조, 제85조)

2) 협의 자체에 대한 불복

먼저 확인의 효력을 행정쟁송으로 없앤 후, 협의에 대하여 다룰 수 있다.

〈협의성립확인 전과 후의 비교〉

구분		협의성립확인 전	협의성립확인 후
공통점		효과 동일(손실보상&환매권&위험부담의 이전&담보물권자의 물상대위)	
차 이 점	목적물취득의 법적성질	승계취득	원시취득
	물권변동의 형태	법률행위에 의한 물권변동(등기필요)	법률규정에 의한 물권변동(등기불요)
	착오의 경우 권리구제	민법규정 유추적용	확정력이 발생하여 못 다툼
양자의 관계		당사자 간의 계약을 공법상의 처분으로 전환시키는 관계	

제1장

재결신청청구권

CASE

협의 과정에서 일부 지장물에 관하여 협의가 이루어지지 않아 토지소유자 甲이 A공사에게 재결신청을 청구했으나 A공사가 재결신청을 하지 않는 경우, 甲의 불복 방법에 관하여 검토하시오. [32회 문1번]

01 의미, 취지(토지보상법 제30조)

- ① 사업인정 후 협의가 성립하지 아니한 때 피수용자가 사업시행자에게 조속히 재결신청을 할 것을 청구할 수 있는 권리를 말한다.
- ② 수용을 둘러싼 법률관계의 조속한 확정, 수용 당사자 간의 공평

02 법적성질

공법상 청구권의 성질

03 요건

1) 당사자

피수용자가 사업시행자에게 청구

2) 청구기간

(1) 원칙

협의가 성립하지 않은 경우, 사업인정고시가 있는 날로부터 1년 이내

(2) 예외

- ① 협의불성립이 명백한 경우에는 협의기간 만료 전이라도 재결신청청구 가능
- ② 사업시행자가 사업인정 후 상당 기간 경과하도록 협의에 대한 통지를 하지 않은 경우 재결신청청구 가능

(3) 협의가 성립하지 아니한 때의 의미에 대한 판례

- (a) 협의절차를 거쳤으나 협의가 성립하지 아니한 경우
- (b) 손실보상대상에서 제외하고 협의를 거치지 않은 경우

3) 청구의 내용 및 형식

재결을 신청한다는 내용으로 재결신청청구서를 제출

04 청구의 효과

- ① 청구를 받은 날부터 60일 이내에 관할 토지수용위원회에 재결신청 의무발생
- ② 신청지연시 지연된 기간에 법정이율을 적용한 가산금 지급

05 권리구제

1) 사업시행자가 재결신청청구를 거부 또는 부작위하는 경우

(1) 민사소송 또는 공법상 당사자소송

민사소송과 공법상 당사자소송은 불인정

(2) 항고소송 인정여부

a. 문제점

재결신청청구의 거부가 거부처분인지 문제

b. 재결신청청구 거부의 대상적격 인정여부

가) 거부가 처분이 되기 위한 판례 요건

법규상·조리상 신청권의 존재, 공권력행사의 거부일 것, 국민의 권리·의무에 직접 영향을 미칠 것이 요구된다.

나) 재결신청청구 거부가 공권력행사 거부인지

재결신청청구 거부시 재결의 거부와 같은 결과를 가져올 수 있는 점을 고려하여 공권력행사로 봄이 타당하다.

다) 판례의 태도

거부처분 취소소송 또는 부작위 위법확인소송의 방법으로 다투어야 한다고 판시

라) 검토

재결신청거부는 취소소송의 대상적격이 인정

c. 소결

소송요건 충족한다면 항고소송으로 권리구제 가능

2) 지연가산금에 대한 다툼

- ① 판례는, 지연가산금은 법정 지연손해금의 성격을 갖는 것으로, 지연가산금은 수용보상금과 함께 수용재결로 정하도록 규정하고 있으므로, 지연가산금에 대한 불복은 수용보상금의 증액에 관한 소(보증소)에 의하여야 한다고 판시하였다.
- ② 제83조의 이익신청도 가능

06 관련 문제

피수용자의 권리보호에 미흡

01 의미 및 근거

재결신청은 협의불성립시 사업시행자가 토지수용위원회에게 수용 또는 사용의 재결을 구하는 절차 행위이다.(제28조)

02 요건

- ① 재결신청권자는 사업시행자
- ② 협의 불성립시, 관할 토지수용위원회, 사업인정고시일로부터 1년 이내

03 재결신청 기각시

재결신청이 기각되어도 재결신청기간 이내라면 재결신청을 할 수 있고, 토수위는 다시 수용재결을 할 수 있다.

04 사업시행자에게만 재결신청권을 인정하는 이유와 타당성

- ① 피수용자에게 재결신청권 부여시 공익사업 계획에 지장이 생길 우려
- ② 형평차원에서 피수용자에게 재결신청청구권이 인정

구 분	재결신청의 청구	재결신청
법적근거	30조	28조
당사자	피수용자가 사업시행자에게	사업시행자가 관할 토지수용위원회에
의미	재결신청을 조속히 해 달라	재결 결정을 내려 달라
비고	신청지연시 지연가산금 발생 가능	사업인정고시일 1년 내 하지 않으면 사업인정 실효

01 의의 및 취지

관할 토지수용위원회가 행하는 수용 또는 사용결정의 최종적 판단절차

02 법적 성질

1) 형성적 행정행위

- ① 처분
- ② 행정심판의 재결과는 구별되는 원행정행위
- ③ 준사법적인 행정행위이므로 불가변력이 인정

2) 기속행위·재량행위 여부

(1) 수용목적물의 범위

수용목적물의 범위와 관련하여서는 기속행위의 성질

(2) 손실보상금의 결정

보상금액의 결정에 대해서는 증액재결이 가능하므로 재량행위의 성질

3) 공법상 대리

수용권자와 피수용권자를 대신하여 수용재결의 사항을 판단하므로 공법상 대리의 성격

03 재결의 성립

1) 재결의 주체

토지수용위원회(독립된 합의제 행정청)

2) 재결의 내용과 범위

(1) 재결의 내용

(2) 재결의 범위

신청한 범위에서 재결, 증액재결 가능

3) 재결 형식

서면

4) 재결의 절차

5) 재결의 결함

(1) 재결의 경정 (토지보상법 제36조)

재결에 계산상 또는 기재상의 잘못이나 그 밖에 이와 비슷한 잘못 → 경정재결

(2) 재결의 유탈 (토지보상법 제37조)

토수위가 신청의 일부에 대한 재결을 빠뜨린 경우에 그 빠뜨린 부분의 신청은 그 토수위에 계속된다.

6) 재결의 효과

(1) 목적물의 권리취득

사업시행자는 수용의 개시일에 토지나 물건의 소유권을 취득하며, 그 토지나 물건에 관한 다른 권리는 이와 동시에 소멸한다(원시취득)

(2) 위험부담의 이전

토지수용위원회의 재결이 있은 후 수용하거나 사용할 토지나 물건이 토지소유자 또는 관계인의 고의나 과실 없이 멸실되거나 훼손된 경우 그로 인한 손실은 사업시행자의 부담으로 한다(제46조).

(3) 손실보상청구권

- ① 피수용자는 재결의 효과로서 손실보상청구권을 취득
- ② 사업시행자는 수용 또는 사용의 시작일까지 관할 토지수용위원회가 재결한 보상금을 지급하여야 한다.

제4절

재결의 실효

01 의미 및 취지

유효하게 성립한 재결효력이 객관적 사실의 발생에 따라 사후적으로 상실되는 것을 말한다.

02 내용

1) 보상금을 지급 또는 공탁하지 않은 경우 (토지보상법 제42조)

2) 사업인정이 취소되는 경우

- ① 수용의 개시일 이전 사업인정 취소 : 재결은 실효
- ② 수용의 개시일 이후 사업인정 취소 : 환매권 발생

03 효과 (손실보상의무 발생)

1) 사업시행자의 손실보상

손실보상의무 발생

2) 손실보상의 절차 및 방법

제9조 제5항부터 제7항까지의 규정을 준용

04 관련 문제

1) 재결실효와 재결신청효력의 관계

(1) 문제점

재결이 실효된 경우 재결신청도 실효되는지가 문제

(2) 견해 대립

- ① 재결의 효력만 실효, 재결신청은 유효하다는 견해
- ② 재결과 재결신청이 같이 실효된다는 견해

(3) 판례

사업시행자가 수용의 개시일까지 보상금을 지급 또는 공탁하지 않으면 재결은 물론 재결신청의 효력까지 상실된다고 판시(그로 인하여 사업인정도 실효될 수 있음)

(4) 검토

피수용자 보호를 위하여 재결의 효력이 상실되면 그 재결신청도 효력이 상실된다는 견해가 타당

2) 이의재결 증액보상금 미지급 시 이의재결의 실효

- ① 토지수용법 제84조 제2항은 법 제42조와 달리 실효규정을 두지 않았고
- ② 법 제88조에서 처분효력의 부정지를 규정하고 있으므로
- ③ 이의재결에서 증액된 보상금을 지급*공탁하지 않았더라도 이의재결이 당연히 실효되는 것은 아니라고 본다.

01 의의 및 취지 (토지보상법 제33조)

화해는 토지수용위원회의 심리과정에서 사업시행자와 토지소유자 및 관계인이 서로 양보하여 상호간의 주장을 일치시킴으로써 분쟁을 종결시키는 것을 말한다.

02 법적성질

- ① 공법상 계약으로 보는 견해
- ② 재판상 화해로 확정판결로 보는 견해
- ③ 재결로 보아야 한다는 견해

03 협의와의 차이점

- ① 협의는 재결신청 전 수용 당사자 간에 공법상 계약, 화해는 재결신청 후 토지수용위원회의 중재
- ② 협의는 필요적 절차, 화해는 임의적 절차

04 절차

05 화해조서의 효력

- ① 화해조서에 서명 또는 날인이 된 경우에는 당사자간에 화해조서와 동일한 내용의 **합의**가 성립된 것으로 본다.
- ② 명문규정 없으나, **협의성립확인** 또는 **재결**과 같은 효력이 있다고 보는 것이 타당

06 화해조서 작성에 대한 다툼

- ① 불복규정 없음
- ② 화해의 법적성질을 재결로 본다면 재결에 대한 불복방법을 준용, 재판상 화해로 본다면 재심사유가 없는 한 다툼 수 없게 될 것이다.

CASE

토지보상법 제38조 천재지변시 토지사용과 동법 제39조 시급한 토지 사용을 비교하시오,

01 의미

약식절차란 토지의 수용 또는 사용에 관한 보통절차 가운데 그 일부를 생략하고 행하는 절차를 말한다.

02 천재지변 시의 토지의 사용

1) 의미

천재지변이나 그 밖의 사변으로 공공의 안전을 유지하기 위한 공익사업을 긴급히 시행할 필요가 있을 때 특별자치도지사·시장·군수·구청장의 허가를 받아 타인의 토지를 사용할 수 있게 하는 약식절차이다(제38조).

2) 요건

- ① 천재지변 그 밖의 사변 시에 한정된다.
- ② 공공의 안전을 유지하기 위한 공익사업을 긴급히 시행할 필요가 있어야 한다.
- ③ 토지보상법 제4조 각 호의 하나에 해당하는 공익사업이어야 한다.
- ④ 사업시행자의 신청을 전제한다.
- ⑤ 사용기간은 6개월을 넘지 못한다(제38조 제3항).

3) 절차

- ① 사업시행자는 허가를 받아 즉시 사용할 수 있고, 사업시행자가 국가 또는 특별시·광역시 또는 도일 때에는 통지하고 사용할 수 있다(제38조 제1항).
- ② 허가를 하거나 통지를 받은 경우 또는 직접 사용하려는 경우 즉시 토지소유자 및 토지점유자에게 통지하여야 한다(동조 제2항).

4) 효과

- ① 사업시행자 : 사용권을 취득, 사용기간 만료 시 반환 및 원상회복의무(제48조), 대행(제44조)·대집행(제89조) 신청권 발생
- ② 토지소유자 : 토지인도 의무, 손실보상청구권 발생

5) 권리구제

(1) 위법한 허가에 대한 행정쟁송 및 손해배상

위법한 허가에 대하여 행정쟁송으로 다툴 수 있고, 손해배상 요건 충족 시 손해배상을 청구할 수 있다.

(2) 적법한 허가에 대한 손실보상

- ① 손실보상 해야 한다.
- ② 제9조 제5항부터 제7항까지의 규정을 준용

(3) 원상회복에 대한 공법상 결과제거청구권

공법상 결과제거청구권 행사가 가능

03 시급한 토지사용에 대한 허가

1) 의의

공익사업이 진행되는 동안 재결이 지연됨으로써 재해를 방지할 수 없거나 공공의 이익에 현저한 지장을 줄 우려가 있다고 인정되는 경우 재결신청을 받은 토지수용위원회의 허가로서 토지를 사용할 수 있게 하는 약식절차이다 (제39조).

2) 요건

- ① 보통절차에 의해 재결신청 중에 있는 공익사업이어야 한다.
- ② 토지수용위원회의 재결이 지연되고 있는 경우여야 한다.
- ③ 재결이 지연됨으로 인하여 재해를 방지하기 곤란하거나, 공공의 이익에 현저한 지장을 줄 우려가 있다고 인정되어야 한다.
- ④ 사업시행자의 신청을 전제한다.
- ⑤ 사업시행자가 국가나 지방자치단체인 경우를 제외하고 담보를 제공하여야 한다.
- ⑥ 사용기간은 6개월을 넘지 못한다(제39조 제2항).

3) 절차

- ① 토지수용위원회가 허가한 때에는 토지소유자 및 점유자에게 통지
- ② 담보의 제공

4) 효과

- ① 사업시행자 : 사용권을 취득, 사용기간 만료 시 반환 및 원상회복의무(제48조), 대행(제44조)·대집행(제89조) 신청권 발생
- ② 토지소유자 : 토지인도의무, 손실보상청구권 발생, 보상금의 지급시기까지 미지급시 제공된 담보의 전부 또는 일부를 취득

5) 권리구제

(1) 위법한 허가에 대한 행정쟁송 및 손해배상

위법한 허가에 대하여 행정쟁송으로 다툴 수 있고, 손해배상 요건 충족 시 손해배상을 청구할 수 있다.

(2) 적법한 허가에 대한 손실보상

토지수용위원회의 재결이 있기 전에 토지소유자나 관계인이 청구할 때에는 사업시행자는 자기가 산정한 보상금을 토지소유자나 관계인에게 지급하여야 한다(제41조 제1항).

(3) 원상회복에 대한 공법상 결과제거청구권

공법상 결과제거청구권 행사가 가능하다.

구분		천재지변 시 토지 사용(법38조)	시급한 토지 사용(법39조)
공 통 점	취지	보통절차를 거칠 여유가 없는 경우 원활한 사업진행을 도모	
	요건	관련 행정청의 허가&토지소유자 및 점유자에 대한 통지&공용사용의 경우만 허용	
	사용기간 및 효과	6월 이내 사용, 반환 및 원상회복 의무	
	보상의 특징	사후보상(사전보상의 예외)	
차 이 점	허가권자	시·군·구청장	재결신청전제&관할토지수용위원회
	담보물 제공 여부	제공X	제공O
	보상금 지급 절차	협의절차 있음 (9조5항~7항준용)	협의절차 없음 (재결로 보상금 결정)
	손실보상액에 대한 불복	별도규정 없음(9조)	별도규정 있음(41조)

제1절

공용수용의 일반적 효과

01 서

사업시행자가 공익사업에 필요한 목적물을 취득하고, 토지소유자와 관계인은 목적물에 대한 권리를 상실

02 권리변동의 시기

1) 공용수용 절차 종결 시기

공용수용의 절차는 협의의 성립, 협의성립확인, 재결, 화해조서작성으로 종결된다.

2) 공용수용 효과 발생 시기

- ① 수용의 개시일에 발생
- ② 사업시행자가 보상금의 지급 또는 공탁을 하는 것을 조건으로 발생

03 사업시행자에 대한 효과

1) 권리의 원시취득

- ① 사업시행자는 수용의 개시일에 토지나 물건의 소유권을 취득하며, 그 토지나 물건에 관한 다른 권리는 이와 동시에 소멸한다(제45조 제1항).
- ② 등기하지 않아도 소유권 취득, 다만 타인에게 처분하려면 등기 필요

2) 손실보상의무

수용의 개시일까지 보상금 지급의무, 수용의 정지조건

3) 위험부담의 이전

재결 이후에는 사업시행자에게 위험부담 이전

4) 사용기간 만료 시 반환·원상회복의무

04 피수용자에 대한 효과

1) 손실보상청구권

- ① 재결이 있어야 피수용자에게 손실보상청구권이 발생한다.
- ② 그러므로, 재결절차를 거치지 않은 채 곧바로 사업시행자를 상대로 손실보상을 청구하는 것은 허용되지 않는다.

2) 토지·물건의 인도·이전 의무

3) 담보물권자의 물상대위

제2절 보상금 지급 또는 공탁

01 사업시행자의 보상금 지급의무

보상금의 지급은 피수용자에 대한 사업시행자의 의무이며, 수용의 정지조건이다.

02 보상금의 공탁

CASE

사업시행자 甲은 피수용자 乙의 수용보상금에 대하여 공탁을 하면서, 공탁금 수령시 앞으로 물건의 인도이전등 사업에 협조할 것을 조건으로 공탁하였다. 그러나 乙는 이에 대하여 이의유보없이 보상금을 수령하였다. 乙의 공탁금 수령의 효과를 검토하시오

1) 의의 및 취지

- ① 보상금의 공탁이란 일정한 사유(제40조 제2항)가 있을 때, 사업시행자가 보상금을 공탁함으로써 보상금 지급에 갈음하는 제도이다.
- ② 이는 사전보상원칙을 실현하고, 피수용자의 권익을 보호함에 취지가 있다.

2) 요건

- (1) 보상금 받을 자가 수령을 거부하거나 보상금을 수령할 수 없을 때
- (2) 사업시행자의 과실 없이 보상금을 받을 자를 알 수 없을 때
- (3) 관할 토지수용위원회가 재결한 보상금에 대하여 사업시행자가 불복할 때
- (4) 압류나 가압류에 의하여 보상금의 지급이 금지되었을 때

3) 공탁의 성질

(1) 문제점

토지보상법상의 공탁이 〈민법상 변제공탁〉과 그 성질이 같은 것인지 문제된다.

(2) 학설

- ① 보상금 지급에 갈음하여 하는 공탁은 채무자가 채무를 변제한 것과 같은 효과를 발생시키기 위해 행하는 〈변제공탁〉으로 보는 견해
- ② 다만, 민법상 변제공탁은 목적물 전부를 공탁해야 하는데, 보상금이 증액된 경우에는 일부만의 공탁이 되므로 변제공탁이 아니라고 보는 견해
- ③ 사업시행자가 재결에 불복하여 공탁하는 경우는 일종의 담보공탁이라고 보는 견해
- ④ 압류·가압류에 의한 공탁은 집행공탁이라 보는 견해가 있다.

(3) 판례

- ① 보상금의 지급의무를 이행하기 위한 것으로서, 민법상 변제공탁과 다를 바 없다
- ② 압류·가압류에 의한 공탁에 대하여는 변제공탁으로 보는 듯한 판례와 집행공탁으로 보는 듯한 판례가 있다.

(4) 검토

- ① 보상금 지급의무를 면하고자 하는 공탁은 변제공탁
- ② 그러나 사업시행자가 재결에 불복하여 보상금액의 차액을 공탁한 경우는 일종의 담보공탁

4) 공탁의 구체적 내용

(1) 공탁의 당사자

(2) 관할 공탁소

(3) 공탁물

5) 공탁의 효과 및 공탁하지 아니한 경우 효과

(1) 공탁의 효과

- ① 보상금지급 효과가 발생
- ② 수용의 개시일 이전에 공탁이 있었다 하더라도 수용의 효과는 수용의 개시일에 발생
- ③ 쟁송절차에 의한 보상금 증액이 있어도 공탁한 보상금에 대해서는 지연이자가 발생하지 않는다.

(2) 보상금 미공탁의 효과

a. 원재결에서 정한 보상금의 미공탁

재결은 그 효력을 상실한다(제42조).

b. 이의재결에서 정한 보상금의 미공탁

판례는 이의재결에서 증액된 보상금을 공탁하지 아니한 경우에도 이의재결이 실효되는 것은 아니라고 한다.

6) 하자 있는 공탁 및 수령의 효과

(1) 하자 있는 공탁의 효과

- a. 공탁요건에 해당하지 아니하는 공탁
- b. 보상금 일부의 공탁
- c. 조건부 공탁

(2) 공탁 하자의 치유

이의유보 없이 이를 수령하면 그 공탁은 유효

(3) 하자 있는 공탁금 수령의 효과

a. 이의를 유보하지 않고 수령한 경우

재결에 대하여 승복한 것으로 본다.

b. 이의신청 및 행정소송 제기 후 이의유보 없이 수령한 경우

(가) 견해 대립

- ① 이의신청 또는 행정소송의 제기를 이의유보로 보는 견해
- ② 다른 견해는 이의신청이나 행정소송의 제기와 이의유보는 별개의 것으로서 보는 견해

(나) 판례

- ① 판례는 과거 이의신청이나 행정소송의 제기를 이의유보로 볼 수 없다는 입장이었으나,
- ② 최근에는 이의유보의 의사표시는 반드시 명시적으로 하여야 하는 것은 아니므로, 행정소송을 제기하고 시가감정의 비용지출 등을 하는 경우에는 **묵시적인 이의유보**가 있는 것으로 보았다.

(다) 검토

이의신청이나 행정소송의 제기 자체를 이의의 유보를 한 것으로 볼 수 있으므로, 피수용자의 권리보호를 위하여 공탁금 수령 시 이의유보를 확인하는 절차 마련 필요(또는 피수용자 보호를 위하여 이의신청이나 행정소송의 제기를 이의유보로 볼 필요가 있다.)

c. 이의를 유보하고 수령한 경우

공탁의 하자가 치유될 수 없다.

CASE

토지보상법상 수용목적물의 인도·이전의무에 대한 실효성 확보수단에 대해 설명하시오. [16회 문3]

01 인도 및 이전의무

1) 의의

토지소유자나 관계인과 그 밖에 토지소유자나 관계인에 포함되지 아니하는 자로서 수용하거나 사용할 토지나 그 토지에 있는 물건에 관한 권리를 가진 자는 수용 또는 사용의 개시일까지 그 토지나 물건을 사업시행자에게 인도하거나 이전하여야 한다(제43조).

2) 인도·이전 의무가 수용효과의 발생조건인지 여부

인도의무는 수용효과의 발생조건이 아니다.

3) 인도·이전의무와 손실보상이 동시이행의 관계인지 여부

피수용자가 목적물의 인도·이전의무를 이행하지 않아도, 사업시행자는 보상금을 지급 또는 공탁함으로써 수용의 효과가 발생하기 때문에 동시이행의 관계가 아니다.

02 토지보상법상 의무이행확보수단

1) 개설

대행(제44조) 및 대집행(제89조), 벌칙규정(제95조의2 제2호) 규정

2) 대행

(1) 의의 및 취지

- ① 토지·물건을 인도·이전해야 할 자가 고의나 과실 없이 의무를 이행할 수 없거나, 사업시행자가 과실 없이 토지나 물건을 인도·이전할 자를 알 수 없을 때, 사업시행자의 청구에 의하여 특별자치도지사·시장·군수 또는 구청장이 인도·이전의무를 대행하는 제도이다(제44조).
- ② 공익사업을 원활하게 추진

(2) 법적성질

- ① 행정대집행의 일종으로 보는 견해
- ② 토지보상법 제89조에 해당하지 않는 특례로 보는 견해

(3) 요건 및 절차

- ① 토지나 물건을 인도하거나 이전하여야 할 자가 고의나 과실 없이 그 의무를 이행할 수 없을 때
- ② 사업시행자가 과실 없이 토지나 물건을 인도하거나 이전하여야 할 의무가 있는 자를 알 수 없을 때
- ③ 사업시행자의 청구에 의하여 토지나 물건의 인도 또는 이전을 대행하여야 한다.
- ④ 그로 인한 비용은 그 의무자가 부담, 미납부시 지방세 체납처분의 예에 따라 징수 가능

(4) 대행정구의 대상이 되는 토지·물건의 범위

수용목적물뿐만 아니라 사업시행에 방해가 되는 것이면 대행정구의 대상이 된다.

3) 대집행

CASE

A시는 시가지 철도이설사업을 시행하기 위하여 토지보상법 제16조에 따라 주택용지를 협의취득하면서 그에 따른 일체의 보상금을 B에게 지급하였고, B는 해당 주택을 자진철거하겠다고 약정하였다. B가 자진철거를 하지 않을 경우 B의 주택에 대하여 대집행을 할 수 있는지 판단하시오. [22회 문3]

(1) 의의 및 취지

- ① 대체적 작위임무의 불이행에 대하여 당해 행정청이 스스로 또는 제3자로 하여금 의무를 이행하게 하고, 의무자에게 비용을 징수하는 제도이다.
- ② 공익사업을 원활하게 시행

(2) 요건

a. 토지보상법상 요건 [이완공]

- ① 이 법 또는 이 법에 따른 처분으로 인한 의무를 이행하여야 할 자가
- ② 그 정하여진 기간 이내에 의무를 이행하지 아니하거나 완료하기 어려운 경우
- ③ 또는 그로 하여금 그 의무를 이행하게 하는 것이 현저히 공익을 해친다고 인정되는 사유가 있는 경우에는
- ④ 사업시행자는 시·도지사나 시장·군수 또는 구청장에게 「행정대집행법」에서 정하는 바에 따라 대집행을 신청할 수 있다.

b. 행정대집행법상 요건

- ① 법률에 의하여 직접 명령되었거나 또는 법률에 의거한 행정청의 명령에 의한 행위로서
- ② 타인이 대신하여 행할 수 있는 행위를 의무자가 이행하지 아니하는 경우
- ③ 다른 수단으로써 그 이행을 확보하기 곤란하고
- ④ 또한 그 불이행을 방지함이 심히 공익을 해할 것으로 인정될 때에는
- ⑤ 당해 행정청은 스스로 의무자가 하여야 할 행위를 하거나 또는 제삼자로 하여금 이를 하게 하여 그 비용을 의무자로부터 징수할 수 있다.

(3) 인도·이전 의무가 대집행 대상인지

a. 문제점

- ① 원칙적으로 토지·물건의 인도의무는 대체적 작위임무가 아니므로 대집행이 불가
- ② 다만, 토지보상법 제89조상의 <의무>에 토지·물건의 인도의무까지 포함하여 대집행의 대상이 되는 것으로 볼 수 있는지 논란이 있다.

b. 학설

① 부정설

토지·물건의 인도의무는 대체적 작위임무가 아니므로 불가하다는 견해

② 긍정설

토지보상법 제89조는 의무자가 당해 토지를 인도한 것과 같은 법적 효과를 발생시키는 것을 목적으로 하므로 긍정하는 견해

c. 판례

명도 의무는 그것을 강제적으로 실현하면서 직접적인 실효 행사가 필요한 것이지 대체적 작위 의무라고 볼 수 없으므로 특별한 사정이 없는 한 대집행의 대상이 될 수 있는 것이 아니라 한다.

d. 검토

- ① 인도의무는 비대체적 작위 의무이므로 대집행 인정 곤란
- ② 법치행정의 원리상 명확한 법적 근거 없이 대집행을 비대체적 작위 의무까지 확대하여 적용하는 것은 국민의 권익 보호 측면에서 문제
- ③ 따라서 직접강제제도의 도입에 대한 검토가 요구

01 개설

- ① 사법상 계약에 있어서 위험부담은 매도인이 진다.
- ② 그러나 토지보상법 제46조는 민법상 채무자위험부담주의의 예외를 규정하여 피수용자를 보호하기 위한 제도를 마련하고 있다.

02 의의 및 취지

- ① 재결이 있는 후 수용 또는 사용의 목적물이 사업시행자에게 인도 또는 이전되기 이전에 멸실·훼손되었더라도 사업시행자는 재결에서 정한 보상금을 지급해야 하고, 이행불능을 이유로 보상금 지급을 거부하거나 보상금의 감면을 청구할 수 없다.
- ② 피수용자의 손실과 부담을 최소화하여 완전보상을 실현하기 위하여 인정

03 요건

1) 재결이 있는 후

재결이 있기 전에는 사업시행자에게 위험부담이 이전되지 않는다.

2) 피수용자의 고의나 과실이 없을 것

04 대상에 대한 검토

- ① 목적물의 가격하락의 경우에는 해당되지 않는다.
- ② 목적물에 하자가 숨어 있을 경우도 위험부담의 대상이 되지 않는다.(예. 폐기물 매립)

05 효과

재결 후 수용 또는 사용의 목적물이 사업시행자에게 인도 또는 이전되기 전에 멸실 또는 훼손되었더라도 사업시행자는 재결에서 정한 보상금을 지급하여야 하며, 이행불능을 이유로 보상금의 지급을 거부하거나 보상금의 감면을 청구할 수 없다.

01 물상대위의 의미

담보물권에 있어서는 목적물에 대위하는 가치적 변형물에도 미치는 것이 원칙인데, 이것을 물상대위라 한다.

02 물상대위의 인정 범위 (중요X)

03 보상금에 대한 물상대위

- ① 채무자가 받을 보상금에 대하여 행사할 수 있다.
- ② 다만, 그 보상금이 채무자에게 지급되기 전에 압류하여야 한다(제47조).

04 물상대위의 효력이 미치는 보상의 범위

담보물권의 목적물과 직접적 관련성이 없는 그 밖에 다른 보상금에 대해서는 물상대위의 효력이 미치지 않는다고 보는 것이 타당하다.

CASE

A지방자치단체는 도로사업 부지를 취득하기 위하여 甲의 토지에 대하여는 수용재결에 의하여 소유권을 취득한 후 소유권이전 등기를 마쳤다. 그러나 甲의 토지가 관내의 택지개발예정지구에 포함되자 A지방자치단체는 이 사건 토지가 도로 사업에 더 이상 제공될 수 없는 상황에서 도로사업의 목적 달성이 불가능 하다고 판단하여, 당초 협의취득 및 수용의 목적이 된 해당 도로사업을 폐지하였다. 이에 따라 甲에게 [토지보상법]에 의한 환매권이 발생하였다.

甲이 환매권을 행사할 무렵 환매금액에 관한 A지방자치단체와 甲의 협의가 성립되지 아니하여, A지방자치단체는 환매 대상 토지의 현재가격이 취득일 당시에 비하여 현저히 상승하였음을 들어 환매대금의 증액을 구하는 소송을 제기 하였다.

甲의 환매권 및 환매대금증액청구소송의 법적 성질을 각각 설명하시오.(15점) [35회 문1]

01 의미

공익사업의 폐지·변경 또는 그 밖의 사유로 취득한 토지의 전부 또는 일부가 필요 없게된 경우, 원소유자가 보상금에 상당하는 금액을 사업시행자에게 지급하고 토지를 다시 취득할 수 있는 권리를 말한다.

02 근거

1) 이론적 근거

〈공평의 원칙〉, 〈재산권 보장이념〉, 〈원소유자의 감정 존중〉

2) 실정법적 근거

- ① 헌법으로부터 직접 도출되는 권리라는 견해,
- ② 개별 법령의 근거가 있어야 한다는 견해
- ③ 생각건데 법률에 근거가 있어야 함이 타당하다.

[관련자료] 대법원 및 헌법재판소 입장

- ① 대법원은 개별 법령의 근거가 있어야 한다는 견해이다.
- ② 헌법재판소는 헌법상의 권리로 보고 있다

03 법적 성질

1) 공권설 및 사권설

(1) 문제점

사업인정 전 협의취득은 사권이나, 사업인정 후 취득의 경우는 공권인지 사권인지 대립

(2) 학설

① 공권설

수용 등 공법적 원인에 의해 형성된 법률관계를 전제하므로 공권

② 사권설

환매권자의 이익을 위해 행사하므로 사권

(3) 판례

① 대법원은 사권으로 보며,

② 헌법재판소도 환매권의 발생 여부 또는 그 행사의 가부에 관한 다툼을 사법관계로 보고 있다.

(4) 검토

① 환매권은 공권력 행사의 주체인 사업시행자에게 행사, 공공필요의 소멸 여부의 판단 역시 공익적 판단에서 비롯하므로 공권으로 봄이 타당하다.

② 따라서 당사자소송으로 해결해야 하나, 실무적으로는 민사소송으로 해결하고 있다.

2) 형성권

환매권은 환매기간 내에 환매의 요건이 발생하면 환매권자가 수령한 보상금 상당금액을 사업시행자에게 지급하고 일방적으로 의사표시를 함으로써 사업시행자의 의사에 관계없이 성립되는 <형성권의 일종>으로 보는 것이 타당하다.

3) 물건적 효력설과 채권적 효력설

(1) 문제점

환매권 행사시 물건적 효력이 발생하는지 채권적 효력이 발생하는지 문제된다.

(2) 견해 대립

a. 물건적 효력설

환매는 환매권자의 의사표시만으로 성립하고, 바로 소유권이 환매권자에게 이전된다고 한다.

(소유권이전확인소송의 유형)

b. 채권적 효력설

현재 소유자에 대하여 소유권이전등기청권이 발생할 뿐이고, 현 소유자가 소유권이전등기를 이행해야 소유권이 이전된다고 본다. (소유권이전등기청구소송 또는 소유권이전등기말소청구소송의 유형)

(3) 판례

판례는 환매권 행사는 **채권적 효력**으로서 소유권이전등기청구권이 발생하며, 10년의 소멸시효에 걸린다고 판시했다.

(4) 검토

① 물건적 효력을 인정한다면 등기 없이 소유권이 변동되는 결과가 초래된다.

② 환매권행사에 의하여 소유권이전등기청구권이라는 청구권이 발생하고, 현재 토지소유자의 등기이전이 있어야 소유권이 이전되므로 채권적 효력으로 보는 것이 타당하다.

04 요건

1) 환매권자

- ① 환매권자는 취득일 당시의 토지소유자 또는 포괄승계인
- ② 환매권은 일신전속적인 성격(양도불가)

2) 환매의 상대방

- ① 사업시행자이지만, 토지가 제3자에게 매각되는 경우에는 제3자인 현재의 소유자
- ② 협의취득 또는 수용의 등기가 되었을 때에는 제3자에게 대항할 수 있다고 규정되어 있다.

3) 환매의 목적물

(1) 토지소유권

토지소유권만 인정

(2) 토지 일부에 대해 선택적 행사 불가능

일부만 선택적으로 환매권을 행사할 수는 없다.

(3) 잔여지만의 환매 불가능

잔여지에 접한 일단의 토지가 필요 없게 된 경우가 아니면 원래의 수용 토지를 제외하고 잔여지만을 환매할 수는 없다.

3) 행사요건

(1) 전부 또는 일부가 필요 없게 된 때

a. 환매의 행사요건 (토지보상법 제91조 제1항)

- ① 공익사업의 폐지·변경 또는 그 밖의 사유로 취득한 토지의 전부 또는 일부가 필요 없게 된 경우 환매권자는
- ② 사업의 폐지·변경으로 인한 경우에는 관계 법률에 따라 사업이 폐지·변경된 날, 그 밖의 사유로 인한 경우에는 사업완료일로부터, 10년 이내에 그 토지에 대하여 받은 보상금에 상당하는 금액을 사업시행자에게 지급하고 그 토지를 환매할 수 있다.

b. 구체적인 의미

- ① <폐지·변경> 공익사업을 아예 그만두거나 다른 공익사업으로 바꾸는 것을 말한다
- ② <필요 없게 된 때>란 취득 목적사업을 위해 취득한 토지가 사용할 필요 자체가 없어진 경우를 말하며, 필요 없게 되었는지는 사업시행자의 주관적인 의사를 표준으로 하는 것이 아니라 객관적·합리적으로 판단해야 한다.

(2) 전부를 이용하지 않을 때

a. 토지보상법 제91조 제2항 규정

취득일부터 5년 이내에 취득한 토지의 전부를 해당 사업에 이용하지 아니하였을 때에는 취득일부터 6년 이내에 그 토지에 대하여 받은 보상금 상당 금액을 사업시행자에게 지급하고 그 토지를 환매할 수 있다.

b. 구체적인 의미

- ① <전부>란 사업시행자가 취득한 토지의 전부를 기준으로 판단
- ② <이용하지 아니하였을 때>란 단지 사실상 사업에 제공되지 않은 경우

(3) 각 요건의 관계

각각 독립적이므로 어느 요건에만 충족되면 환매권 행사 가능

05 환매금액

1) 지급받은 보상금 상당금액

환매금액은 “그 토지에 대하여 받은 보상금에 상당하는 금액”이다.

2) 토지가격이 취득일 당시에 비해 현저히 변동된 경우

(1) 의미

- ① <환매권 행사 당시의 토지가격>이 지급한 보상금에 환매 당시까지의 해당 사업과 관계없는 인근 유사토지의 지가변동률을 곱한 금액보다 높은 경우로 한다(령 제48조).
- ② <대법원>은 이 경우 환매가격은 보상금에다 환매 대상 토지의 환매 당시의 감정평가금액에서 보상금에 인근 유사토지의 지가변동률을 곱한 금액을 공제한 금액을 더한 금액이다.

(2) 금액의 협의 및 협의불성립 시 법원에 청구

토지의 가격이 취득일 당시에 비하여 현저히 변동된 경우, 사업시행자와 환매권자는 환매금액에 대하여 서로 협의하되, 협의가 성립되지 아니하면 그 금액의 증감을 법원에 청구할 수 있다(제91조 제4항).

(3) 소송으로 증액청구

판례는 환매는 수용의 해제가 아니라 사법상의 행위라고 보아 금액 증감의 청구는 <민사소송>으로 해야 한다고 본다.

06 절차와 방법

1) 환매통지·공고

(1) 사업시행자의 환매권 통지 의무

- ① 사업시행자는 환매할 토지가 생겼을 때에는 지체 없이 그 사실을 환매권자에게 통지하여야 하고, 과실 없이 환매권자를 알 수 없을 때에는 공고하여야 한다
- ② 판례는 환매권 통지규정이 법적인 의무라고 한다.
- ③ 사업시행자의 환매통지는 일종의 최고에 불과하기 때문에, 환매통지가 없는 경우라도 환매요건이 발생하면 환매권자는 환매권을 행사할 수 있다.

(2) 통지의무 위반으로 환매권 행사기간이 도과한 경우

a. 학설 및 판례

판례는 사업시행자가 통지·공고를 하지 않아 환매권 행사가 불가능하게 되어 환매권을 상실하게 하는 손해를 가한 때에는 **불법행위**를 구성한다고 판시하고 있다.

b. 검토

환매권의 통지 의무는 법적의무이고, 환매권의 의의 및 기능을 감안할 때, 이를 위반한 것은 불법행위로 평가함이 타당하다.

2) 환매의 협의

- ① 환매권자의 환매에 대한 의사표시가 있게 되면 서로 협의하여야 하고, 환매권자가 협의에서 정해진 환매가격을 지급함으로써 환매가 성립한다.
- ② 헌법재판소는 환매권의 행사는 **형성권**의 행사로서 사업시행자의 동의를 얻어야 하거나 의사여하에 따라 효과가 좌우되는 것이 아니라 한다.

3) 환매권의 행사방법 및 행사의 효력발생 시점

- ① 사업시행자의 환매통지(의무)
- ② 이에 대해 환매권자가 환매의 의사표시를 하면 환매계약이 성립
- ③ 대법원은 환매 의사표시가 상대방에게 도달한 때 환매권 행사의 효력이 발생한다고 본다.

07 환매권 행사의 효과

1) 환매권의 효과에 대한 견해대립

〈판례〉는 환매권 행사의 효과를 **채권적 효과**로 보아, 사법상 매매계약의 효력이 생기는 것으로 보면서 소유권이전등기 청구권이 발생하고, 이 청구권은 10년을 시효로 소멸한다고 한다.

2) 대항력

협의취득 또는 수용의 등기가 되었을 때에는 제3자에게 대항할 수 있다.

08 환매권의 소멸

1) 사업시행자의 통지나 공고가 있는 경우

환매권은 통지를 받은 날 또는 공고한 날로부터 6월의 기간이 경과함으로써 소멸하게 된다(제92조 제2항).

2) 사업시행자의 통지나 공고가 없는 경우

토지보상법 제91조 제1, 2항에서 정한 기간에 환매권을 행사하지 않으면 환매권은 소멸한다.

09 환매권에 대한 다툼

1) 행사요건에 관한 다툼

- ① 환매권을 공권으로 보면 공법상 당사자소송
- ② 환매권을 사권으로 보면 민사소송(소유권이전(말소)등기청구소송)

2) 환매금액에 관한 다툼 (제91조 제4항)

토지의 가격이 취득일 당시에 비하여 현저히 변동된 경우 사업시행자와 환매권자는 환매금액에 대하여 서로 협의하되, 협의가 성립되지 아니하면 그 금액의 증감을 법원에 청구할 수 있다.

10 환매금액 증감 소송

1) 문제점

견해의 대립이 있다.

2) 학설

(1) 민사소송이라는 견해

(2) 행정소송이라는 견해

(3) 검토

- ① 사업인정 전 협의취득은 사법상 매매계약으로 보므로 민사소송
- ② 그러나 사업인정 후 협의취득이나 수용재결에 의한 취득은 공법적 원인에 의해 소유권을 취득한 것이므로, 공권으로 보아 공법상 당사자소송

CASE

A시는 X초등학교의 수용시설이 열악하다고 판단하고, 인근에 Y초등학교의 건립을 위한 사업인정과 재결을 거쳐 해당 부지(甲 소유의 토지)를 취득하였다. 2년 후, A시는 인근의 다른 택지(아파트 단지 예정)에 새 초등학교부지가 있다는 사실을 알고, 아파트건설 사업을 하던 제3자인 B회사와 그 아파트 단지 내에 들어설 새 초등학교 부지와 이 학교용지를 교환하였다. 이 사실을 알게된 甲은 당초 사업이 폐지, 변경되었으므로 환매권을 행사하였다. 이에 A시는 B회사와 교환한 당초 초등학교 부지를 중학교부지로 변경하는 도시관리계획을 결정, 고시하면서 당초 토지는 초등학교에서 중학교부지로 공익사업이 변경되었으므로 환매권 행사가 제한된다고 주장한다. A시의 주장은 타당한가?

1) 의의 및 취지 (토지보상법 제91조 제6항)

- ① 공익사업변환이란 공익사업의 토지취득 후 다른 공익사업으로 변경된 경우 별도의 취득절차 없이 다른 공익사업에 이용하도록 하는 제도이다.
- ② 무용한 절차의 반복을 방지하기 위한 제도

2) 요건

	변경 전	변경 후
사업시행자	국가, 지자체, 공공기관	요건 없음 사업시행자가 바뀐 경우에도 인정(判)
공익사업	-	토지보상법 4조 1호~5호
사업인정여부	O	O (判)
처분	제3자에게 처분되지 않을 것(判)	

3) 기산일 규정의 해석

환매권 행사기간은 당해 공익사업 변경을 **관보에 고시한 날**로부터 기산한다는 의미로 해석해야 한다.

4) 사업시행자의 동일성 문제

(1) 문제점

공익사업 변환이 사업시행자가 동일한 경우에만 인정될 수 있는 것인지 문제된다.

(2) 견해 대립

(3) 대법원

사업시행자가 동일한 경우에만 허용되는 것은 아니라 한다.

(4) 검토

예외적 규정은 좁게 해석함이 국민의 권리구제에 유리하다.

5) 변환의 효과

변경된 공익사업의 내용을 관보에 고시한 때부터 환매권 행사기간을 다시 기산하여 환매권 행사기간이 연장되는 효과가 발생하게 된다.

6) 제도의 위헌성

(1) 문제점

헌법상 보장된 환매권을 법률로 제한하는지 문제된다.

(2) 합헌설

피해최소성의 원칙 및 법익균형의 원칙에도 부합된다 할 것이므로 기본권 제한에 관한 과잉금지원칙에 위배되지 아니한다고 한다.(헌재입장)

(3) 위헌설

행정편의만을 중시한 일방적인 것이며, 비례의 원칙에도 위배될 뿐만 아니라 환매권의 본질적인 내용을 침해하는 제한으로 위헌의 소지가 있다고 한다.

(4) 검토

- ① 위헌설 : 환매권을 본질적으로 침해하는 제한
- ② 합헌설: 위헌은 아니나, 예외적인 경우에 허용되어야 한다.

CASE

토지수용의 재결에 대한 불복을 논하라. [3회 문1]

제1절

개설

01 재결의 불복

불복대상	수용재결 자체를 다투는 것	보상금의 증감을 청구하는 것
불복방법	제83조 : 이의신청 제85조 제1항 : 취소소송 또는 무효확인소송	제83조 : 이의신청 제85조 제2항 : 보상금증감청구소송

02 수용재결 전치주의

1) 문제점

수용재결을 거치지 않고 곧바로 행정소송을 제기할 수 있는지 문제된다.

2) 수용재결 전치주의의 개념

수용재결전치주의는 행정소송을 제기하기 앞서 토지수용위원회의 재결을 반드시 거쳐야 하는 것을 의미한다.

3) 토지보상법 제85조 제1항 태도

“재결에 불복할 때 행정소송을 제기할 수 있다”고 규정하여, 수용재결 전치주의를 취한 것으로 볼 수 있다.

4) 관련 판례

판례 역시 토지보상법 제85조의 행정소송을 제기하기 위해서는 규정 문언상 수용재결을 반드시 거쳐야 한다고 판단하였다.

CASE

토지소유자 甲은 “사업시행자인 B구청장이 도로개설공사를 시행하면서 사업인정고시가 된 2010. 4. 6. 이후 3년 이상 이 사건 토지를 사용하였다”고 주장하면서 토지보상법 제72조제1호를 근거로 이 사건 토지의 수용을 청구하였다.

이에 대해 A광역시지방법토지수용위원회는 “사업인정고시가 된 날부터 1년 이내에 B구청장이 재결신청을 하지 아니하여 사업인정은 그 효력을 상실하였으므로 甲은 토지수용법 제72조제1호를 근거로 이 사건 토지의 수용을 청구할 수 없다”며 甲의 수용청구를 각하하는 재결을 하였다.

A광역시지방법토지수용위원회의 각하재결에 대하여 행정소송을 제기하기 전에 강구할 수 있는 甲의 권리구제수단에 관하여 설명하시오.

01 의의 및 성격 (특별법상 행정심판, 임의전치주의)

- ① 관할토지수용위원회의 위법부당한 재결에 불복이 있는 토지소유자 및 사업시행자가 중앙토지수용위원회에 이의를 신청하는 것으로서 **특별법상 행정심판**에 해당한다.
- ② 토지보상법 제 83조에서 <~할 수 있다>고 규정하여 **임의주의적 성격**을 갖는다.

02 요건

- ① 중앙토지수용위원회의 재결에 이의가 있는 자 : 중앙토지수용위원회에 이의신청
- ② 지방토지수용위원회의 재결에 이의가 있는 자 : 해당 지방토지수용위원회를 거쳐 중앙토지수용위원회에 이의신청(처분청 경유주의)

03 이의신청에 대한 재결 (제84조)

- ① 중앙토지수용위원회는 수용재결이 위법 또는 부당하다고 인정할 때에는 그 재결의 전부 또는 일부를 취소하거나 보상액을 변경할 수 있다.(감액재결 가능)
- ② 보상금이 늘어난 경우 재결서 정본을 받은 날로부터 30일 이내에 사업시행자는 증액된 보상금을 지급 또는 공탁해야 한다.

04 재결의 효력

- ① 이의재결의 확정시 민사소송법상의 확정판결이 있는 것으로 본다.
- ② 이의신청은 사업의 진행 및 토지의 사용·수용을 정지시키지 아니한다.(집행부정지)(제88조)

05 대상

- ① 이의신청의 대상은 토지수용위원회의 제34조에 따른 재결이다.
- ② 수용재결과 보상재결 중 한 부분만에 대하여 불복이 있는 경우에도 토지수용위원회의 재결 자체가 이의신청의 대상이 된다.

01 취소소송

1) 의의 및 행정심판의 임의적 전치주의

2) 소송의 대상

(1) 취소소송의 대상(원처분주의와 재결주의)

이의재결에 불복하여 취소소송을 제기하는 경우 소송의 대상이 수용재결인지 이의재결인지가 문제된다.

(2) 토지보상법의 규정내용

제34조에 따른 재결에 불복할 때에는, 행정소송을 제기할 수 있다고 규정하고 있다(제85조 제1항).

(3) 판례

대법원은 수용재결에 불복하여 취소소송을 제기하는 때에는 이의신청을 거친 경우에도 수용재결의 취소를 구하여야 한다는 **원처분주의**를 취하고 있다.

(4) 검토

- ① 현행 토지보상법은 <제34조에 따른 재결에 불복할 때>라고 규정하여, 행정소송법상 원칙대로 원처분주의를 명확히 규정
- ② 다만, 이의재결 자체의 고유한 위법이 있을 경우에는 중앙토지수용위원회를 상대로 이의재결의 취소를 구할 수 있다.

3) 행정심판(이의신청) 임의주의

4) 취소소송의 피고

5) 제소기간 (제85조 제1항)

재결서를 받은 날부터 90일 이내에, 이의신청을 거쳤을 때에는 이의신청에 대한 재결서를 받은 날부터 60일 이내에 각각 행정소송을 제기해야 한다.

6) 제소 효과

(1) 법원에 대한 효과

법원은 심리·판결할 의무

(2) 처분에 대한 효과

집행부정지원칙

7) 심리

8) 판결

9) 관련 문제

(1) 확정판결의 집행력

(2) 사업시행자의 법정이율 가산지급

사업시행자가 제기한 행정소송이 각하·기각 또는 취하된 경우 법정이율을 적용하여 산정한 금액을 보상금에 가산하여 지급하여야 한다.

02 무효등확인소송

1) 의의

무효등확인소송이란 관할 토지수용위원회의 재결 또는 이의재결의 효력유무 또는 존재여부를 확인하는 소송이다.

2) 무효등확인소송의 인정

흠이 중대명백한 경우

3) 취소소송에 관한 사항의 일부 적용배제

행정심판 필요적 전치, 제소기간의 제한이 적용되지 않는다.

03 보상금증감청구소송

CASE

토지소유자 甲은 위 토지수용위원회의 재결에 불복하여 공익사업법에 따라 보상금의 증액을 구하는 소송을 제기하고자 한다. 이 소송의 의의와 그 특수성을 설명하시오.[26회 문1]

1) 의의 및 취지등

수용재결 중 보상금에 대하여서만 이의가 있는 경우에 보상금의 증액 또는 감액을 청구하는 소송이다.

2) 소송의 성질

(1) 형식적 당사자소송

재결청을 피고로 하는 것이 아니라 그 법률관계의 일방 당사자를 피고로 하는 소송에 해당하게 되므로 형식적 당사자소송이다.

(2) 소송의 법적 성질

a. 학설

① 형성소송설

실질적으로는 보상액의 취소·변경을 구하는 항고소송

② 확인·금부소송설

법원은 정당보상액을 직접 확인·금부하는 것에 대한 판단이면 충분

b. 검토

분쟁을 일회적으로 해결하도록 한 취지 등을 고려할 때, 〈확인·급부소송〉

3) 소송의 대상

- ① 재결로 형성된 법률관계인 보상금의 증감에 관한 것을 소송의 대상으로 삼아야 하며 보상금의 증감에 관한 사항 외에는 소송의 대상이 될 수 없다.
- ② 〈원재결로 형성된 법률관계인 보상금의 증감〉에 관한 것을 소송의 대상으로 삼아야 한다.

4) 소제기의 요건

재결서를 받은 날로부터 90일 이내에, 이의신청을 거친 경우에는 이의재결서를 받은 날로부터 60일 이내에 피고의 소재지를 관할하는 행정법원 또는 토지 소재지 관할 행정법원에 소송을 제기할 수 있다(제85조 제1항, 제2항).

5) 심리 및 판결

(1) 소송의 범위

a. 문제점

보상금증감청구소송의 범위에 잔여지수용청구에 관한 것까지 포함할 것인지 문제

b. 학설

① 긍정설

손실의 범위와 보상의 금액은 밀접한 관련을 지닌다.

② 부정설

잔여지수용은 수용의 범위와 관련된 것이며, 수용거부결정은 '처분'이므로 수용재결 자체를 다투어야 한다고 본다.

c. 판례

잔여지 수용청구권은 〈형성권적 성질〉을 가지므로, 잔여지 수용청구를 받아들이지 아니한 토지수용위원회의 재결에 대하여 '보상금의 증감에 관한 소송'을 제기해야 한다고 판시

d. 검토

잔여지 수용청구 등 보상의 원인인 손실범위는 보상금액과 밀접한 관련이 있다.(긍정)

(2) 입증책임

(3) 보상항목간의 유용

a. 문제점

보상항목 상호 간의 유용이 허용되는지 문제

b. 견해대립

c. 판례

항목 상호간의 유용을 허용하여 과다 부분과 과소 부분을 합산하여 보상금의 합계액을 결정하여야 한다.

d. 검토

개인별 총액으로서 보상액의 당부를 소송물로 보아 항목간 유용을 허용함이 합리적일 것이다.

(4) 보상대상 판단 (사업시행자 또는 토지수용위원회가 보상대상을 부정하는 경우)

피보상자는 관할 토지수용위원회를 상대로 그 재결에 대한 취소소송을 제기할 것이 아니라, 사업시행자를 상대로 제85조 제2항에 따른 보상금증감청구소송을 제기하여야 한다.

(5) 판결의 효력

법원은 스스로 보상액의 증감을 결정할 수 있고 토지수용위원회는 별도의 처분을 할 필요가 없다.

6) 청구의 병합

수용재결에 대한 취소소송에서 보상금증액청구소송을 예비적으로 병합하여 제기할 수 있다고 보는 것이 타당

제1절

토지수용위원회

CASE

공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률상 토지수용위원회에 대하여 설명하시오.

01 개설

토지수용위원회는 사업시행자와 토지소유자 또는 관계인과의 사이에서 수용이나 손실보상에 관한 다툼을 당사자가 주장하는 바에 따라 공정*중립의 입장에서 판단하고, 이를 최종적으로 재결하는 준사법적 행정기관이다.

02 성격

- 1) 독립된 행정기관
- 2) 합의제 행정기관
- 3) 준사법적 행정기관
- 4) 독립성 및 전문성 인정

03 설치와 구성

- 1) 위원회의 설치
- 2) 구성

04 관할

1) 관할의 의의 및 구분(범위)

(1) 관할의 의의

(2) 관할의 구분

- ① 중앙토지수용위원회 : 국가 또는 시·도가 사업시행자인 사업, 수용하거나 사용할 토지가 둘 이상의 시·도에 걸쳐 있는 사업
- ② 지방토지수용위원회 : 중앙토지수용위원회 이외의 사업의 재결(시·도 해당 관할의 사업)

2) 관할 범위내 재결의 종류

- ① 중앙토지수용위원회는 관할 범위내 재결과, 1차적 재결에 대한 불복으로서 이의재결을 담당한다.
- ② 지방토지수용위원회는 관할 범위내 재결만 담당한다.

05 재결사항 (토지보상법 제50조 제1항)

- ① 수용하거나 사용할 토지의 구역 및 사용방법
- ② 손실보상
- ③ 수용 또는 사용의 개시일과 기간
- ④ 그 밖에 이 법 및 다른 법률에서 규정한 사항

CASE

토지보상법상 보상협의회에 대하여 설명하시오.

01 개설

토지보상법은 주민의 의견수렴과 민원 해소를 위하여 보상협의회를 설치·운영하도록 하고 있다.

02 의의 및 성격 등 (토지보상법 제82조)

1) 의의 및 취지

- ① 보상업무에 관한 사항을 협의하기 위해서 시·군·구에 설치하는 합의제 행정기관이다.
- ② 보상업무의 지연 초래를 방지하기 위함

2) 성격

(1) 자문기관인지 여부

위원회가 보상업무에 대해 단순히 자문하는 기능을 갖는 것에 불과

(2) 임의적 및 의무적 보상협의회

a. 의무적 보상협의회

b. 임의적 보상협의회

03 협의 사항 (협의회의 기능)

PART 02

손실보상

Chapter 01 손실보상 일반론

Chapter 02 토지보상법상 손실보상 기준

Chapter 03 손실보상의 내용

Chapter 04 손실보상액의 산정과 평가각론

제1절 손실보상 개요

01 의의 및 취지

행정상 손실보상이란 공공필요에 의한 적법한 공권력 행사로 인하여 개인의 재산권에 가해진 특별한 희생에 대하여, 사유재산권 보장과 공평부담의 차원에서 행정주체가 행하는 조절적인 재산적 보상을 말한다.

02 근거

1) 이론적 근거

특별희생설, 공평부담

2) 실정법적 근거

(1) 헌법적 근거

헌법 제23조 제3항은 “공공필요에 의한 재산권의 수용·사용 또는 제한 및 그에 대한 보상은 법률로써 하되, 정당한 보상을 지급하여야 한다.”고 하여 재산권의 제한과 보상에 대한 일반원칙을 규정하고 있다.

(2) 법률상 근거

일반법 없음. 각 개별법에서 규정

03 손실보상청구권의 성질

1) 문제점

2) 견해 대립

(1) 공권설

- ① 원인행위가 공법적
- ② 공법상 당사자소송

(2) 사권설

- ① 보상은 사법상 채권·채무관계
- ② 민사소송

3) 대법원 입장

- ① 대법원은 전통적으로 사권설의 입장
- ② 그러나 최근 전원합의체 판결에서 [하천법]상의 손실보상청구권을 공권으로 보아 판례 변경
- ③ 그 외 토지보상법상 손실보상청구권도 공법상 권리로 보고 있다.

4) 검토

공법상 원인이므로 공권으로 봄이 타당

[헌법] 제23조

- ① 모든 국민의 재산권은 보장된다. 그 내용과 한계는 법률로 정한다.
- ② 재산권의 행사는 공공복리에 적합하도록 하여야 한다.
- ③ 공공필요에 의한 재산권의 수용·사용 또는 제한 및 그에 대한 보상은 법률로써 하되, 정당한 보상을 지급하여야 한다.

01 존속보장과 가치보장**CASE**

재산권 가치보장과 존속보장에 관하여 서술하십시오.[17회 문4번]

1) 존속보장**(1) 의의**

존속보장이란 재산권자가 재산권을 보유하고 향유(사용, 수익, 처분)하는 것을 보장하는 것을 말한다.

(2) 헌법적 근거 및 내용과 한계

헌법은 재산권은 보장하되, 그 내용과 한계는 법률로 정하는 것으로 규정하고 있다.

(3) 존속보장 실현제도

공용침해에서의 공공필요 요건, 환매제도, 분리이론, 위법한 재산권 침해행위에 대한 취소소송 등이 있다.

2) 가치보장**(1) 의의**

가치보장이란 공공필요에 의해 재산권에 대한 공권적 침해가 행해지는 경우 재산권의 가치를 보장하기 위해 보상 등으로 가치보장조치를 취하는 것을 말한다.

(2) 헌법적 근거 및 내용과 한계

헌법 제23조 제3항은 공용침해시 정당보상 의무를 규정하고 있다.

(3) 손실보상의 요건

① 공공필요에 의해 ② 적법한 공권력에 의해 ③ 재산권에 침해가 있고 ④ 이로 인하여 특별한 희생이 발생하여야 하며 ⑤ 손실보상규정이 존재해야 한다.

3) 존속보장과 가치보장의 관계

공용수용시 재산권의 존속보장은 가치보장으로 전환된다.

CASE

손실보상에 있어서 사회적 제약과 특별한 희생의 구별기준에 관하여 경계이론과 분리이론의 입장을 설명하시오.
[14회 문2번]

1) 헌법 제23조의 내용

현실적으로 재산권에 대한 어떠한 제한이 사회적 제약인지 특별한 희생인지 구별이 쉽지 않다.

2) 경계이론

(1) 의의

양자는 <재산권 침해의 정도>에 따라 경계 지어진 것에 불과하다고 보는 견해이다.

(2) 사회적 제약과 특별한 희생의 구분

사회적 제약의 재산권 침해가 일정 정도를 넘어서게 되면 특별한 희생으로 전환

(3) 재산권의 가치보장에 중점

특별한 희생이 발생하면 보상규정의 유무를 불문하고 보상이 따라야 한다고 본다.

3) 분리이론

(1) 의의

양자를 서로 독립된 제도로 보아, 양자를 재산권 제한의 정도가 아니라 <입법의 형식과 목적>에 의해 구분한다.

(2) 위헌심사기준

- ① 재산권의 내용규정(사회적 제약)은 비례의 원칙, 평등의 원칙 등을 기준으로 위헌여부를 판단
- ② 공용침해규정은 헌법 제23조 제3항이 정하고 있는 요건만을 기준으로 판단

(3) 사회적 제약이 수인한계를 넘으면 위헌성

사회적 제약이 한도를 넘으면 비례의 원칙, 평등의 원칙 위반으로 위헌이 된다.

(4) 재산권의 존속보장에 중점

재산권에 대한 위헌적 침해 자체를 배척

4) 판례의 입장

(1) 대법원

종래 우리 대법원은 경계이론의 입장이라고 보았으나, 최근에는 분리이론을 따르고 있다는 견해도 제기되고 있다.

(2) 헌법재판소

- ① 사회적 제약을 넘는 가혹한 부담을 가져오는 예외적인 경우에는 보상규정을 두지 않은 것이 비례원칙에 위반되어 위헌이라고 헌법불합치결정을 한 바 있다.
- ② 재산권 침해와 공익간의 비례성을 다시 회복하기 위해서 보상규정을 두어야 하고, 반드시 금전보상을 해야 하는 것은 아니고 토지매수청구권과 같은 방법도 사용할 수 있다고 판시하였다.

03 헌법 제23조 제3항이 불가분 조항인지

1) 의의 및 기능

불가분조항이란 공용침해의 근거규정과 이에 대한 손실보상규정이 하나의 법률로 규정되어야 하고, 서로 불가분의 관계를 형성하고 있어야 한다는 것이다.

2) 우리 헌법상 인정여부

(1) 학설

긍정설, 부정설 대립

(2) 판례

불가분조항으로 보고 있는 입장

(3) 검토

헌법 제23조 제3항은 불가분조항으로 봄이 타당

CASE

甲은 하천부지에 임시창고를 설치하기 위하여 관할청에 하천점용허가를 신청하였다. 이에 관할청은 허가기간 만료 시에 위 창고건물을 철거하여 원상복구할 것을 조건으로 이를 허가하였다. 甲은 창고건물철거에 따른 손실보상을 청구할 수 있는지 검토하시오.[20회 문2번]

01 서**02** 공공필요

1) 개념

전형적인 불확정개념

2) 공공필요의 판단

공용침해를 통해 얻게 되는 공익 > 재산권을 침해당하는 사인의 이익

3) 공공성의 확대화 경향

03 공권력에 의한 적법한 침해

1) 공권적 침해

공권력 주체에 의하여 직접적으로 의도된 재산권에 대한 침해가 있어야 한다.

2) 적법한 침해

법률에 근거한 적법한 침해를 의미한다.

04 재산권에 대한 침해

- ① 재산권이란 소유권 뿐만 아니라 법에 의하여 보호되고 있는 재산적 가치가 있는 일체의 권리를 의미한다.
- ② 현존하는 것만, 기대이익은 불포함

05 특별한 희생

1) 의의 및 문제점

- ① 특별한 희생이 발생해야 한다.
- ② 사회적 제약과 특별한 희생의 구분이 문제된다.

2) 학설

(1) 형식적 기준설

침해행위의 <인적범위를 특정할 수 있는지 여부>를 기준으로 판단한다.

(2) 실질적 기준설

a. 의의

침해하는 행위의 실질적 내용(침해의 본질성 및 강도)에 따라 구분

b. 종류

- ① 보호가치가 있는 재산권에 대한 침해만을 보상을 요하는 특별한 희생으로 보는 보호가치성설,
- ② 재산권의 본질인 배타적 지배를 침해한 것은 수인 한도를 넘는 것으로 특별한 희생에 해당한다고 보는 수인한도설,
- ③ 재산권의 침해가 종래 재산권의 이용목적을 침해하는 경우에 특별한 희생으로 보는 목적위배설,
- ④ 재산권의 사적 효용을 본질적으로 침해하는 경우에는 특별한 희생에 해당한다고 보는 사적효용설,
- ⑤ 재산권마다 그 위치나 상황이 다를 수 있으므로 보상 여부 결정에 있어서도 구체적인 상황을 고려하여야 한다는 상황구속성설,
- ⑥ 재산권 침해의 중대성과 정도를 기준으로 특별희생인지를 판단하는 중대성설 등이 있다.

3) 판례

(1) 대법원

(구)도시계획법상 개발제한구역지정으로 인한 토지소유자의 재산권행사의 제한은 사회적 제약에 불과하다고 보았다.

(2) 헌법재판소

- ① 개발제한구역 지정으로 인한 개발가능성 소멸과 그에 따른 지가하락은 토지소유자가 감수해야 하는 사회적 제약이라고 판시하였다.
- ② 그러나 토지를 종래의 목적으로도 사용할 수 없거나 실질적으로 토지의 사용·수익의 길이 없는 경우 등 사회적 제약의 한계를 넘는 가혹한 부담이 발생하는 예외적인 경우에도 보상규정을 두지 않은 것은 비례의 원칙에 위반되어 헌법에 위반된다고 판시하였다.

4) 검토 (복수기준설)

양 기준을 종합하여야 한다.

CASE

甲은 A도내 일정지역에서 20년 이상 제조업을 운영하여 왔다. A도지사는 (가칭) 청정자연 보호구역의 지정 및 관리에 관한 법률을 근거로 甲의 공장이 포함되는 B지역 일대를 청정자연보호구역으로 지정하였다. 그 결과 B지역 내의 모든 제조업자들은 법령상 강화된 폐수 배출허용기준을 준수하여야 한다. 이에 대해 甲은 변경된 기준을 준수하는 것이 기술적으로 어려울 뿐만 아니라, 수질정화시설을 갖추는 데 과도한 비용이 소요되므로, 이는 재산권의 수용에 해당하는 것으로 손실보상이 주어져야 한다고 주장한다.

甲재산권의 규제에 대한 보상규정이 위 법률에 결여되어 있는 경우 甲주장의 타당성을 검토하시오.[18회 문1번 변형]

1) 문제점

개별법률에서 손실보상규정을 두지 않은 경우, 헌법 제23조 제3항의 규정만으로 손실보상을 청구할 수 있는지가 문제된다.

2) 학설 [직방위보유]

(1) 직접효력설

(2) 방침규정설

(3) 위헌무효설

(4) 보상입법부작위 위헌설

(5) 유추적용설

3) 판례

(1) 대법원

최근 대법원은 유추적용설 입장

(2) 헌법재판소

개발제한구역 지정으로 토지소유자에게 사회적 제약의 범위를 넘는 가혹한 부담이 발생하는 예외적인 경우에도 보상규정을 두지 않은 것은 위헌성이 있는 것이고, 보상의 구체적인 기준과 방법은 입법자가 정할 사항이라고 판시하였다. 이는 위헌무효설을 취한 것으로 평가되기도 한다.

4) 검토

국민의 권리구제의 실효성을 위하여 <직접효력설>이 타당

※ 보충자료 - 그 밖의 손실보상이론

1. 수용유사침해이론

<위법한> 공용침해로 인하여 특별한 희생을 입은 자에 대하여 그 근거법령에 보상규정이 없는 경우에도 수용에 준하여 그 손실을 보상해 주어야 한다는 이론을 말한다.

2. 수용적 침해이론

수용적 침해란 적법한 공권력 행사의 비정형적이고 비의도적인 부수적 효과로서 발생한 개인의 재산권 손실에 대하여 손실보상을 인정하자는 이론이다.

01 서

02 사업시행자 보상 원칙 (제61조)

03 사전보상의 원칙 (제62조)

04 현금보상의 원칙 (제63조)

05 개인별 보상의 원칙 (제64조)

06 일괄보상의 원칙 (제65조)

07 사업시행 이익과의 상계금지원칙 (제66조)

08 시가보상의 원칙 (제67조 제1항)

09 개발이익 배제의 원칙 (제67조 제2항)

CASE

채권보상에 대하여 서술하시오. [3회 문3번]

01 개설**02** 의의 및 취지

- ① 채권보상이란 보상금 지급시 일정한 경우 채권으로 지급하는 것이다.
- ② 사업시행자의 자금 확보를 지원하고자 하는 제도이다.

03 채권보상제도의 위헌성 여부

1) 문제점

채권보상이 보상의 시기*방법에 제한을 두어 위헌인지 문제된다.

2) 학설

(1) 위헌설

- ① 보상의 시거나 방법에 제한
- ② 비례의 원칙에 위배

(2) 합헌설

통상적인 수익만 보장되고 유동성이 확보된다면 정당보상에 해당

3) 검토

채권보상에 의하더라도 정당보상의 수준이 될 수 있도록 상환기간, 이자율을 명확히 정하고 있음(합헌)

CASE

택지개발사업이 시행되는 지역에 농지 4,000㎡를 소유하고 있던 甲은 보상금으로 사업주변지역에서 같은 면적의 농지를 대토하고자 하였다. 이 지역의 농지가격수준은 사업이 시행되기 이전만 하더라도 주변지역과 같게 형성되고 있었다. 그러나 해당 사업으로 인해 주변지역의 지가가 상승하여 甲은 보상금으로 3,000㎡밖에 매입할 수 없었다. (40점)

- 1) 甲이 받은 보상은 정당보상에 해당한다고 볼 수 있는가 (20점)
- 2) 甲과 사업주변지역 토지소유자와의 불공평관계에서 나타나는 문제점과 개선대책은 (20점) [9회 1번]

01 의의 및 취지 (토지보상법 제63조 제1항)

- ① 대토보상이란 공익사업으로 조성된 토지로 보상받을 수 있는 제도를 말한다.
- ② 사업시행자의 손실보상금의 부담을 경감하고, 토지구입 수요를 줄임으로써 인근지역 부동산 가격의 상승을 억제할 수 있으며 토지소유자가 개발혜택을 일정 부분 공유할 수 있도록 하는 기능을 갖는 제도이다.
- ③ 대토보상은 현물보상의 하나로 유사토지 구입의 어려움을 해소해 주는 기능도 한다.

02 토지로 보상받을 수 있는 자

03 대토보상의 내용

제1절

정당보상

01 헌법상 기준

CASE

토지보상법 제70조에 따라 취득한 토지의 보상액을 공시지가 기준으로 산정하는 것이 정당보상 원칙에 부합하는지 논하시오. [12회 문2 변형]

1) 정당보상

(1) 문제점

〈정당한 보상〉이 무엇을 의미하는가에 관하여 학설상 견해의 대립

(2) 견해 대립

a. 완전보상설

- ① 공용침해로 인하여 발생한 객관적 손실 전부
- ② 객관적 가치의 보상과 함께 부대적 손실의 보상도 포함하는 것으로 이해
- ③ 오늘날에서는 〈생활보상〉도 포함시키고자 하는 견해가 새롭게 제기
- ④ 단, 정신적 손해와 개발이익은 불포함

b. 상당보상설

- ① 재산권의 재산권의 공공복리 적합의무의 관점에서 공·사익을 형량하여 보상내용이 결정되어야 한다는 견해이다.
- ② 원칙은 완전보상, 합리적인 이유가 있으면 완전보상 하회도 가능

c. 절충설

상황에 따라 완전보상 또는 상당보상 가능

(3) 판례

- ① <대법원>은 보상의 시기·방법 등에 어떠한 제한도 없는 완전한 보상을 의미한다고 하였다.
- ② <헌법재판소>는 원칙적으로 피수용재산의 객관적인 재산가치를 완전하게 보상하는 것이어야 한다는 완전보상을 뜻하는 것으로서, 보상금액 뿐만 아니라 보상의 시기나 방법 등에 있어서도 어떠한 제한을 두어서는 아니 된다는 것을 의미한다고 하였다.(헌재 1990. 6. 25. 89헌마107)

(4) 검토

피침해자의 재산적 가치를 완전하게 보상하는 완전보상설이 타당

2) 정당보상 의미의 확대

최근 사회복리국가 이념이 도입됨에 따라 생활보상도 포함해야 한다는 주장이 일반화되고 있다.

01 객관적 기준평가**02** 현실적인 이용상황 기준 감정평가

1) 원칙 (제70조 제2항)

토지에 대한 보상액은 가격시점에서의 현실적인 이용상황과 일반적 이용방법에 의한 객관적 상황을 고려하되, 일시적인 이용상황과 토지소유자나 관계인이 갖는 주관적 가치 및 특별한 용도에 사용할 것을 전제로 한 경우 등은 고려하지 아니한다.

2) 현실적인 이용상황의 의미

3) 예외

(1) 현황평가 예외의 정당성

(2) 일시적인 이용상황

(3) 무허가건축물 등의 부지, 불법형질변경 토지

종전의 이용상황을 기준

(4) 미지급용지

종전 공익사업에 편입될 당시의 이용상황을 상정하여 평가한다.

03 개별 감정평가**04** 건축물 등이 없는 상태 기준

건부감가를 고려X

05 해당 공익사업으로 인한 가격변동 배제**06** 공시지가기준 감정평가

01 개설

공시지가를 기준으로 보상액을 산정

02 공시지가의 선정

1) 사업인정 전 협의취득의 경우

공시지가는 해당 토지의 가격시점 당시 공시된 공시지가 중 가격시점과 가장 가까운 시점에 공시된 공시지가로 한다(제70조 제3항).

2) 사업인정 후 취득의 경우

(1) 기준, 취지

사업인정 후 취득의 경우 공시지가는 사업인정고시일 전의 시점을 공시기준일로 하는 공시지가로서, 해당 토지에 관한 협의의 성립 또는 재결 당시 공시된 공시지가 중 사업인정고시일과 가장 가까운 시점에 공시된 공시지가로 한다(제70조 제4항).

(2) 관련 헌법재판소 판례

공시지가에 개발이익이 포함되는 것을 방지하기 위한 것으로 헌법 제23조 제3항에 위반된다고 할 수 없다고 한다.

3) 당해 사업으로 인한 가격변동시 적용 공시지가

토지보상법 제70조 제5항

03 시점수정에 의한 산정

04 지역요인의 비교 및 개별요인의 비교

1) 지역요인 비교

2) 개별요인 비교

3) 감정평가서 기재정도

감정평가서에는 모든 가격산정요인의 세세한 부분까지 일일이 실시하거나 그 요소가 감정평가에 미치는 영향을 수치로 표현할 필요는 없다고 하더라도, 적어도 그 가격산정요인들을 특정*명시하고 그 요인들이 어떻게 참작되었는지를 알아볼 수 있는 정도로 지역요인 및 개별요인의 비교내용을 기술한다.

05 그 밖의 요인 보정(후술)

06 보상액의 결정

07 공시지가 기준보상과 정당보상

CASE

공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률상 공시지가를 기초로 한 보상액 산정에 있어서 개발이익 배제 및 포함을 논하시오. [17회 문3번]

1) 문제점

공시지가를 기준으로 한 보상이 정당보상의 원칙에 합치하는지에 관하여 논의가 있다.

2) 학설

(1) 위헌설

보상액 산정방법을 제한, 공시지가는 시가에 미달

(2) 합헌설

개발이익을 배제하기 위한 방법

3) 판례

- ① 대법원은 공시지가를 기준으로 보상액을 산정하는 것은 개발이익을 배제하기 위한 것으로 보상액 산정방법의 제한이 아니라고 본다.
- ② 헌법재판소는 공시지가가 적정가격을 반영하지 못하고 있다면 이는 제도운영상 문제로서 정하여진 절차에 의해 시정할 수 있으므로 공시지가 기준보상이 정당보상과 괴리되는 것은 아니라고 하였다.

4) 검토

개발이익배제라는 입법취지, 정상거래가격 반영가능 → 정당보상 합치

01 그 밖의 요인의 의의

그 밖의 요인 보정이란 시점수정, 지역요인 및 개별요인의 비교 외에 대상토지의 가치에 영향을 미치는 요인을 보상액에 반영하는 것을 말한다.

02 인정여부

1) 문제점

토지보상법에서 그 밖의 요인 보정에 대한 명문의 규정을 두지 않아, 그 적용가능성이 문제된다.

2) 견해 대립

(1) 부정설

재량을 배제하기 위해서는 법정 고려항목 이외에 어떤 요인도 고려할 수 없다

(2) 긍정설

토지보상법은 개별요인의 비교항목을 예시한 것에 지나지 않으므로 그 밖의 요인 보정이 가능하다고 본다.

3) 판례

(1) 대법원 입장

정상거래가격, 보상선례 등을 고려하는 것이 상당하다.

(2) 헌법재판소 입장

“가감조정을 거쳐 헌법 제23조 제3항의 정당한 보상이 산정된다.”라고 결정한 바 있다.

5) 검토

- ① 정상거래가격, 보상선례 등을 고려하여 정당한 보상금을 산출할 필요성이 있다.
- ② 다만, 입법적으로는 명확한 근거 규정 마련 필요

CASE

甲 소유의 토지를 포함하는 일단의 토지가 공공토지의 비축에 관한 법률에 따라 X읍-Y읍간 도로사업용지 비축사업 지역으로 지정되었고, 한국토지주택공사를 사업시행자로 하여 2014. 3. 31. 이 사건 비축사업에 대하여 「공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따른 사업인정 고시가 있었다. 한편, 관할 도지사는 X읍-Y읍간 도로확포장공사와 관련하여 2016. 5. 1. 도로구역결정·고시하였는데, 甲의 토지는 도로확포장공사가 시행되는 도로구역 인근에 위치하고 있다. 이후 이 사건 비축사업을 위하여 甲 소유의 토지에 대해 2016. 7. 5. 관할 토지수용위원회의 수용재결이 있었는 바, 위 도로확포장공사로 인하여 상승된 토지가격이 반영되지 않는 감정평가가격으로 보상금이 결정되었다.

이에 甲은 도로확포장공사로 인한 개발이익이 배제된 보상금 결정은 위법하다고 주장하는 바, 甲의 주장이 타당한지에 관하여 설명하시오. [28회 문4]

01 개설

개발이익도 보상금에 포함되어야 하는지 여부가 문제된다.

02 개발이익의 의미

개발이익이라 함은 공익사업의 계획 또는 시행이 공고 또는 고시되거나 공익사업의 시행, 그 밖에 공익사업의 시행에 따른 절차로서 행하여진 토지이용계획의 설정·변경·해제 등으로 인하여 토지소유자가 **자기의 노력에 관계없이** 지가가 상승되어 현저하게 받은 이익으로서 **정상지가 상승분을 초과하여 증가된 부분**을 말한다.(표준지 조사 평가기준 제2조 제2호)

03 개발이익 배제의 취지 및 필요성

- ① 공익사업의 개발이익은 기업자의 투자에 의하여 발생하는 것이므로, 기업자 또는 궁극적으로 국민 모두에게 귀속되어야 한다.
- ② 피수용자인 토지소유자의 노력이나 자본에 의하여 발생한 것이 아니므로 불로소득

04 개발이익의 범위와 한계

해당 공익사업은 배제, 다른 공익사업은 포함

05 개발이익 배제의 내용

- 1) 적용공시지가의 적용(사업인정고시일 전 공시지가 기준)
사업인정고시일 전의 공시지가를 기준으로 보상액을 결정
- 2) 해당 공익사업으로 인한 가격변동 배제
- 3) 변경되기 전의 용도지역을 기준

06 개발이익의 배제의 정당보상 합치여부

- 1) 문제점
개발이익이 당해 토지의 객관적 가치의 일부로서 보상액 산정에 포함되어야 하는지 견해가 대립한다.
- 2) 학설
 - (1) 위헌설
주변토지소유자와 피수용자 사이의 형평성이 침해, 종전과 같은 생활수준 유지 곤란
 - (2) 합헌설
불로소득이므로 배제해야
- 3) 판례
 - (1) 대법원
대법원은 개발이익을 배제한 보상액 산정이 타당하다는 입장을 유지해 오고 있다.
 - (2) 헌법재판소
피수용자인 토지소유자의 노력이나 자본에 의하여 발생한 것이 아니므로, 오히려 투자자인 기업자 또는 궁극적으로는 국민 모두에게 귀속되어야 할 성질의 것이라고 판시한 바 있다.
- 4) 검토
 - ① 불로소득이므로 배제가 타당
 - ② 다만, 개발이익을 환수제도 정비 필요성

07 평등원칙 위반 여부

1) 문제점

피수용자에 대한 보상금에서는 개발이익을 배제하나 사업시행지역 밖의 토지소유자는 개발이익을 향유한다면 헌법 제11조의 평등원칙에 위반되지 않는지가 문제된다.

2) 평등의 원칙의 의미

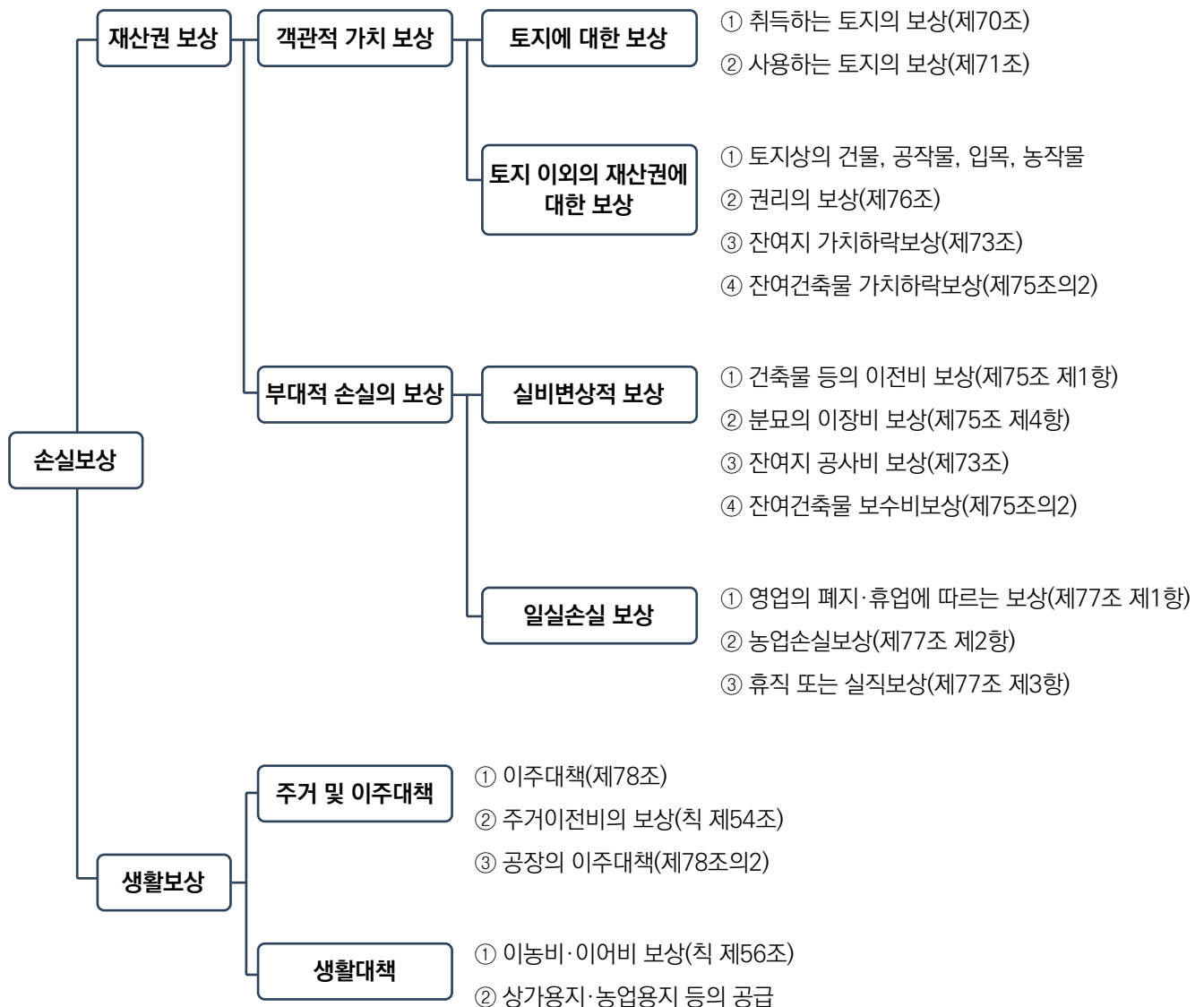
헌법 제11조 제1항이 규정하는 평등의 원칙은 결코 일체의 차별적 대우를 부정하는 절대적 평등을 의미하는 것이 아니라, 법의 적용이나 입법에 있어서 불합리한 조건에 의한 차별을 하여서는 안 된다는 것을 뜻한다.

3) 헌법재판소의 태도

개발이익을 환수할 수 있는 제도적 장치가 마련되지 아니한 제도적 상황에서 보상액 산정에 있어서 개발이익을 배제한다고 하여, 평등원칙에 위반되는 것은 아니라고 보고 있다.

제1절 재산권 보상

[손실보상의 구분]



CASE

2. 생활보상에 관하여 약술하시오.(20점) [15회, 문3]

01 생활보상의 의미

피수용자가 종전과 같은 생활을 유지할 수 있도록 보상하는 것으로 재산권보상으로 채워지지 아니하는 손실에 대한 보상을 말한다.

02 근거

1) 헌법적 근거

(1) 학설

- ① 생활보상은 헌법 제23조 제3항의 정당보상을 근거로 한다는 정당보상설과
- ② 헌법 제34조의 인간다운 생활을 할 권리에 근거한다는 생존권설,
- ③ 헌법 제23조와 제34조를 모두 근거한다는 통일설이 있다.

(2) 판례

- ① 헌법재판소는 이주대책은 헌법 제23조 제3항에서 말하는 정당보상에 해당하지 아니한다고 한다.
- ② 대법원은 이주대책은 국가의 적극적이고 정책적인 배려에 의하여 마련된 제도라 하여 제34조설을 취하고 있다. 다만 최근에 정당보상으로 본 판례가 있다.

(3) 검토

생활보상의 내용에 경제적 약자에 대한 생존배려형 보상이 포함되어 있다는 점을 고려할 때, 통일설이 타당하다.

2) 토지보상법상 근거

제78조(이주대책), 제78조의2(공장의 이주대책), 시행규칙 제54조의 주거이전비, 시행규칙 제56조 이농비·이어비 등

03 생활보상의 범위

1) 주거 및 이주대책

주거대책은 피수용자가 종전과 같은 주거를 획득하는 것을 보장하는 보상을 말한다.

2) 생활대책

생활대책은 종전과 같은 경제수준을 유지할 수 있도록 하는 조치를 말한다.

제1절 공법상 제한받는 토지 평가

CASE

중앙토지수용위원회는 보상금을 산정하면서, X토지는 그 용도지역이 제1종 일반주거지역이기는 하지만 기업도시 개발사업의 시행을 위해서 제3종 일반주거지역으로 변경되지 않은 사정이 인정되므로 제3종 일반주거지역으로 변경이 이루어진 상태를 상정하여 토지가격을 평가한다고 실시하였다. 이에 대해 사업시행자인 乙은 X토지를 제1종 일반주거지역이 아닌 제3종 일반주거지역으로 평가한 것은 공법상 제한을 받는 토지에 대한 보상금 산정에 위법이 있다고 주장하면서 보상금감액청구소송을 제기하고자 한다. 乙의 소송상 청구가 인용될 수 있는 가능성에 관하여 설명하시오. (단, 소송요건은 충족된 것으로 본다.) [28회, 문1번]

01 의미

관계 법령에 의해 가해지는 토지 이용규제나 제한을 받는 토지를 말한다.

02 종류

1) 일반적 계획제한

일반적 계획제한은 제한 그 자체로 목적이 완성되고 구체적 사업시행이 필요하지 않은 제한을 말한다.

2) 개별적 계획제한

개별적 계획제한이란 그 제한이 구체적 사업시행을 필요로 하는 제한이다.

03 보상평가기준

1) 원칙

공법상 제한받는 토지는 제한받는 상태대로 평가한다(칙 제23조 제1항 본문).

2) 예외

(1) 해당 공익사업시행을 직접 목적으로 하여 가하여진 경우

제한이 없는 상태를 상정하여 평가한다(칙 제23조 제1항 단서).

(2) 해당 공익사업 시행을 직접 목적으로 하여 용도지역 등이 변경된 경우

변경되기 전의 용도지역 또는 용도지구 등을 기준으로 평가한다(칙 제23조 제2항).

04 일반적 계획제한과 개별적 계획제한

1) 일반적 계획제한

일반적 계획제한은 제한받는 상태를 기준으로 감정평가한다.

2) 개별적 계획제한

① 개별적 계획제한은 제한을 받지 않는 상태를 기준으로 하여 감정평가한다.

② 판례는 당해 공익사업은 물론 다른 공익사업에 의한 제한도 받지 않는 상태대로 평가하여야 한다고 판시

05 관련 판례 (공익사업의 시행을 위하여 용도지역 등의 변경이 이루어지지 않은 경우)

① 특정 공익사업으로 인하여 용도지역 등이 지정 또는 변경되지 않은 경우 용도지역 등의 지정 또는 변경이 이루어진 상태를 상정하여 토지가격을 평가하여야 한다.

② 이 경우 토지가 특정 공익사업에 제공된다는 사정을 배제할 경우 용도지역 등의 지정 또는 변경을 하지 않은 행위가 계획재량권의 일탈남용에 해당함이 객관적으로 명백하여야만 한다.

CASE

공부상 지목이 과수원(果)으로 되어 있는 토지의 소유자 甲은 이 토지의 일부에 토지의 형질변경허가 및 건축허가를 받지 않고 2005년 8월 26일 임의로 지상 3층 건물을 건축하였다. 위 토지에 대한 보상평가기준에 대해 설명하시오.
[18회, 문3번]

01 무허가건물 등의 부지

1) 의의

무허가건물 등의 부지라 함은 관계법령에 의해 허가를 받거나 신고를 하고 건축 또는 용도변경을 하여야 하는 건물을 허가를 받지 아니하거나 신고를 하지 아니하고 건축 또는 용도변경한 건물의 부지를 말한다.

2) 보상평가기준

(1) 건축당시 이용상황 상정 평가원칙

무허가건축물 등이 건축 또는 용도변경 될 당시의 이용상황을 상정하여 평가한다(칙 제24조).
(현황평가주의의 예외)

(2) 예외

1989년 1월 24일 당시의 무허가건축물등은 적법한 건축물로 본다.

(3) 부지의 범위

무허가건물 등의 사용·수익에 필요한 범위 내의 토지와 무허가건물 등의 용도에 따라 불가분적으로 사용되는 범위의 토지를 의미

3) 입증책임의 문제

토지평가의 대원칙인 현황평가주의의 예외를 인정하려면 그것을 주장하는 자인 <사업시행자가 입증>하여야 할 것이다.

02 불법형질변경토지

1) 의의

불법형질변경토지라 함은 개발행위 허가를 받지 않고 토지형질을 변경하거나 농지 또는 산지를 전용허가를 받지 않거나 신고하지 않고 형질변경된 토지를 말한다.

2) 보상평가기준

(1) 형질변경당시 이용상황 상정 평가원칙

토지가 형질변경될 당시의 이용상황을 상정하여 평가한다(칙 제24조).

(2) 예외

1995년 1월 7일 당시 공익사업시행지구에 편입된 불법형질변경토지 또는 무허가개간토지에 대하여는 현실적인 이용상황에 따라 보상하거나 개간비를 보상하여야 한다.

3) 관련문제

(1) 현황평가 예외가 정당보상원칙 위반인지

불법을 인정하지 않는 것이므로 정당보상에 위반된다고 볼 수 없다.

(2) 소급입법에 의한 재산권박탈금지 원칙에 위배되는지

보호할 신뢰이익이 작고, 신뢰보호요청에 우선하는 심히 중대한 공익성의 사유로 인해 예외적으로 허용

(3) 입증책임의 문제

사업시행자가 불법으로 형질변경되었다는 것을 입증하여야 한다고 할 것이다(판례 동지).

01 의미

미지급용지란 종전에 시행된 공익사업의 부지로서 보상금이 지급되지 아니한 토지를 말한다(칙 제25조).

02 보상평가기준

- ① 미지급용지는 종전의 공익사업에 편입될 당시의 이용상황을 상정하여 평가한다.(칙 제25조 제1항)
- ② 다만, 종전의 공익사업에 편입될 당시의 이용상황을 알 수 없는 경우에는 편입될 당시의 지목과 인근토지의 이용상황 등을 참작하여 평가한다.(칙 제25조 제1항)

03 평가규정의 취지

미지급용지를 가격시점의 이용상황에 따라 공익사업의 부지로 평가하게 되면 피보상자에게 지나친 희생을 강요

04 미지급용지의 판단기준

사업시행자가 사실관계를 조사하여 판단·결정할 사항이다.

05 미지급용지 적용 범위에 대한 논의

1) 문제점

종전의 공익사업으로 인해 지가가 상승하였을 때에도 미지급용지로 보아야 하는지 문제

2) 학설

- ① 토지소유자의 이익 여부와는 관계없이 모두 적용되어야 한다고 보는 견해
- ② 토지소유자에게 불리한 경우에는 적용이 제한된다고 보는 견해

3) 판례

대법원은 종전의 공익사업의 시행으로 인하여 토지의 현실적인 이용상황을 변경시킴으로써 가격이 상승하였다면 미지급용지에 포함되지 않는 것으로 보고 있다.

06 관련 법적 문제

1) 보상의무자

새로운 공익사업의 시행자

2) 보상대상자

소유자가 변경되었을 경우에도 미지급용지의 평가규정을 적용하여 산정한 보상금을 지급하는 것이 타당

3) 미지급용지에 대한 부당이득반환청구권 행사

공공이 사인의 토지를 토지소유자의 점유·관리를 배제한 채 일반 공중의 통행로로 제공한 경우에는 임료(차임) 상당의 이익을 법률상 원인 없이 이득을 보고 있는 것이므로 부당이득금 반환의무가 있는 것이다.(판례)

CASE

공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 시행규칙 (이하 '토지보상법 시행규칙'이라 함) 제26조 제1항에 따른 '사실상의 사도'의 요건을 설명하고, 이에 따라 A토지가 사실상의 사도로 인정되는 경우와 그렇지 않은 경우에 보상기준이 어떻게 달라지는지 설명하시오.(10점) [33회, 문1]

01 토지보상법상 도로의 분류

토지보상법은 ① 사도법상의 사도, ② 사실상의 사도, ③ 그 외의 도로부지로 분류하여 그 평가기준을 달리 정하고 있다(시행규칙 제26조).

02 평가기준

1) 사도법상 사도의 평가

(1) 의의

사도법에 따라 개설허가권자의 개설허가를 받은 도로를 말한다.

(2) 평가방법

- ① 인근토지에 대한 평가액의 5분의 1 이내로 평가한다(칙 제26조 제1항).
- ② <인근토지>라 함은 당해 도로부지 또는 구거부지가 도로 또는 구거로 이용되지 아니하였을 경우에 예상되는 표준적인 이용상황과 유사한 토지로서 당해 토지와 위치상 가까운 토지를 말한다(칙 제26조 제4항).

2) 사실상 사도의 평가

(1) 의의 (칙 제26조 제2항)

사실상의 사도란 [사도법]에 의한 사도 외의 도로로서

- ① 도로개설당시의 토지소유자가 자기 토지의 편익을 위하여 스스로 설치한 도로,
- ② 토지소유자가 그 의사에 의하여 타인의 통행을 제한할 수 없는 도로,
- ③ [건축법] 제45조에 따라 건축허가권자가 그 위치를 지정·공고한 도로,
- ④ 도로개설당시의 토지소유자가 대지 또는 공장용지 등을 조성하기 위하여 설치한 도로의 어느 하나에 해당하는 도로를 말한다.

(2) 사실상 사도의 개념과 관련된 판례

① 자기토지의 편익을 위해 스스로 설치한 도로의 의미 (1호)

토지 소유자가 자기 소유 토지 중 일부에 도로를 설치한 결과 나머지 부분 토지의 편익이 증진되는 경우

② 토지소유자가 그 의사에 의하여 타인의 통행을 제한할 수 없는 도로의 의미 (2호)

단순히 당해 토지가 불특정 다수인의 통행에 장기간 제공되어 왔고 이를 소유자가 용인하여 왔다는 사정만으로는 사실상의 도로에 해당한다고 할 수 없다.

③ 기타

〈사실상의 사도〉의 부지로 보려면 사도법에 의한 사도에 준하는 실질을 갖추고 있어야 하고, 나아가 위 규칙 제26조 제2항 제1호 내지 제4호 중 어느 하나에 해당하여야 할 것이다.(판례)

(3) 평가방법

인근 토지에 대한 평가액의 3분의 1 이내로 평가한다(칙 제26조 제1항).

3) 그 외의 도로 (제1호 또는 제2호외의 도로의 부지)

(1) 공도의 의의

국가 또는 지방자치단체가 일종의 행정권의 작용으로서 토지를 일반 공중의 통행에 제공한 도로를 말한다.

(2) 평가방법

공도의 부지가 도로로 이용되지 아니하였을 경우에 예상되는 인근지역에 있는 표준적인 이용상황을 기준으로 평가한다(공도부지가 처분의 대상이 되기 위해서는 공용폐지를 전제로 하기 때문).

4) 기타 도로

(1) 새마을 도로

새마을 도로는 인근토지 평가액의 3분의 1 이내로 평가한다.

(2) 예정공도

- ① 예정공도란 [국계법]에 따른 도시·군관리계획에 의하여 도로로 결정된 후부터 도로로 사용되고 있는 도로이다.
- ② 예정공도부지는 공도부지의 보상평가방법을 준용한다.

03 도로보상기준의 정당보상 여부

1) 문제점

도로보상평가방법이 헌법상 정당보상에 부합되는지 문제된다.

2) 도로부지를 감가보상하는 이유

(1) 화체이론설

도로가치의 일부가 도로에 접한 토지의 가치로 이전되었기 때문

(2) 사용·수익권 제한 가치설

사용·수익권을 제한당하고 있으므로

(3) 판례의 태도

인근토지에 비하여 낮은 가격으로 보상하여 주어도 될 만한 객관적 사유가 인정되는 경우에만 인근토지의 3분의 1이내에서 평가

(4) 검토

인근토지에 비하여 낮게 보상하여도 될 만한 객관적 사유가 있는 경우에만 적용된다는 점에서 정당보상의 원칙에 위배되지 않는다고 본다.

CASE

한국수자원공사는 한국수자원공사법 제9조 및 제10조에 근거하여 수도권 광역상수도 사업 실시계획을 수립하여 국토해양부장관의 승인을 얻은 후, 1필지인 甲의 토지 8,000㎡ 중 6,530㎡를 협의취득하였다. 협의취득 후 甲의 잔여지는 A지역 495㎡, B지역 490㎡, 그리고 C지역 485㎡로 산재하고 있다.

- 1) 甲은 위 잔여지의 토지가격의 감소를 이유로 손실보상을 청구하려고 한다. 이 경우 잔여지의 가격감소에 대한 甲의 권리구제방법을 설명하시오.
- 2) 호텔을 건립하기 위해 부지를 조성하고 있던 甲은 자신의 잔여지를 더 이상 종래의 사용목적대로 사용할 수 없게 되자 사업시행자와 매수에 관한 협의를 하였으나, 협의를 성립되지 아니하였다. 이에 甲은 관할 토지수용위원회에 잔여지의 수용을 청구하였지만, 관할 토지수용위원회는 이를 받아들이지 않았다. 이 경우 잔여지수용청구의 요건과 甲이 제기할 수 있는 행정소송의 형식을 설명하시오. [23회, 문2]

I 잔여지 손실보상

01 의미 및 취지 (토지보상법 제73조)

잔여지 손실보상이란 일정한 요건하에서 잔여지의 가치가 하락하거나, 공사가 필요한 때 그 비용을 보상하는 것을 말하며 정당보상 실현에 취지가 있다.

02 요건

1) 규정 검토

- ① 사업시행자는 동일한 소유자에 속하는 일단의 토지의 일부가 취득되거나 사용됨으로 인하여 잔여지의 가격이 감소하거나 그 밖의 손실이 있을 때 또는 잔여지에 통로·도랑·담장 등 신설 등 그 밖의 공사가 필요할 때에는 국토교통부령이 정하는 바에 따라 그 손실이나 공사의 비용을 보상하여야 한다.
- ② 다만, 잔여지의 가격 감소분과 잔여지에 대한 공사의 비용을 합한 금액이 잔여지의 가격보다 큰 경우에는 사업시행자는 그 잔여지를 매수할 수 있다(제73조 제1항).

2) 일단의 토지의 의미

반드시 공부상의 한 필지임을 요하지 않으나, 동일한 소유자에게 속하는 것이어야 한다.

03 보상청구 기간 (토지보상법 제73조 제2항)

사업이 완료된 날 또는 제24조의2에 따른 사업완료의 고시가 있는 날부터 1년이 지난 후에는 청구할 수 없다 (제73조 제2항).

04 잔여지 매수의 효과

사업인정고시가 된 후 사업시행자가 잔여지를 매수하는 경우 그 잔여지에 대해서는 사업인정 및 사업인정고시가 된 것으로 본다(제73조 제3항).

05 손실보상 청구 절차

협의를 → 협의 불성립시 재결신청 → (재결에 불복하는 경우) 이의신청 또는 보증소

06 소송제기 전 재결이 선행되어야 하는지 여부 (재결전치주의)

재결절차를 거치지 않은 채 곧바로 사업시행자를 상대로 손실보상을 청구하는 것은 허용되지 않는다고 판시

01 의미 및 취지 (토지보상법 제74조)

잔여지수용청구란 일정한 요건하에 토지소유자가 사업시행자에게 잔여지를 매수하여 줄 것을 청구하는 것을 말한다.
(확장수용의 일환)

02 요건

1) 토지보상법 제74조

- ① 동일한 소유자에게 속하는 일단의 토지의 일부가 협의에 의하여 매수되거나 수용됨으로 인하여 잔여지를 종래의 목적에 사용하는 것이 현저히 곤란할 때에는 해당 토지소유자는 사업시행자에게 잔여지를 매수하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사업인정 이후에는 관할 토지수용위원회에 수용을 청구할 수 있다.
- ② 이 경우 수용의 청구는 매수에 관한 협의가 성립되지 아니한 경우에만 할 수 있으며, 사업완료일까지 하여야 한다.

2) 토지보상법 시행령 제39조

- ① 건축할 수 없거나 건축물의 건축이 현저히 곤란한 경우
- ② 영농이 현저히 곤란한 경우
- ③ 교통이 두절되어 사용이나 경작이 불가능하게 된 경우
- ④ 위와 유사한 정도로 잔여지를 종래의 목적대로 사용하는 것이 현저히 곤란하다고 인정되는 경우 중 하나에 해당하여야 한다.

3) 관련 판례

- ① '종래의 목적'이라 함은 수용재결 당시에 당해 잔여지가 현실적으로 사용되고 있는 구체적인 용도를 의미하고,
- ② '사용하는 것이 현저히 곤란한 때'라고 함은 절대적으로 이용 불가능한 경우만이 아니라 이용은 가능하나 많은 비용이 소요되는 경우를 포함한다고 판시한 바 있다.

03 잔여지수용거부시 제기할 수 있는 소송의 형식

1) 잔여지수용청구권의 법적성질 (형성권)

잔여지 수용청구권은 손실보상의 일환으로 토지소유자에게 부여되는 권리로서 그 요건을 구비한 때에는 잔여지를 수용하는 토지수용위원회의 재결이 없더라도 그 청구에 의하여 수용의 효과가 발생하는 형성권에 해당한다.

2) 잔여지수용 거부에 대한 보상금증감청구소송 가능성

(1) 학설

- ① 보상금액과 보상범위는 밀접한 관련이 있다고 보는 <긍정설>과
- ② 확장수용에 대한 다툼은 보상금액의 문제가 아니라 보상의 범위에 관련된 문제이므로 불가하다는 <부정설>이 있다.

(2) 판례

잔여지 수용청구권은 형성권적 성질을 가지므로, 토지수용위원회의 재결에 대하여 토지소유자가 불복하여 제기하는 소송은 “보상금의 증감에 관한 소송”에 해당하여 사업시행자를 피고로 하여야 한다고 판시했다.

(3) 검토

보상금증감청구소송의 제도 취지가 분쟁의 일회적 해결로서 피수용자의 권리구제를 위한 것이므로 긍정함이 타당

04 관련문제 (잔여지의 수용청구와 잔여지의 가격감소의 선택적 병합 가부)

대법원 2014. 4. 24. 선고 2012두6773

잔여지의 수용청구와 잔여지의 가격감소로 인한 손실보상청구는 서로 양립할 수 없는 관계에 있어 선택적 병합이 불가능

01 개설

토지보상법은 건축물 등 물건에 대하여는 이전에 필요한 비용으로 보상하도록 규정하고, 예외적으로 물건의 가격으로 보상하는 방법을 규정하고 있다.

02 건축물에 대한 보상평가

1) 건축물의 의의

2) 보상평가기준

(1) 건축물 가격의 평가

가. 이전비 보상의 원칙

이전비로 보상함이 원칙이다(제75조 제1항).

나. 물건가격으로 보상하는 경우

- ① 건축물의 가격은 원가법으로 평가한다.
- ② 다만, 주거용 건축물에 있어서는 거래사례비교법에 의하여 평가한 금액이 원가법에 의하여 평가한 금액보다 큰 경우와 구분소유권의 대상이 되는 건물의 가격은 거래사례비교법으로 평가한다(칙 제33조 제2항).

다. 개발이익의 배제

주거용 건축물을 거래사례비교법으로 평가함에 있어 공익사업의 시행에 따라 이주대책을 수립·실시하거나 주택입주권 등을 당해 건축물의 소유자에게 주는 경우 또는 개발제한구역안에서 이전이 허용되는 경우에 있어서의 당해 사유로 인한 가격상승분은 제외하고 평가하도록 규정하고 있다(칙 제33조 제2항).

03 무허가건축물에 대한 보상

CASE

공부상 지목이 과수원으로 되어 있는 토지의 소유자 甲은 토지상에 식재되어 있던 사과나무가 이미 폐목이 되어 과수농사를 할 수 없는 상태에서 사과나무를 베어내고 인삼밭으로 사용하여 왔다. 또한 甲은 이 토지의 일부에 토지의 형질변경허가 및 건축허가를 받지 않고 2005년 8월 26일 임의로 지상 3층 건물을 건축하고, 영업허가 등의 절차 없이 식당을 운영하고 있다. 위 토지 및 지장물에 대한 보상평가기준에 대해 설명하시오. [18회, 문3]

1) 무허가건축물의 의의

「건축법」 등 관계법령에 의하여 허가를 받거나 신고를 하고 건축 또는 용도변경을 하여야 하는 건축물을 허가를 받지 아니하거나 신고를 하지 아니하고 건축 또는 용도변경한 건축물이다(칙 제24조).

2) 무허가건축물의 보상여부

(1) 문제점

무허가건축물도 보상대상이 되는지 문제된다.

(2) 학설

① 보상대상이 아니라는 견해

② 보상대상이라는 견해

③ 사업인정을 기준으로 하는 견해

사업인정 후의 무허가건축물은 보상의 대상이 아니나 사업인정 전의 무허가건축물은 보상대상이라고 보는 견해이다.

(3) 판례

토지수용법상의 사업인정의 고시 이전에 건축된 건물이기만 하면 손실보상의 대상이 됨이 명백하다 (대판 99두10896).

(4) 검토

생각건대 허가는 그 성질에 비추어 행위의 적법성 여부에만 관여하고 유효성 여부와는 무관, 사업인정을 기준으로 하여 판단하는 견해가 타당하다.

3) 보상평가기준

① 적법한 건축물의 평가방법과 동일한 평가방법을 적용해야 할 것이다.

② 그러나 무허가 건축물은 인허가에 드는 행정적 비용과 보유기간 동안의 재산세 등은 이를 부담하지 않았으므로, 이를 고려하여 평가하여야 한다.

04 주거용 건축물 등의 보상에 관한 특례

1) 주거용 건축물의 최저 보상에 관한 특례

① 주거용건축물로서 건축물 평가 규정에 따라 평가한 금액이 6백만 원 미만인 경우 그 보상액은 6백만 원으로 한다.

② 다만, 무허가건축물 등에 대하여는 그러하지 아니하다(다만 1989년 1월 24일 당시 무허가건축물은 특례 적용)

2) 재편입 주거용 건축물에 대한 가산금

① 공익사업의 시행으로 인하여 주거용 건축물에 대한 보상을 받은 자가 그 후 당해 공익사업시행지구밖의 지역에서 매입하거나 건축하여 소유하고 있는 주거용 건축물이 그 보상일부터 20년 이내에 다른 공익사업시행지구로 편입되는 경우 그 주거용 건축물 및 그 대지(보상을 받기 이전부터 소유하고 있던 대지 또는 다른 사람 소유의 대지위에 건축한 경우에는 주거용 건축물에 한한다)에 대하여는 당해 평가액의 30퍼센트를 가산하여 보상한다.

② 가산금은 1천만원을 한도로 하고, 1989년 1월 24일 당시의 무허가건축물에 대해서도 특례를 적용한다.

CASE

주식회사 甲은 30년 넘게 서울특별시 A구에서 콘크리트 제조 공장을 허가 받아 적법하게 운영하고 있다. 甲이 창고로 사용하고 있는 부지(이하 '이 사건 부지'라 함)는 백제 한성기의 왕성 유적으로 알려진 국가지정문화유산 B유적지의 보호구역에 있다. 학계 등은 B유적지의 완전한 복원을 위해서는 이 사건 부지의 수용 필요성을 오래전부터 제기해 왔고, 이 사건 부지에 있는 창고의 증축과정에서 백제 토성의 유물이 발견되기도 하였다.

한편, 관련 법령에 따라 B유적지를 관리하는 A구청장 乙은 B유적지의 정비 및 복원을 위하여 이 사건 부지에 대한 공익사업을 계획하고 국토교통부장관에게 사업인정 신청을 하였다. 국토교통부장관은 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」(이하 '토지보상법'이라 함)에 따라 사업인정(이하 '이 사건 사업인정'이라 함)을 하고 이를 고시하였다. 甲은 다음과 같은 이유로 이 사건 사업인정 및 고시가 위법하다고 주장한다.

물음 3) 이 사건 부지에 대한 수용이 진행될 경우, 甲의 영업손실에 대한 보상 요건을 설명하시오. [36회, 문1]

01 의미 및 성격

영업손실이란 수용대상이 된 토지·건물 등을 이용하여 영업을 하다가 그 토지·건물 등이 수용됨으로 인하여 영업을 할 수 없거나 제한을 받게 됨으로 인하여 생기는 직접적인 손실을 말한다.

02 영업손실의 보상대상인 영업 (토지보상법 시행규칙 제45조)

1) 시간적 요건

사업인정고시일등(사업인정고시일과 보상계획공고일 중 빠른 날) 이전부터 영업을 하고 있어야 한다.

2) 장소적 요건

- ① 적법한 장소에서 이루어진 영업이어야 한다.
- ② 다만, 무허가건축물등에서 임차인이 영업하는 경우에는 그 임차인이 사업인정고시일등 1년 이전부터 「부가가치세법」 제8조에 따른 사업자등록을 하고 영업을 행한 경우에는 보상대상이 된다.

3) 시설적 요건

일정한 정도의 인적·물적 시설을 갖추어야 한다.

4) 계속적 요건

계속적으로 영업을 하여야 한다.

5) 허가 등의 요건

허가 등을 필요로 하는 경우에는, 사업인정고시일등 전에 그 허가 등을 받아 그 내용대로 영업을 하고 있어야 한다.

03 영업의 폐지와 휴업의 구분

1) 토지보상법상 기준 (칙 제46조 제2항)

- ① 다른 장소에 이전하여서는 당해 영업을 할 수 없는 경우
- ② 다른 장소에서는 당해 영업의 허가등을 받을 수 없는 경우
- ③ 도축장 등 악취 등이 심하여 인근주민에게 혐오감을 주는 영업시설로서 다른 장소로 이전하는 것이 현저히 곤란하다고 특별자치도지사·시장·군수 또는 구청장이 객관적인 사실에 근거하여 인정하는 경우

2) 영업의 폐지와 휴업의 구별 기준 (이전가능성)

다른 장소로 이전하는 것이 가능한지 여부에 달려 있다.

04 보상평가기준

1) 폐업보상

(1) 평가기준

2년간의 영업이익에 영업용 고정자산·원재료·제품 및 상품 등의 매각손실액을 더한 금액으로 평가한다 (칙 제46조 제1항).

(2) 영업이익 및 소득의 산정

최근 3년간의 평균 영업이익을 기준으로 한다.

2) 휴업보상

공익사업의 시행으로 인하여 영업장소를 이전하여야 하는 경우의 영업손실은 휴업기간에 해당하는 영업이익과 영업장소 이전 후 발생하는 영업이익감소액에 다음 각호의 비용을 합한 금액으로 평가한다.(칙 제47조 제1항)

05 무허가건축물 임차인의 영업에 대한 보상

1) 폐업보상

무허가건축물 등에서 임차인이 영업하는 경우 폐업보상액 중 영업용 고정자산 등 매각손실액을 제외한 금액은 1천만 원을 초과하지 못한다(칙 제46조 제5항).

2) 휴업보상

영업시설의 이전비용 및 감손상당액을 제외한 금액은 1천만 원을 초과하지 못한다(칙 제47조 제6항).

06 무허가영업의 손실보상에 관한 특례

1) 3개월 수준의 가계지출비 수준의 보상

적법한 장소에서 행하던 무허가영업을 계속할 수 없게 된 경우에는 「통계법」에 따른 가계조사통계의 도시근로자가 구 월평균 가계지출비를 기준으로 산정한 3인 가구 3개월분 가계지출비에 해당하는 금액을 영업손실에 대한 보상금으로 지급하되, 영업시설 등의 이전비용은 별도로 보상한다(칙 제52조 본문).

2) 무허가영업에 대한 손실보상의 배제 및 한도

본인 또는 생계를 같이 하는 동일 세대안의 직계존속·비속 및 배우자가 해당 공익사업으로 다른 영업에 대한 보상을 받은 경우에는 영업시설 등의 이전비용만을 보상하여야 한다(칙 제52조 단서).

07 공익사업시행지구 밖의 영업손실에 대한 보상

공익사업시행지구 밖에서 영업손실 보상대상이 되는 영업을 하고 있는 자가, 공익사업의 시행으로 인하여, ① 배후지의 3분의 2 이상이 상실, ② 진출입로의 단절, 그 밖의 부득이한 사유로 인하여, 일정한 기간 동안 휴업하는 것이 불가피한 경우의 어느 하나에 해당하면, 영업보상하여야 한다(칙 제64조 제1항).

08 관련 문제

1) 가설건축물 안에서의 영업이 보상대상이 되는지

가설건축물은 공익사업이 시행될 때 철거가 예정되어 있으므로 가설건축물 내의 영업도 보상대상이 아니라고 보는 것이 타당하다.

2) 자유영업의 경우 사업자등록이 영업의 적법요건인지

생각건데 사업자등록은 납세의무와 관련이 있는 것이지 영업의 적법요건으로 볼 수는 없다.

CASE 1

A시는 도시개발사업을 하면서 주거를 상실하는 거주자에 대한 이주대책을 수립하였다. 이주대책의 주요내용은 다음과 같다. 이를 근거로 다음 물음에 답하시오.(45점) [20회, 문1]

- 기준일 이전부터 사업구역 내 자기 토지상 주택을 소유하고 협의 계약 체결일까지 당해 주택에 계속 거주한 자가 보상에 합의하고 자진 이주한 경우 사업구역 내 분양아파트를 공급한다.
- 분양아파트를 공급받지 않은 이주자에게는 이주정착금을 지급한다.
- 무허가건축물 대장에 등록된 건축물 소유자는 이주대책에서 제외한다.

- 1) 이주대책의 이론적 및 헌법적 근거를 설명하시오.(5점)
- 2) 주택 소유자 甲이 보상에 합의하고 자진 이주하지 아니한 경우에도 이주대책에 의한 분양아파트의 공급 혹은 이주정착금의 지급을 요구할 수 있는지의 여부를 검토하시오.(20점)
- 3) 무허가건축물대장에 등록되지 않은 건축물 소유자 乙이 당해 건축물이 무허가건축물이라는 이유로 이주대책에서 제외된 경우에 권리구제를 위하여 다룰 수 있는 근거와 소송방법에 관하여 검토하시오.(20점)

CASE 2

도지사 A는 “X국가산업단지 내 국도 대체우회도로개설사업”(이하 ‘이 사건 개발사업’이라 함)의 실시계획을 승인·고시하고, 사업시행자로 B시의 시장을 지정하였다. B시의 시장은 이 사건 개발사업을 시행함에 있어 사업시행으로 인하여 건물이 철거되는 이주대상자를 위한 이주대책을 수립하면서 훈령의 형식으로 ‘B시 이주민지원규정’을 마련하였다.

위 지원규정에서는 ① 이주대책대상자 선정과 관련하여 공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률 및 그 시행령이 정하고 있는 이주대책대상자 요건 외에 ‘전세대원이 사업구역 내 주택 외 무주택’이라는 요건을 추가적으로 규정하는 한편, ② B시의 이주택지 지급 대상에 관하여, 과거 건축물양성화기준일 이전 건물의 거주자의 경우 소지가(조성되지 아니한 상태에서의 토지가격) 분양대상자로, 기준일 이후 건물의 거주자의 경우 일반우선 분양대상자로 구분하고 있는 바, 소지가 분양대상자의 경우 1세대당 상업용지 3평을 일반분양가로 추가 분양하도록 하고, 일반우선 분양대상자의 경우 1세대 1필지 이주택지를 일반분양가로 우선분양할 수 있도록 하고 있다.

B시의 시장은 이주대책을 실시하면서 이 사건 개발사업 구역 내에 거주하는 甲과 乙에 대하여, 甲은 공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법령이 정한 이주대책대상자에 해당됨에도 위 ①에서 정하는 요건을 이유로 이주대책대상자에서 배제하는 부적격 통보를 하였고, 소지가 분양대상자로 신청한 乙에 대해서는 위 지원규정을 적용하여 소지가 분양대상이 아닌 일반우선분양대상자로 선정하고, 이를 공고하였다. 다음 물음에 답하시오. (30점)

- 1) 甲은 ‘B시 이주민지원규정’에서 정한 추가적 요건을 이유로 자신을 이주대책 대상자에서 배제한 것은 위법하다고 주장한다. 甲의 주장이 타당한지에 관하여 설명하시오.(15점)
- 2) 乙은 자신을 소지가 분양대상자가 아닌 일반우선 분양대상자로 선택한 것은 위법하다고 보아 이를 소송으로 다투려고 한다. 乙이 제기하여야 하는 소송의 형식을 설명하시오.(15점) [28회, 문2]

01 의미

이주대책이란 공익사업의 시행으로 인하여 생활의 근거를 상실하게 되는 자를 종전과 같은 생활상태를 유지할 수 있도록 다른 지역으로 이주시키는 것을 말한다.

02 이주대책의 범위

- ① 협의의 이주대책 : 이주정착지에 이주시키는 것
- ② 광의의 이주대책 : 이주대책대상자의 이주를 지원하는 모든 것

03 근거

1) 이론적 근거

원상회복, 생활보장, 생활안정, 감정준중 등

2) 헌법적 근거

(1) 학설

- ① 생활보상은 헌법 제23조 제3항의 정당보상을 근거로 한다는 정당보상설과
- ② 헌법 제34조의 인간다운 생활을 할 권리에 근거한다는 생존권설,
- ③ 헌법 제23조와 제34조를 모두 근거한다는 통일설이 있다.

(2) 판례

- ① 헌법재판소는 이주대책은 헌법 제23조 제3항에서 말하는 정당보상에 해당하지 아니한다고 한다.
- ② 대법원은 이주대책은 국가의 적극적이고 정책적인 배려에 의하여 마련된 제도라 하여 제34조설을 취하고 있다. 다만 최근에 정당보상으로 본 판례가 있다.

(3) 검토

생활보상의 내용에 경제적 약자에 대한 생존배려형 보상이 포함되어 있다는 점을 고려할 때, 통일설이 타당하다.

3) 토지보상법상 근거

토지보상법 제78조의 주거용 건축물에 대한 이주대책을 생활보상으로 볼 수 있고 동법 제78조의 2에서 공장부지 제공자에 대한 이주대책이 규정되어 있다.

04 수립·실시

1) 이주대책의 수립·실시 의무

(1) 이주대책의 수립·실시 의무

사업시행자는 공익사업의 시행으로 인하여 주거용 건축물을 제공함에 따라 생활의 근거를 상실하게 되는 자를 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 이주대책을 수립·실시하거나 이주정착금을 지급하여야 한다(제78조 제1항).

(2) 이주대책 수립·실시의 의제

2) 이주대책 수립요건

- ① 인근에 택지 조성에 적합한 토지가 없는 경우 또는
- ② 이주대책의 수립·실시로 인하여 당해 공익사업의 시행이 사실상 곤란하게 되는 경우(칙 제53조 제1항)를 제외하고는
- ③ 이주대책대상자 중 이주정착지에 이주를 희망하는 자의 가구 수가 10호(戶) 이상인 경우에 수립·실시한다(령 제40조 제2항).

3) 이주대책대상자에서 제외되는 경우 (령 제40조 제5항)

- ① 무허가 건축물 등의 소유자
- ② 계속하여 거주하고 있지 아니한 건축물의 소유자
- ③ 타인이 소유하고 있는 건축물에 거주하는 세입자

4) 절차

5) 이주대책의 내용

(1) 이주대책 수립 시 사업시행자의 재량

사업시행자는 이주대책을 수립할 의무를 지지만, 이주대책의 내용 결정에 대해서는 재량권을 갖는다.(판례동지)

(2) 이주정착지의 조성공급

이주대책의 내용에는 이주정착지에 대한 도로, 급수시설 등 통상적인 수준의 생활기본시설이 포함되어야 하며, 이에 필요한 비용은 사업시행자가 부담한다.

6) 사업시행자가 수립한 이주대책 기준의 대외적 구속력 여부

- ① 대법원은 한국토지주택공사가 수립한 이주대책기준에 대하여 <사업시행자 내부의 사무처리준칙>에 불과하고, 대외적으로 국민이나 법원을 기속하는 효력이 없다고 판시하였다. (대법원 96누140672),
- ② 다만, 사업시행자는 이주대책을 수립·실시하는데 재량을 가지므로 사업시행자가 설정한 이주대책기준은 그것이 객관적으로 합리적이 아니라거나 타당하지 않다고 볼 만한 특별한 사정이 없는 한 존중되어야 한다고 하였다 (대법원 2008두12610).

05 이주자의 법적 지위

1) 문제점

이주대책대상자는 이주대책상의 권리를 언제 취득하는지가 문제된다.

2) 이주대책계획수립청구권

- ① 이주대책대상자는 사업시행자에게 특정한 이주대책을 청구할 권리는 발생하지 않지만, 이주대책을 수립할 것을 청구할 권리, 즉 이주대책계획수립청구권을 갖는다.
- ② 사업시행자가 이주대책을 수립하지 않는 경우에는 의무이행심판 또는 부작위위법확인소송을, 거부한 경우에는 의무이행심판(또는 거부처분취소심판) 또는 거부처분취소소송을 제기할 수 있다.

3) 분양신청권

이주대책계획이 수립되면 이주대책대상자는 분양신청권을 취득한다.

4) 수분양권의 발생시기

(1) 문제점

- ① 수분양권이란 이주단지조성사업에 의해 조성된 택지의 분양권이나 아파트입주권 등을 취득할 수 있는 구체적 권리이다.
- ② 수분양권이라는 특정한 실체법상의 권리가 언제 이주대책대상자에게 발생하는지 문제된다.

(2) 학설

① 법상 취득설 (=이주대책수립 이전설)

토지보상법 제78조의 규정에 의하여 당연히 이주자에게 구체적인 수분양권이 발생한다고 본다.

② 이주대책계획수립시설

토지보상법 규정에 의한 추상적·포괄적 권리가 사업시행자가 이주대책을 수립·실시한 때 구체적 권리인 수분양권으로 발생한다고 본다.

③ 확인·결정시설

이주자가 사업시행자에게 이주대책대상자 선정신청을 하고 사업시행자가 이를 받아들여 이주대책 대상자로 확인·결정하여야만 비로소 구체적인 수분양권이 발생한다고 본다.

(3) 판례

- ① 판례의 다수의견은 <확인·결정시설>의 입장에서 사업시행자의 이주대책 대상자 확인·결정은 행정처분에 해당하므로 이에 불복하는 자는 항고소송으로 다룰 수 있다는 입장이다.
- ② 다만 반대의견은 <법상 취득설>의 입장이고, 반대보충의견은 <이주대책계획수립시설>을 취하고 있다.

(4) 검토

- ① 토지보상법 제78조에 구체적인 내용이 없으므로 이 규정에 의하여 바로 수분양권이 발생한다고 볼 수는 없다.
- ② 법상 이주대책대상자 : 사업시행자가 구체적인 계획을 수립하면
- ③ 법상 이주대책대상자가 아닌 이주자 : 사업시행자가 이주대책대상자로 확인·결정하여야

06 수분양권의 발생시기별 권리구제 방법

1) 학설

학설	권리구제
법상 취득설 (이주대책 계획수립 이전설)	① 거부시 : 거부처분 취소소송 ② 분양신청을 하더라도 거부당할 것이 명백한 특수한 경우 : 분양을 받을 권리 또는 그 법률상 지위의 확인을 구할 수 있다.(확인소송의 보충성 필요)
이주대책 수립시설	① 거부시 : 거부처분 취소소송 ② 사업시행자가 미리 수분양권을 부정하거나, 분양절차가 종료되어 분양신청을 하더라도 거부당할 것이 명백할 경우, 확인소송이 권리구제에 유효 적절한 수단이 되는 경우 : 당사자소송으로 수분양권 또는 법률상 지위의 확인을 구할 수 있다.
확인·결정시설	① 거부시 : 거부처분취소소송 ② 이주대책대상자 선정신청 및 이에 따른 확인·결정 등 절차를 밟지 아니하여 수분양권을 아직 취득하지도 못한 상태에서 곧바로 분양의무의 주체를 상대방으로 하여 민사소송이나 공법상 당사자소송으로 이주대책상의 수분양권의 확인 등을 구하는 것은 허용될 수 없다.

2) 검토

- ① 생각건데, 이주대책대상자 선정은 확인행위이다.
- ② 따라서 선정거부는 거부처분취소소송을 제기하거나 수분양권의 확인을 구하는 소송(공법상 당사자소송)을 제기하여야 할 것이다.

07 이주대책에 대한 권리구제

1) 학설

- ① 확인결정이라는 처분에 의해 비로소 수분양권이라는 권리가 발생하는 <형성처분>으로 보는 견해,
- ② 확인결정은 이주대책 수립·실시절차를 이행하기 위해 행하는 <확인·이행처분>으로 보는 견해가 있다.

2) 판례

- ① 대법원 다수의견은 확인·결정시 수분양권이 발생한다는 입장이므로, 확인결정행위는 <형성적 행정처분>으로 본다.
- ② 반대의견 및 반대보충의견은 확인결정 이전에 이미 취득하고 있는 것이라는 입장이므로 <확인·이행처분>으로 본다.

3) 검토

- ① 어느 견해에 따르더라도 이주대상자 확인·결정행위는 행정쟁송법상 처분이므로 항고소송의 대상이 된다.
- ② 따라서 이주자의 이주대책대상자 선정신청에 대하여 사업시행자가 거부한 경우에는 이주자는 사업시행자를 상대로 항고소송을 제기할 수 있다.

CASE 1

공공사업으로 인한 소음·진동·먼지 등에 의한 간접 침해의 구제수단을 설명하시오. (20점) [14회, 문3]

CASE 2

丙은 이 사건 공익사업구역 밖에서 음식점을 경영하고 있었는데, 이 사건 공익사업으로 인하여 자신의 음식점의 주 출입로가 단절되어 일정 기간 휴업을 할 수 밖에 없게 되었다. 이때, 丙은 토지보상법령상 보상을 받을 수 있는가? (10점) [29회, 문1]

01 간접손실 및 간접손실보상의 개념

1) 간접손실의 개념 및 구별개념

공익사업으로 인하여 사업시행지 밖의 재산권자에게 가해지는 손실 중 공익사업으로 인하여 필연적으로 발생하는 손실이 간접손실이다.

2) 간접손실의 유형

02 간접손실보상의 필요성

- ① 토지 등이 비록 공익사업에 직접 편입되지 않았으나 그로 인해 손실이 발생하였다면 마땅히 보상되어야 한다.
- ② 형평의 관념에서라도 간접손실보상이 필요하다.

03 간접손실보상의 법적 성격과 논거

1) 간접손실보상의 법적성질

- ① 손해배상의 성격으로 보는 견해
- ② 손실보상으로 보는 견해
- ③ 제3의 유형으로서 일종의 결과책임으로서의 보상이라는 견해
- ④ 구별은 의미가 없고, 피해를 어떻게 처리할 것인가가 중요하다고 보는 구별불요설 등이 있다.

2) 간접손실보상의 성격

- ① 간접적으로 침해가 발생한다는 점에서 직접침해에 의한 보상과는 구별된다.
- ② 사후보상의 성격을 갖는다.
- ③ 재산권에 대한 보상과 생활권에 대한 보상의 성격이 모두 있다.

04 간접손실이 헌법 제23조 제3항에 포함되는지 여부

1) 문제점

간접손실이 헌법 제23조 제3항에 포함되는 손실이라면 헌법 제23조 제3항의 정당보상이 주어져야 하므로, 이하 견해대립을 검토한다.

2) 학설

- ① 헌법 제23조 제3항은 공용침해로 인하여 재산권자에게 직접적으로 발생한 손실만을 보상하는 것으로 규정하고 있다고 보는 부정설,
- ② 간접손실도 헌법 제23조 제3항의 손실보상에도 포함시키는 것이 타당하다는 긍정설이 있다.

3) 판례

판례는 간접손실을 헌법 제23조 제3항에서 규정한 손실보상의 대상이 된다고 본다.(긍정설)

4) 검토

헌법 제23조 제3항을 손실보상에 관한 일반적 규정으로 보는 것이 타당(긍정설)

05 간접손실보상의 법률적 근거

토지보상법 제79조 및 동법 시행규칙 제59조부터 제65조에서 규정한다.

06 간접손실보상의 요건

1) 일반적 요건

(1) 간접손실의 존재

- ① 공공사업의 시행으로 사업시행지 이외의 토지소유자(제3자)가 입은 손실이어야 하고,
- ② 그 손실이 공공사업의 시행으로 인하여 발생하리라는 것이 예견되어야 하고,
- ③ 그 손실의 범위가 구체적으로 특정될 수 있어야 한다.

(2) 특별한 희생의 발생

(3) 보상규정의 존재

- ① 간접손실보상을 위해서 원칙적으로 간접손실보상에 관한 법령상 규정이 존재해야 한다.
- ② 토지보상법 제79조 제1항은 간접손실인 공사비용의 보상을 규정하고 있다. 또한 토지보상법 제79조 제2항은 <국토교통부령으로 정하는 바에 따라 그 손실을 보상하여야 한다.> 고 규정하고 있다.
- ③ 이에 따라 동법 시행규칙은 제59조부터 제65조에서 간접보상을 유형화하여 열거·규정하고 있다.

2) 보상규정 존재와 관련한 요건

(1) 토지보상법 제79조 제4항을 일반근거규정으로 볼 수 있는지

- ① 토지보상법 제79조 제4항은 법에 규정된 사항 외의 간접손실보상에 관하여는 국토교통부령으로 정하는 기준에 따른다고 규정한다.
- ② 동규정을 일반근거조항으로 보는 견해와, 개괄수권조항으로 보는 견해가 대립한다.
- ③ 생각건대, 개괄수권조항설이 타당하다.

(2) 보상규정 흠결시 보상청구가능성

CASE

X군에 거주하는 어업인들을 조합원으로 하는 A수산업협동조합은 조합원들이 포획*채취한 수산물의 판매를 위탁받아 판매하는 B수산물위탁판매장을 운영하여 왔다. 한편, B위탁판매장 운영에 대해서는 관계 법령에 따라 관할 지역에 대한 독점적 지위가 부여되어 있었으며, A조합은 B위탁판매장 판매액 중 일정비율의 수수료를 지급받아 왔다. 그런데, 한국농어촌공사는 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」에 따라 X군 일대에 대한 공유수면매립면허를 받아 공유수면매립사업을 시행하였고, 해당 매립사업의 시행으로 인하여 사업대상지역에서 어업활동을하던 A조합의 조합원들은 더 이상 조업을 할 수 없게 되었다.

A조합은 위 공유수면매립사업지역 밖에서 운영하던 B위탁판매장에서의 위탁판매사업의 대부분을 중단하였고, 결국에는 B위탁판매장을 폐쇄하기에 이르렀다. 이에 따라 A조합은 공유수면매립사업으로 인한 위탁판매수수료 수입의 감소에 따른 영업손실의 보상을 청구하였으나, 한국농어촌공사는 B위탁판매장이 사업시행지 밖에서 운영되던 시설이었고 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」상 직접적인 보상 규정이 없음을 이유로 보상의 대상이 아니라고 주장한다. 한국농어촌공사의 주장은 타당한가? [30회, 문3]

가. 학설

- ① 토지보상법 시행규칙 제59조 이하의 간접보상규정을 제한적 열거규정으로 보는〈보상부정설〉,
- ② 헌법 제23조 제3항 및 토지보상법상의 간접손실보상에 관한 규정을 유추적용하여 보상을 청구할 수 있다고 보는〈유추적용설〉,
- ③ 헌법 제23조 제3항에 근거하여 보상청구권이 인정된다고 보는〈헌법 제23조 제3항의 직접적용설〉,
- ④ 간접손실도 헌법상 평등원칙 및 재산권 보장규정에 근거하여 보상해 주어야 한다고 보는〈평등원칙 및 재산권보장규정근거설〉,
- ⑤ 손해배상을 청구하여야 한다는〈손해배상설〉
- ⑥ 간접손실을 수용적 침해로 보아 보상하려는〈수용적침해설〉 등의 견해가 대립한다.

나. 판례의 입장

간접손실을 헌법 제23조 제3항에 규정한 손실보상의 대상이 된다고 보고, 간접손실보상규정을 유추적용하여 그에 관한 보상을 인정하는 것이 타당하다고 보았다.

다. 검토

간접손실보상도 헌법 제23조 제3항의 손실보상에 포함된다고 보아 직접 헌법 제23조 제3항에 근거하여 손실보상을 청구할 수 있다고 보는 것이 타당하다.

07 토지보상법상 간접손실의 보상내용

1) 공익사업시행지구 밖의 대지 등에 대한 보상 (칙 제59조)

2) 공익사업시행지구 밖의 건축물에 대한 보상 (칙 제60조)

3) 소수잔존자에 대한 보상 (칙 제61조)

4) 공익사업시행지구 밖의 공작물 등에 대한 보상 (칙 제62조)

5) 공익사업시행지구 밖의 어업피해에 대한 보상 (칙 제63조)

6) 공익사업시행지구 밖의 영업손실보상 (칙 제64조)

(1) 요건

공익사업시행지구 밖에서 영업손실의 보상대상이 되는 영업을 하고 있는 자가 공익사업의 시행으로 인하여
① 배후지의 3분의 2 이상이 상실되어 그 장소에서 영업을 계속할 수 없는 경우 또는 ② 진출입로의 단절,
그 밖의 부득이한 사유로 인하여 일정한 기간 동안 휴업하는 것이 불가피한 경우의 어느 하나에 해당하는
경우에는 그 영업자의 청구에 의하여 당해 영업을 공익사업시행지구에 편입되는 것으로 보아 보상하여야 한다.

(2) 제1호의 의미

(3) 제2호의 의미

〈그 밖의 부득이한 사유〉라는 것은 공익사업의 시행 또는 시행 당시 발생한 사유로 휴업이 불가피한 경우만을
의미하는 것이 아니라 공익사업의 시행 결과, 즉 그 공익사업의 시행으로 설치되는 시설의 형태·구조·사용
등에 기인하여 휴업이 불가피한 경우도 포함된다고 해석함이 타당하다.(판례)

7) 공익사업시행지구 밖의 농업손실보상 (칙 제65조)

경작하고 있는 농지의 3분의 2 이상에 해당하는 면적이 공익사업시행지구에 편입됨으로 인하여 당해 지역에서
영농을 계속할 수 없게 된 농민에 대하여는 공익사업시행지구 밖에서 그가 경작하고 있는 농지에 대하여도
영농손실액을 보상하여야 한다.

08 간접손실보상의 한계

09 공사비보상

1) 공사비보상의 대상과 범위

사업시행자는 공익사업의 시행으로 인하여 취득하거나 사용하는 토지(잔여지를 포함한다) 외의 토지에 통로*도량*담장 등의 신설이나 그 밖의 공사가 필요할 때에는 그 비용의 전부 또는 일부를 보상하여야 한다.

2) 비용보상의 청구기한

사업이 완료된 날 또는 사업완료의 고시가 있는 날부터 1년 내 청구해야 한다.

3) 손실보상의 협의와 재결 (토지보상법 제80조)

협의 후 불성립시 재결신청

CASE

X는 도시 및 주거환경정비법(이하 '도시정비법'이라 함)에 따른 재개발정비사업조합이고, 甲은 X의 조합원으로서, 해당 정비사업구역 내에 있는 A토지와 B토지의 소유자이다. A토지와 B토지는 연접하고 있고 그 지목이 모두 대(垔)에 해당하지만, A토지는 사도법에 따른 사도가 아닌데도 불특정 다수인의 통행에 장기간 제공되어 왔고, B토지는 甲이 소유한 건축물의 부지로서 그 건축물의 일부에 임차인 乙이 거주하고 있다. X는 도시정비법 제72조 제1항에 따라 분양신청기간을 공고하였으나 甲은 그 기간내에 분양신청을 하지 않았다. 이에 따라 X는 甲을 분양대상자에서 제외하고 관리처분계획을 수립하여 인가를 받았고, 그에 불복하는 행정심판이나 행정소송은 없었다. X는 도시정비법 제73조 제1항에 따른 甲과의 보상협정이 이루어지지 않자 A토지와 B토지에 관하여 관할 토지수용위원회에 수용재결을 신청하였고, 관할 토지수용위원회는 A토지와 B토지를 수용한다는 내용의 수용재결을 하였다. 다음 물음에 답하시오. (40점)

물음 3) 주거이전비에 관하여 甲은 토지보상법 시행규칙 제54조 제1항에 따른 요건을 갖추고 있고, 乙은 같은 조 제2항에 따른 요건을 갖추고 있다. 관할토지수용위원회는 수용재결을 하면서 甲의 주거이전비에 관하여는 재결을 하였으나 乙의 주거이전비에 관하여는 재결을 하지 않았다. 甲은 주거이전비의 증액을 청구하고자 하고, 乙은 주거이전비의 지급을 청구하고자 한다. 甲과 乙의 권리구제에 적합한 소송을 설명하시오. [33회, 문1]

01 의의 및 취지

- ① 주거이전비는 공익사업지구에 편입되는 주거용 건축물에 실제 거주하고 있는 소유자 및 세입자에 대하여 가구원수에 따라 지급하는 보상이다.
- ② 판례는 세입자들의 조기이주를 장려하여 사업추진을 원활하게 하려는 정책적인 목적과 세입자들을 대상으로 하는 사회보장적인 차원의 생활보상의 성격도 가진다고 본다.

02 소유자에 대한 보상

1) 보상평가기준

- ① 공익사업시행지구에 편입되는 주거용 건축물의 소유자에 대하여는 가구원수에 따라 2개월분의 주거이전비를 보상하여야 한다.
- ② 다만, 건축물의 소유자가 해당 건축물 또는 공익사업시행지구 내 타인의 건축물에 실제 거주하고 있지 아니하거나 해당 건축물이 무허가건축물등인 경우에는 그러하지 아니하다(칙 제54조 제1항).

2) 요건의 의미

(1) 주거용 건축물, 무허가건축물

- ① 건축물의 공부상 용도와 관계없이 실제 주거용으로 사용되는지 여부에 따라 결정해야 한다.
- ② 불법으로 주거용으로 용도변경한 건축물 소유자는 보상대상자에서 제외된다.

(2) 보상의 시기

보상시기는 주거용 건축물에 대한 보상을 하는 때이다.

(3) 실제 거주요의 요건

사업인정고시 당시 또는 공익사업을 위한 관계 법령에 의한 고시 당시 실제 거주하고 있었더라도 주거용 건축물에 대한 보상을 하는 때, 즉 이전 당시 실제 거주하고 있지 않았다면 주거이전비의 보상대상이 아니다.

03 세입자에 대한 보상

1) 보상기준

- ① 주거용 건축물의 세입자로서 사업인정고시일등 당시 또는 공익사업을 위한 관계법령에 의한 고시 등이 있을 당시 당해 공익사업시행지구 안에서 3개월 이상 거주한 자에 대하여는 가구원수에 따라 4개월분의 주거이전비를 보상하여야 한다.
- ② 다만, 무허가건축물등에 입주한 세입자로서 사업인정고시일등 당시 또는 공익사업을 위한 관계법령에 의한 고시 등이 있을 당시 그 공익사업지구 안에서 1년 이상 거주한 경우

2) 요건의 의미

- (1) 사업인정고시일등 당시 관계법령에 의한 고시 등이 있을 당시
- (2) 계속 거주요의 요건 : 불필요
- (3) 무허가건축물 등이 아닐 것

04 주거이전비에 대한 쟁송

1) 주거이전비 보상청구권의 법적성질

주거이전비 보상청구권은 공법상 권리이다.

2) 불복방법

(1) 판례의 태도

- ① 주거이전비 보상청구소송은 당사자소송에 의하여야 할 것이다.
- ② 다만, 재결이 이루어진 다음 세입자가 보상금의 증감 부분을 다투는 경우에는 공익사업법 제85조 제2항에 규정된 행정소송에 따라, 보상금의 증감 이외의 부분을 다투는 경우에는 같은 조 제1항에 규정된 행정소송에 따라 권리구제를 받을 수 있다고 봄이 상당하다.
- ③ 이러한 법리는 이주정착금, 주거이전비 및 이사비의 보상을 구하는 경우에도 그대로 적용된다.

(2) 주거이전비에 대한 수용재결을 거치지 않은 경우

주거이전비 보상청구권이 공법상 권리이므로, 주거이전비 보상을 둘러싼 쟁송은 민사소송이 아니라 <당사자 소송>에 의하여야 한다.

(3) 주거이전비에 대한 수용재결을 거친 경우

토지보상법 제83조의 이의신청 및 제85조 제2항 보상금증감청구소송이 가능하다.

3) 세대주가 아닌 가구원이 직접 주거이전비를 청구할 수 있는지 여부

가구원은 사업시행자를 상대로 직접 주거이전비의 지급을 구할 수 없다(판례).

05 주거이전비와 부동산 인도 의무

1) 문제점

피수용자는 주거이전비, 이사비, 이주정착금을 지급받지 않음을 이유로 부동산 인도 의무 이행을 거절할 수 있는지, 그리고 사업시행자는 주거이전비 등을 지급하기 위해 어떤 절차를 거쳐야 하는지 문제된다.

2) 판례

- ① 주거이전비 등에 관한 협의가 성립된다면 양자는 동시이행의 관계에 있게 되고, 재결절차 등에 의할 때에는 주거이전비 등의 지급절차가 부동산 인도에 선행되어야 할 것이다.
- ② 사업시행자는 협의나 재결절차를 거칠 필요 없이 현금청산대상자나 세입자에게 주거이전비 등을 직접 지급하거나 변제공탁을 할 수도 있다.

CASE

공공사업시행시 잔여지 및 잔여건물 보상에 관하여 설명하시오. [13회, 문4]

01 잔여 건축물의 손실에 대한 보상

1) 의의 (토지보상법 제75조의2)

사업시행자는 동일한 소유자에게 속하는 일단의 건축물의 일부가 취득되거나 사용됨으로 인하여 잔여 건축물의 가격이 감소하거나 그 밖의 손실이 있을 때에는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 그 손실을 보상하여야 한다.

2) 보상청구 기간

사업완료일로부터 1년 이내

3) 잔여 건축물 매수의 효과

사업인정 및 사업인정고시가 된 것으로 본다.

4) 보상방법 등

협의 후 협의불성립시 재결 신청

5) 보상평가기준

공익사업시행지구에 편입되기 전의 잔여 건축물의 가격에서 편입된 후의 잔여 건축물의 가격을 뺀 금액으로 평가한다.

02 잔여건축물의 보수가 필요한 경우의 보수비

보수비는 건축물의 잔여부분을 종래의 목적대로 사용할 수 있도록 그 유용성을 동일하게 유지하는데 통상 필요하다고 볼 수 있는 공사에 사용되는 비용으로 평가한다(칙 제35조 제2항).

01 개설

- ① 개간비 보상은 토지 등이 개간됨으로써 경제적 가치가 증가한 경우 그 이익을 당초 개간한 자에게 되돌려 주도록 하는 제도이다.
- ② 실비변상적 성격

02 개간비 보상

1) 보상대상이 되는 개간의 요건(칙 제27조)

(1) 국유지 또는 공유지의 개간

당해 토지가 국유지 또는 공유지이어야 한다.

(2) 적법한 개간

- ① 관계 법령에 의하여 적법하게 개간한 경우에만 보상한다.
- ② 다만, 1995년 1월 7일 당시 공익사업시행지구에 편입된 무허가개간토지에 대하여는 예외적으로 개간비를 보상하도록 하고 있다(칙 부칙 제6조).

(3) 계속 점유

개간한 자가 개간당시부터 보상당시까지 계속하여 적법하게 당해 토지를 점유하고 있어야 한다.

2) 개간비 평가 기준

- ① 개간비는 개간에 소요된 비용으로 평가한다.
- ② 그러나 보상액은 개간 후의 토지가격에서 개간 전의 토지가격을 뺀 금액을 초과하지 못한다(칙 제27조 제1항).

03 개간지에 대한 보상

취득하는 토지의 보상액은 개간 후의 토지가격에서 개간비를 뺀 금액으로 한다(칙 제27조 제3항).

01 소유권 외의 권리의 내용**02** 소유권 외 권리의 평가

취득하는 토지에 설정된 소유권 외의 권리에 대하여는 당해 권리의 종류, 존속기간 및 기대이익 등을 종합적으로 고려하여 평가한다(칙 제28조 제1항).

03 소유권 외의 권리의 목적이 되고 있는 토지의 평가1) 소유권 외의 권리가 설정된 토지2) 소유권 이외의 권리가 설정된 토지의 평가

토지의 평가금액에서 토지에 관한 소유권 외의 권리의 가액을 뺀 금액으로 평가한다(칙 제29조).

01 일반 토지의 사용료 평가1) 의의

토지사용료의 보상범위는 지표상의 토지사용만이 대상이 되는 것이 아니라, 토지의 입체적 소유권 개념에 기초하여 토지의 지상 및 지하부분의 사용을 포함하게 된다.

2) 보상기준

협의 또는 재결에 의하여 사용하는 토지에 대하여는 그 토지와 인근 유사토지의 지료·임대료·사용방법·사용기간 및 그 토지의 가격 등을 고려하여 평가한 적정가격으로 보상하여야 한다(제71조 제1항).

CASE

실농보상을 약술하시오. [1회, 문4]

01 의의 및 취지

농업손실이란 공익사업 시행으로 인하여 당해 토지가 공익사업시행지구내 편입되어 영농을 계속할 수 없게 됨에 따라 발생하는 손실로서, 농업손실보상이란 농민에게 영농손실액을 보상하는 것을 말한다.

02 농업손실보상의 성격

1) 일실손실보상

장래 기대이익의 상실에 대한 보상

2) 간접보상이자 생활보상

농민의 생계를 지원하는 <간접보상>이자 <생활보상>의 성격을 가진다.

03 보상대상

1) 물적 대상

(1) 보상대상 농지

<농지>란 법적 지목을 불문하고 실제로 농작물 경작지 또는 다년생식물 재배지로 이용되는 토지를 말한다.

(2) 보상대상이 아닌 농지

다음 어느 하나에 해당하는 토지는 보상대상인 농지로 보지 아니한다.

- ① 사업인정고시일등 이후부터 농지로 이용되고 있는 토지,
- ② 일시적으로 농지로 이용되고 있는 토지,
- ③ 타인소유의 토지를 불법으로 점유
- ④ 농민이 아닌 자가 경작
- ⑤ 토지의 취득에 대한 보상 이후에 사업시행자가 2년 이상 계속하여 경작하도록 허용하는 토지(칙 제48조 제3항).

2) 인적 대상

- ① 자경농지의 경우 농지 소유자에게 지급한다.
- ② 농지 소유자가 해당 지역에 거주하는 농민이 아닌 경우는 실제 경작자에게 보상한다(토지보상법 시행규칙 제48조 제4항).

3) 관련 판례

사업시행자가 보상금 지급이나 토지소유자 등의 승낙 없이 공사에 착수하여 영농을 계속할 수 없게 한 경우 농업손실보상과 별도로 손해배상책임이 있다(대판 2013. 11. 14. 2011다27103).

04 보상평가기준

- 1) 원칙적인 산정방법
- 2) 예외적 산정방법

05 농기구의 매각손실에 대한 보상

06 공익사업시행지구 밖의 농업손실에 대한 보상

경작하고 있는 농지의 3분의 2 이상에 해당하는 면적이 공익사업시행지구로 편입됨으로 인하여 당해 지역에서 영농을 계속할 수 없게 된 농민에 대하여는 공익사업시행지구 밖에서 그가 경작하고 있는 농지에 대하여도 영농손실액을 보상하여야 한다(칙 제65조).

PART 03

기타 개별법

Chapter 01 부동산 가격공시에 관한 법률

Chapter 02 감정평가법

Chapter 03 도정법

제1절

표준지공시지가

01 의의 및 취지

- ① 표준지의 매년 공시기준일 현재의 단위면적당 적정가격
- ② 적정한 가격형성과 각종 조세·부담금 등의 형평성을 도모하는 취지

02 법적성질

1) 문제점

표준지공시지가가 항고소송의 대상이 되는 행정소송법상의 처분인지가 문제된다.

2) 학설

(1) 행정행위설

- ① 이의신청을 할 수 있다고 규정하고 있고
- ② 과세산정의 기준이 되어 국민의 권리의무에 직접 영향을 미친다.

(2) 행정규칙설

지가 정책집행을 위해 일반적·추상적 기준을 설정

(3) 행정계획설

행정목적 실현 수단

(4) 법규명령의 성질을 갖는 고시설

행정처분의 구속력 있는 기준이 되므로 구속력은 있으나 형식은 고시로 본다.

3) 판례

판례는 공시지가에 불복하기 위해서는 공시지가 결정의 취소를 구하는 행정소송을 제기하여야 한다고 하여 처분임을 긍정하고 있다.

4) 검토

- ① 국민의 권리·의무에 영향을 미치는 후속 처분이 예정
- ② 조기에 다투어 법률관계를 확정하고 법적 안정성을 도모할 필요가 있다.

03 공시절차

1) 공시절차

- ① 표준지 선정
- ② 표준지가격의 조사·평가 및 의견청취
(조사·평가의 의뢰 → 조사·평가 → 의견청취 → 조사·평가보고서의 제출 → 적정성 검토)
- ③ 중앙부동산가격공시위원회의 심의
- ④ 지가의 공시 및 열람

2) 표준지의 선정

3) 표준지공시지가의 조사·평가

(1) 조사·평가의 의뢰

(2) 조사·평가

(3) 의견청취

a. 토지소유자의 의견청취

- ① 국토교통부장관이 표준지 소유자의 의견을 들으려는 경우
- ② 표준지 소유자에게 개별 통지해야 한다.
- ③ 이의가 있는 표준지 소유자는 의견제출기간에 의견을 제출할 수 있다.

b. 시도지사, 시장·군수·구청장의 의견청취

감정평가법인등은 조사·평가보고서를 작성하는 경우에는 미리 해당 표준지를 관할하는 시도지사 및 시장·군수·구청장의 의견을 들어야 한다.

(4) 조사·평가보고서 제출

(5) 적정성 검토

- ① 국토교통부장관은 최고평가액이 최저평가액의 1.3배를 초과하는 경우에는 해당 감정평가법인등에게 보고서를 시정하여 다시 제출하게 할 수 있다.
- ② 국토교통부장관은 제출된 보고서의 조사·평가가 관계 법령을 위반하여 수행되었다고 인정되는 경우에는, 다른 감정평가법인등 2인에게 대상 표준지공시지가의 조사·평가를 다시 의뢰해야 한다.

4) 중앙부동산가격공시위원회의 심의

5) 표준지공시지가의 공시 및 열람

(1) 공시

(2) 표준지공시지가의 열람 등

1) 이의신청

(1) 의의 및 취지 (부동산공시법 제7조)

- ① 이의신청이란 표준지공시지가에 이의가 있는 자가 공시일부터 30일 이내에 국토교통부장관에게 이의를 신청하는 것을 말한다.
- ② 이는 공시지가의 객관성을 확보하여 공신력을 높이는 데 취지가 있다.

(2) 이의신청의 성격

a. 문제점

강학상 이의신청인지 행정심판인지 그 법적성질이 문제된다.

b. 구별기준

① 심판기관기준설

행정심판은 행정심판위원회, 이의신청은 처분청에 제기한다고 보아 심판기관을 기준으로 구분하는 견해이다.

② 불복절차기준설

준사법적 절차가 보장되는 것만을 행정심판으로 보고, 그렇지 않은 것은 이의신청으로 보는 견해이다.

③ 판례

국가유공자법상의 이의신청에 대하여 <이의신청 담당기관인 처분청에서의 동일한 절차라는 점을 염두에 두고 행정심판이 아닌 이의신청>으로 보아 불복절차기준설을 취하고 있는 것으로 보인다.

④ 검토

헌법 제107조 제3항이 행정심판절차는 사법절차가 준용되어야 한다고 규정하고 있는 점을 비추어 불복절차를 기준으로 양자를 구별하는 것이 타당하다.

c. 이의신청의 성격

- ① 부동산공시법상 이의신청은 준사법적 절차를 준용하지 않으므로 강학상 이의신청으로 보는 것이 타당
- ② 판례도 [부동산공시법]에 행정심판의 제기를 배제하는 명시적인 규정이 없고, 부동산공시법에 따른 이의신청과 행정심판은 그 절차 및 담당기관에 차이가 있는 점을 고려하여, 행정심판이 아닌 이의신청으로 보았다.

(3) 제기요건

- ① <이의가 있는 자>는 <결정·공시일로부터 30일 이내>에 서면으로 신청해야 한다.
- ② 토지소유자 외에 제3자라도 법률상 이해관계가 인정되면 이의신청을 할 수 있다.

(4) 심리 등

국토교통부장관은 이의신청의 내용이 타당하다고 인정될 때에는 당해 표준지공시지가를 조정하여 다시 공시하여야 한다.

(5) 이의신청 후 제소기간(행정기본법 제36조 제4항)

이의신청에 대해 불복하고자 하는 자는 그 결과를 통지받은 날부터 90일 이내에 행정심판 또는 행정소송을 제기할 수 있다.

2) 항고소송

(1) 대상적격의 문제

표준지공시지가의 법적성질을 행정행위로 본다면 처분성이 인정된다.

(2) 원고적격의 문제

- ① 인근주민에게도 원고적격이 인정되는지가 문제된다.
- ② 부동산공시법은 이의신청인을 토지소유자로 한정하지 않고 있다.
- ③ 따라서 부동산공시법의 입법취지, 표준지공시지가의 영향범위 등을 고려할 때 인근주민에게도 표준지공시지가에 대해서 다룰 법률상 이익이 있어 원고적격이 인정된다고 봄이 타당하다.

(3) 제소기간의 문제

- ① 표준지공시지가처럼 처분 등이 공고 또는 고시로 이루어지는 경우, <처분이 있음을 안 날>의 해석이 문제된다.
- ③ 판례는 통상 고시 또는 공고에 의하여 행정처분을 하는 경우에는 그 처분의 효력이 불특정 다수인에게 일률적으로 적용되는 것이므로, 그 행정처분에 이해관계를 갖는 자가 고시 또는 공고가 있었다는 사실을 현실적으로 알았는지 여부에 관계없이 고시가 효력을 발생하는 날 행정처분이 있음을 알았다고 보아야 한다고 판시하였다.
- ④ 생각건데 판례가 타당, 따라서 표준지공시지가의 공시일(효력발생일)로부터 90일 이내에, 공시일로부터 1년 이내에 행정소송을 제기할 수 있다고 봄이 타당하다.

07 취소소송에 있어 하자승계 관련 판례

CASE

공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률상 보상금 증액청구소송을 하면서 해당 재결에 대한 선행처분으로서 수용대상 토지가격 산정의 기초가 된 표준지공시가격 결정이 위법함을 독립한 사유로 다룰 수 있는가에 관하여 논하시오. (10점) [24회 문4]

1) 하자승계를 긍정한 판례

(1) 표준지공시지와 수용재결(보증소)(예외적으로 인정)

2) 하자승계를 부정한 판례

(1) 표준지공시지와 개별공시지가

(2) 표준지공시지와 조세부과처분

01 의의 및 취지

- ① 개별토지의 단위면적당 가격을 말한다.
- ② 세금 및 각종 부담금 등의 산정을 위하여 결정·공시된다.

02 법적성질**1) 논의의 실익**

개별공시지가가 항고소송의 대상이 되는 행정소송법상의 처분인지가 문제된다.

2) 학설**(1) 행정행위설**

- ① 이익신청을 할 수 있다고 규정
- ② 조세 등의 산정기준이 되므로 국민의 구체적인 권리·의무에 직접 영향

(2) 행정규칙설

지가 정책집행을 위해 일반적·추상적 기준을 설정

(3) 행정계획설

행정목적 실현 수단

(4) 사실행위설

정보제공이라는 사실적 효과일 뿐

3) 판례

대법원은 개별토지가격 결정은 관계법령에 의한 토지초과이득세, 택지초과소유부담금 또는 개발부담금 산정의 기준이 되어 국민의 권리, 의무 내지 법률상 이익에 직접 관계되므로 행정처분이라고 본다.

4) 검토

- ① 과세처분 등의 직접적 기준이 되어 국민의 권리·의무에 직접 영향
- ② 조기에 다투어 법률관계를 확정하고 법적 안정성을 도모할 필요

03 개별공시지가의 공시절차

1) 공시절차 개요

- ① 개별공시지가의 산정
- ② 개별공시지가의 검증과 의견청취
- ③ 시·군·구 부동산가격공시위원회의 심의
- ④ 개별공시지가의 결정·공시

2) 개별공시지가의 산정

3) 개별공시지가의 검증과 의견청취

CASE

甲은 A시장이 자신의 소유 토지에 대한 개별공시지가를 결정함에 있어서 부동산 가격공시에 관한 법률에 의하여 국토교통부장관이 작성한 토지가격비준표를 고려하지 않았다고 주장한다. 이에, A시장은 토지가격비준표를 고려하지 않은 것은 사실이나, 같은 법에 따른 산정지가검증이 적정하게 행해졌으므로, 甲 소유의 토지에 대한 개별공시지가결정은 적법하다고 주장한다. A시장 주장의 타당성에 대해 검토하시오. [19회 문2]

(1) 개별공시지가의 검증 의뢰

시장·군수 또는 구청장은 개별공시지가를 결정·공시하기 위하여 개별토지의 가격을 산정할 때에는 그 타당성에 대하여 감정평가법인등의 검증을 받고 토지소유자, 그 밖의 이해관계인의 의견을 들어야 한다.(제10조 제5항)

(2) 감정평가법인등의 검증

(3) 검증의 생략

4) 토지소유자 등의 의견청취

5) 시·군·구 부동산가격공시위원회의 심의

6) 개별공시지가의 결정·공시

CASE

부동산 가격공시에 관한 법령상 개별공시지가의 정정사유에 관하여 설명하시오. (5점) [31회 문2]

1) 정정 사유

시장·군수 또는 구청장은 개별공시지가에 틀린 계산, 오기, 표준지 선정의 착오 그 밖에 대통령령이 정하는 명백한 오류가 있음을 발견한 때에는 지체 없이 이를 정정하여야 한다.

2) 정정절차

시·군·구부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 정정사항을 결정·공시하여야 한다.
(다만, 틀린 계산 또는 오기의 경우 예외)

3) 정정의 효력

당초에 결정·공시된 개별공시지가는 그 효력을 상실하고, 경정결정된 새로운 공시지가가 공시기준일에 소급하여 그 효력을 발생한다고 한다.

4) 입법적 평가

(1) 신청에 의한 정정 규정이 없는 것

- ① 개별공시지가 정정 규정에는 <신청에 의한 정정규정>이 없다.
- ② 그러나, 행정절차법(제25조)에서 신청에 따른 정정을 인정하므로, 개별공시지가 정정에서도 국민의 권익구제를 위하여 인정함이 타당하다.

(2) 소송단계에 이르지 않고 권리구제를 위한 것

5) 정정신청에 대한 행정청의 거부행위에 대한 불복가능성

- ① 거부행위가 행정쟁송법상 처분이기 위해서 판례의 요건인 공권력행사의 거부일 것, 그 거부가 신청인의 권리·의무에 영향을 미칠 것, 법규상·조리상 신청권이 있을 것의 요건과 관계된다.
- ② 특히 신청권 존부와 관련해서 판례는 정정신청권을 부정하였다.
- ③ 그러나 행정절차법 제25조에 따를 때 신청권이 인정될 수 있어 판례 태도는 비판의 여지가 있다.

6) 토지특성조사 착오가 명백한 경우만 정정결정을 할 수 있는지

(1) 관련 판례

대법원은 그 착오가 명백하여야 비로소 경정 결정할 수 있다고 해석할 것은 아니라고 판시한 바 있다.

(2) 검토

부동산공시법 시행령 제23조 제1항은 명백한 오류의 예시규정이다.

1) 이의신청

(1) 의의 및 취지 (부동산공시법 제11조)

- ① 이의신청이란 개별공시지가에 이의가 있는 자가 공시일로부터 30일 이내에 시장·군수·구청장에게 이의를 신청하는 것을 말한다.
- ② 이는 공시지가의 객관성을 확보하여 공신력을 높이는 데 취지가 있다.

(2) 성격

a. 문제점

강학상 이의신청인지 행정심판인지 문제

b. 구별기준

- ① 심판기관기준설
- ② 불복절차기준설
- ③ 판례
- ④ 검토

c. 이의신청의 성격

- ① 부동산공시법상 이의신청은 준사법적 절차를 준용하지 않으므로 강학상 이의신청으로 보는 것이 타당
- ② 판례도 [부동산공시법]에 행정심판의 제기를 배제하는 명시적인 규정이 없고, 부동산공시법에 따른 이의신청과 행정심판은 그 절차 및 담당기관에 차이가 있는 점을 고려하여, 행정심판이 아닌 이의신청으로 보았다.

(3) 제기요건

부동산공시법 제11조 제1항에서는 <이의가 있는 자>는 <결정·공시일로부터 30일 이내>에 서면으로 신청해야 한다.

(4) 심리 등

이의신청의 내용이 타당하다고 인정될 때에는 해당 개별공시지가를 조정하여 다시 결정·공시하여야 한다.

(5) 이의신청 후 제소기간 (행정기본법 제36조 제4항)

이의신청에 대해 불복하고자 하는 자는 그 결과를 통지받은 날부터 90일 이내에 행정심판 또는 행정소송을 제기할 수 있다.

2) 항고소송

(1) 대상적격의 문제

개별공시지가의 법적성질을 행정행위로 본다면 처분성이 인정된다.

(2) 원고적격의 문제

- ① 인근주민에게도 원고적격이 인정되는지가 문제된다.
- ② 부동산공시법 시행령 제22조에서 <이의신청을 하려는 자>라고 표현하고 있어 이의신청인을 토지소유자로 한정하지 않고 있다.
- ③ 생각건대, 개별공시지가의 결정·공시로 인해 법률상 이익이 침해된다면 원고적격이 인정된다고 볼 것이다.

(3) 개별공시지가의 취소소송 제소기간

CASE

A시장은 2020. 5. 20. 甲의 토지의 개별공시지가를 1㎡당 839만원으로 결정·공시하고, 甲에게 개별 통지하였다.

甲은 토지가격비준표에 제시된 토지특성에 기초한 가격배율을 무시하고 乙이 감정평가방식에 따라 독자적으로 지가를 산정하여 제시한 검증의견을 그대로 반영하여 개별공시지가를 결정한 것은 위법하다고 보아, 「부동산 가격 공시에 관한 법률」 제11조에 따라 2020. 6. 15. 이의신청을 제기하였고, 2020. 7. 10. 이의를 기각하는 내용의 이의신청결과가 甲에게 통지되었다.

甲은 2020. 9. 10. 개별공시지가결정에 대해 취소소송을 제기하였다. 甲이 제기한 취소소송은 제소기간을 준수하였는가? (10점) [32회 문2 변형]

a. 문제점

개별통지를 받았다면, 그때부터 90일 이내에 취소소송을 제기하여야 하나, 개별통지를 하지 않은 경우 처분이 있음을 안 날을 언제로 보아야 할지 문제된다.

b. 판례

개별토지가격결정 처분의 효력은 각각의 토지 또는 소유자에 대하여 발생하는 것이므로, 행정심판의 청구기간은 처분 상대방이 실제로 처분이 있음을 안 날로부터 기산하여야 할 것이고, 처분을 있음을 알았다고 볼 만한 사정이 없는 경우에는 처분이 있는 날로부터 180일 이내에 제기하면 된다고 판시하였다.

c. 검토

- ① 생각건데, 개별공시지가는 표준지공시지가와 달리 불특정 다수인에 대해서가 아니라 개별 토지에 대해서 효력이 발생하는 것이므로, 개별공시지가의 공고 또는 고시일에 처분의 상대방이 처분이 있음을 알았다고까지는 볼 수 없을 것이다.
- ② 따라서 개별공시지가결정을 현실적으로 안 날로부터 90일, 공고 또는 고시일로부터 1년 이내에 행정소송을 제기할 수 있다고 봄이 타당하다.

06 취소소송에 있어 하자승계 관련 판례

CASE

甲이 개별공시지가결정에 대해 다투지 않은 채 제소기간이 도과하였고, 이후 甲의 토지에 대해 수용재결이 있었다.

甲이 보상금의 증액을 구하는 소송에서 개별공시지가결정의 위법을 주장하는 경우, 甲의 주장은 인용될 수 있는가? (20점) [32회 문2]

1) 하자승계를 인정한 판례

- ① (개별통지가 없는) 개별공시지가와 과세처분

2) 하자승계를 부정한 판례

- ① 표준지공시지가와 개별공시지가
- ② (재조사청구에 따른 조정결정을 통지받은) 개별공시지가와 과세처분 사이

07 개발부담금 처분의 하자치유

1) 문제점

개발부담금 부과 이후 개별공시지가의 하자치유가 인정되는지 문제된다.

2) 판례

대법원은 그 하자의 치유를 인정하면 개발부담금 납부의무자로서는 위법한 처분에 대한 가산금 납부의무를 부담하게 되는 등 불이익이 있을 수 있으므로 허용되지 않는다고 판시하였다.

3) 검토

개발부담금 납부의무자로서는 위법한 처분에 대한 가산금 납부의무를 부담하게 되는 등 불이익이 있을 수 있으므로, 허용되지 않는다고 봄이 타당하다.

CASE

B토지소유자는 토지가격비준표와 달리 결정된 개별공시지가결정은 위법하다고 주장한다. 이 주장은 타당한가?
(20점) [29회 3번]

01 의의 및 취지 (법 제3조 제8항)

- ① 토지가격비준표란 표준지와 개별토지의 지가형성요인에 관한 표준적인 비교표이다.
- ② 개별토지의 대량평가를 위하여 작성된 객관적인 지가산정표이다.

02 법적 성질

1) 문제점

토지가격비준표는 행정규칙의 형식이나, 부동산공시법 제3조 제8항 등에 근거가 되는 법령의 규정이 있어 그 법적성질이 문제된다.

2) 학설

- (1) 법규명령설 (실질설)
- (2) 행정규칙설 (형식설)
- (3) 수권여부기준설
- (4) 규범구체화 행정규칙설

3) 판례

〈대법원〉은 토지가격비준표는 법령 보충적인 구실을 하는 법규적 성질을 가지고 있는 것으로 보아야 한다고 판시하여 법규성이 있다고 보았다.

4) 검토

토지가격비준표는 부동산공시법과 결합하여 상위법령을 보충*구체화 하는 기능이 있으므로 법규명령으로 봄이 타당하다.

※ 보충자료 - 표준지 조사평가기준

- ① 의의 : 국토교통부 훈령 형식으로 제정되었으며, 「부동산공시법」 시행령 제6조 제3항에 위임 규정이 있다.
- ② 법적성질 : 법령보충적행정규칙으로서 법규명령의 성질을 가진다.

03 하자와 권리구제

1) 문제점

토지가격비준표의 작성과 활용에 하자가 있을 경우, 개별공시지가에 대한 취소소송이나 손해배상청구소송을 제기할 수 있는지가 문제된다.

2) 작성상의 하자

판례는 비준표상의 토지의 특성 및 평가요소 등이 추가 또는 제외됨으로 인하여 가격상승 또는 가격하락이 있게 되었다는 것만으로는 개별토지가격결정이 부당하다고 하여 이를 다룰 수 없다고 하였다.

3) 활용상의 하자

- ① 일부항목만 적용하면 위법
- ② 토지가격비준표 적용하지 않고 결정한 개공은 위법
- ③ 주용도에 대한 조정률 적용해야 함
- ④ 토지가격비준표를 사용하여 산정한 지가와 달리 결정되어도 위법하지 않음

시장 등은 표준지공시지가에 토지가격비준표를 사용하여 산정된 지가와 감정평가업자의 검증의견 및 토지소유자 등의 의견을 종합하여 당해 토지에 대하여 표준지공시지와 균형을 유지한 개별공시지를 결정할 수 있고, 그와 같이 결정된 개별공시지가가 표준지공시지와 균형을 유지하지 못할 정도로 현저히 불합리하다는 등의 특별한 사정이 없는 한, 결과적으로 토지가격비준표를 사용하여 산정한 지가와 달리 결정되었거나 감정평가사의 검증의견에 따라 결정되었다는 이유만으로 그 개별공시지가 결정이 위법하다고 볼 수는 없다.(대법원 2013. 11. 14. 선고 2012두15364)

제4절

부동산가격공시위원회

CASE

부동산 가격공시에 관한 법령상 중앙부동산가격공시위원회에 관하여 설명하시오. (10점) [29회 문4]

01 의미 및 근거

표준지, 개별공시지가 및 공동주택 공시에 관한 사항을 심의·의결하기 위한 위원회로 부동산가격공시법 제24, 25조 등에 근거를 둔다.

02 종류

- ① 국토교통부장관 소속의 중앙부동산가격공시위원회와
- ② 시장·군수 또는 구청장 소속의 시·군·구 부동산가격공시위원회가 있다.

03 심의사항

- 1) 중앙부동산가격공시위원회
- 2) 시·군·구 부동산가격공시위원회

04 위원회 구성 및 의결 방법

- 1) 중앙부동산가격공시위원회
- 2) 시군구 부동산가격공시위원회

제5절

타인토지출입

01 의미

관계 공무원 또는 부동산가격공시업무를 의뢰받은 자(이하 “관계공무원등”이라 한다)는 표준지가격의 조사·평가 또는 개별토지가격의 산정을 위하여 필요한 때에는 타인의 토지에 출입할 수 있다.(법 제13조 제1항)

02 출입절차 및 제한 등

03 토지보상법상 타인토지출입과의 비교

CASE

토지보상법상 타인토지출입과 부동산공시법상 타인토지출입을 비교하시오.

1) 공통점

(1) 법적성질

권력적 사실행위로서 행정조사

(2) 출입 제한 및 증표 등 제시

2) 차이점

(1) 입법취지

- ① 토지보상법 : 공익사업의 준비 목적
- ② 부동산공시법 : 공시지가의 조사·평가를 위한 목적

(2) 보상규정

- ① 토지보상법 : 손실보상 규정 있음
- ② 부동산공시법 : 손실보상 규정 없어 논란

(3) 토지점유자의 인용의무

- ① 토지보상법 : 인용의무 있고 위반시 벌칙규정 있음
- ② 부동산공시법 : 인용의무 없고 위반시 벌칙규정 없음

(4) 부동산공시법상 타인토지 출입시 손실보상 가능여부

a. 문제점

타인토지출입으로 특별한 희생이 발생한 경우 손실보상이 이루어져야 하나, 보상규정이 없어 손실보상이 가능한지 문제된다.

b. 보상규정 흠결시 보상청구 가능성

(손실보상 파트 참조 요망)

제6절

주택가격공시제도(생략)

제1절

감정평가사의 법적지위

CASE

감정평가사의 의무와 책임을 설명하여라. [2회 문2]

01 개설

02 권리 및 의무

1) 권리

2) 의무

※ 보충자료 - 감정평가법 제25조의 성실의무

1. 품위유지 및 신의성실의무
2. 불공정한 감정평가 금지
3. 토지등의 매매업 금지
4. 금품수수 금지
5. 중복소속 금지
6. 감정평가 유도, 요구에 따른 평가 금지

3) 책임

(1) 행정상 책임

- ① 자격의 취소 (감정평가법 제13조 제1항)
부정한 방법으로 감정평가사의 자격을 받은 경우 및 자격의 취소징계를 받은 경우
- ② 징계 (동법 제39조)
자격의 취소, 등록의 취소, 2년 이하의 업무정지, 견책의 징계
- ③ 과태료 (동법 제52조)
500만원 이하의 과태료를 부과

(2) 형사상 책임

- ① 행정형벌 (동법 제49조 및 50조)
제49조 및 제50조에 따라 징역 또는 벌금
- ② 공무원 의제처벌(동법 제48조)

(3) 민사상 책임 (손해배상책임)

※ 보충자료 - 감정평가의 법률관계

- ① 감정평가 의뢰는 당사자가 상호 대등한 지위에서 이루어지는 것으로 사법상 관계의 성질을 가진다.
- ② 일정한 사무처리를 위한 통일적 노무의 제공을 목적으로 하는 위임계약에 해당한다.

03 감정평가법 제28조와 민법 제750조의 관계(제28조의 법적 성질)

1) 문제점

감정평가법 제28조의 규정이 민법 제750조의 손해배상책임을 배제하는 특칙인지가 문제된다.

[감정평가법] 제28조 (손해배상책임)

- ① 감정평가법인등이 감정평가를 하면서 고의 또는 과실로 감정평가 당시의 적정가격과 현저한 차이가 있게 감정평가를 하거나 감정평가 서류에 거짓을 기록함으로써 감정평가 의뢰인이나 선의의 제3자에게 손해를 발생하게 하였을 때에는 감정평가법인등은 그 손해를 배상할 책임이 있다.

[민법] 제750조 (불법행위의 내용)

고의 또는 과실로 인한 위법행위로 타인에게 손해를 가한 자는 그 손해를 배상할 책임이 있다.

2) 학설

(1) 특칙이라는 견해 (면책설)

감정평가수수료에 비해 손해배상책임이 지나치게 크고, 부동산은 그 특성상 적정가격을 파악하는 것이 매우 어려워 감정평가법인등을 보호할 필요가 있다.

(2) 특칙이 아니라는 견해 (보험관계설)

감정평가법 제28조 제1항의 손해배상규정은 보험금이나 공제금의 지급대상이 되는 손해배상책임의 범위를 한정된 것일 뿐이다.

3) 판례

판례는 감정평가법인등의 부실감정으로 인하여 손해를 입게 된 감정평가의뢰인이나 선의의 제3자는 감정평가법상 손해배상책임과 민법상의 불법행위로 인한 손해배상책임을 함께 물을 수 있다고 판시한 바 있다.(대법원 97다36293)

4) 검토

감정평가에 의한 적정가격의 산정이 어려움에도 손해배상책임을 널리 인정하면 평가제도가 위태로울 수 있으므로 <특칙>으로 봄이 합당하다.

CASE

감정평가 및 감정평가사에 관한 법률상 감정평가법인등의 손해배상책임의 성립요건에 관하여 설명하시오. [33회 문4]

1) 감정평가를 하면서

- ① 감정평가는 가치판단작용을 말하며, 단순한 사실조사의 잘못은 그 배상책임이 없다.
- ② 다만, 판례는 임대차 사실관계 조사상 과실을 이유로 배상책임을 인정한바 있다.(2003다24840)

2) 고의 또는 과실이 있을 것

- ① 고의란 부당한 감정평가로 인한 손해의 발생을 인식하는 것을 말하고,
- ② 과실이란 손해의 발생을 부주의로 인식하지 못하는 것을 말한다(주의의무위반).

3) 부당한 감정평가를 하였을 것

(1) 적정가격과 현저한 차이가 있을 것

판례는 현저한 차이를 인정함에 있어 1.3배가 유일한 판단기준이 될 수 없고, 부당감정에 이르게 된 감정평가 법인등의 귀책사유를 고려하여 사회통념에 따라 탄력적으로 판단해야 한다고 판시했다.(96다52427)

(2) 거짓의 기재

감정평가서에 사실과 다르게 거짓으로 기재하는 것을 말한다.

4) 의뢰인 또는 선의의 제3자에게 손해가 발생하였을 것

5) 상당 인과관계가 있을 것

부당한 감정평가와 손해발생 사이에 상당인과관계가 있어야 한다.

6) 위법성 요건이 필요한지 여부

- ① 감정평가법 제28조 제1항의 손해배상책임의 요건에 위법성이 명시되어 있지 않아 위법성 요건이 별도로 필요한지가 문제된다.
- ② 생각건대, 명시적 규정이 없는 위법성의 요건은 별도로 필요하지 않고, 부당한 감정평가의 개념 속에 위법성 요건이 포함되어 있는 것으로 보는 것이 타당하다.

05 손해배상책임의 내용

1) 손해배상의 범위

손해배상의 범위는 위법행위가 없었더라면 존재하였을 재산 상태와 위법행위가 가해진 현재의 재산 상태의 차이를 말한다.

2) 손해배상책임의 보장 (동법 제28조 제2항)

보험가입이나 공제사업에 가입하는 등 필요한 조치를 해야 한다.

〈 감정평가법인등의 법적지위 〉

구분	내용	비고
권리	감정평가권	감정평가법 제4조
	타인토지 출입권	부동산공시법 제13조
	명칭사용권	감정평가법 제22조 제1항
	보수청구권	감정평가법 제23조
	청문권	감정평가법 제45조[자격취소, 인가취소, 다만, 제39조 제2항(징계)의 자격취소에 대해서는 청문 규정 없음]
	과징금에 대한 이의신청권	감정평가법 제42조
	행정쟁송 제기권	
의무	적정가격 평가의무	부동산공시법 제1조, 감정평가법 10조
	감정평가서 교부 및 보존의무	감정평가법 제6조
	고용인의 신고	감정평가법 제21조의2
	성실의무 등	감정평가법 제25조
	비밀엄수	감정평가법 제26조
	명의대여 등의 금지	감정평가법 제27조
	국토교통부장관의 지도·감독에 따를 의무	감정평가법 제47조
책임	민사상 손해배상책임	감정평가법 제28조
	행정상 인가취소, 업무정지	감정평가법 제32조
	행정상 징계	감정평가법 제39조
	행정상 과징금 관련 책임	감정평가법 제41조
	행정상 과태료 관련 책임	감정평가법 제52조
	형사상 행정형벌 관련 책임	감정평가법 제49조 내지 제50조의 2

01 자격등록의 의의 및 취지 (감정평가법 제17조)

- ① 자격등록이란 감정평가사 자격이 있는 자가 업무를 하기 위해 국토교통부장관에게 등록신청을 하고, 국토교통부장관이 이를 유효한 것으로 받아들이는 것을 말한다.
- ② 감정평가사의 효율적 관리 및 감정평가사 자격에 대한 신뢰성 제고에 취지

02 법적 성질

1) 등록신청

사인의 공법행위로서 수리를 요하는 신고에 해당

2) 자격등록의 법적 성질

(1) 강학상 수리 여부

- ① 강학상 허가로 보는 견해와 강학상 수리로 보는 견해가 있다.
- ② 허가는 실질적 심사를 하는 것이 원칙이나, 수리는 형식적 심사를 하되 필요 시에는 실질적 심사까지 할 수 있고, 신고요건이 허가요건보다 완화되어 있다는 점에서 양자가 구별된다.
- ③ 생각건대, 국토교통부장관은 감정평가사 자격등록 신청에 대하여 감정평가법 제18조 제1항에서 정한 등록거부사유가 없는 이상 등록을 해야 하고, 법규정 외의 사유를 들어 등록을 거부할 수 없으므로, 허가보다는 완화된 요건으로 보아 강학상 수리로 봄이 타당하다.

(2) 기속행위

강학상 수리는 법이 정한 특별한 사정이 없는 한 소정의 요건을 갖춘 신고는 반드시 수리하여야 하므로 기속행위의 성질을 가진다.

03 등록거부사유 (동법 제18조 제1항)**[감정평가법] 제18조 (등록 및 갱신등록의 거부)**

- ① 국토교통부장관은 제17조에 따른 등록 또는 갱신등록을 신청한 사람이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 등록을 거부하여야 한다.
 - 1. 제12조 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우
 - 2. 제17조제1항에 따른 실무수습 또는 교육연수를 받지 아니한 경우
 - 3. 제39조에 따라 등록이 취소된 후 3년이 지나지 아니한 경우
 - 4. 제39조에 따라 업무가 정지된 감정평가사로서 그 업무정지 기간이 지나지 아니한 경우
 - 5. 미성년자 또는 피성년후견인 · 피한정후견인

04 등록의 효과 및 등록증 발급

- ① 국장은 등록을 하면 신청인은 감정평가업무를 수행할 수 있는 지위를 얻게 된다.
- ② 감정평가업무를 수행할 수 있는 자임을 공적으로 증명하는 공증에 해당

05 등록거부에 대한 권리구제

1) 국토교통부장관의 거부 등

국장은 등록거부사유에 해당하는 경우 등록 또는 갱신등록을 거부하여야 한다.

2) 등록거부에 대한 권리구제

- ① 거부처분에 대한 행정쟁송으로 권리구제
- ② 위법한 등록거부로 인하여 손해가 발생한 경우에는 국가배상을 청구도 가능

06 갱신등록과 관련한 논의

(행정법 교재 참고 요망)

I

사무소 개설

CASE

감정평가 및 감정평가사에 관한 법률 제21조에 따른 '사무소 개설 등'에 관하여 설명하시오. [34회 문4]

01 의의 (감정평가법 제21조 제1항)

사무소 개설이란 감정평가법 제17조에 따라 등록을 한 감정평가사가 감정평가업을 하려는 경우 사무소를 개설하는 것을 말한다.

02 사무소 개설이 금지된 자 (동법 제21조 제2항)

03 합동사무소의 개설

합동사무소는 대통령령으로 정하는 수(2명) 이상의 감정평가사를 두어야 한다.

04 복수개설 금지

1개의 사무소만을 설치할 수 있다.

05 소속 감정평가사

- ① 소속 감정평가사는 등록거부사유에 해당하는 사람이 아니어야 하며,
- ② 소속 감정평가사가 아닌 사람에게 제10조에 따른 업무를 하게 하여서는 아니 된다.

CASE

A 등은 감정평가법인을 설립하여 국토교통부장관의 설립인가를 받았다. 설립인가 자체의 하자는 없지만, 감정평가법인의 사원에 관한 「감정평가및 감정평가사에 관한 법률」의 요건을 충족하지 못하여 설립행위에 문제가 있음을 확인한 경쟁업체의 감정평가사 甲은 소송을 통하여 이를 다투고자 한다. 이러한 감정평가법인의 설립행위와 인가행위의 관계를 설명하고, 甲은 어떠한 소송에서 어떠한 하자를 다룰 수 있는지 검토하시오. [36회 문4]

01 개설

감정평가법인을 설립하려는 경우에는 사원이 될 사람 또는 감정평가사인 발기인이 공동으로 정관을 작성하여 국토교통부장관의 인가를 받아야 한다.

02 인가와 기본행위(설립행위)

1) 인가의 개념

인가란 행정청이 제3자의 법률행위를 동의로써 보충하여 그 행위의 효력을 완성시키는 행정행위를 말한다.

2) 인가와 기본행위(설립행위)의 관계

- ① 인가는 기본행위의 효력을 완성시키는 보충적 행위이므로 인가의 효력은 기본행위의 유무 및 하자에 의해 영향을 받는다.
- ② 따라서 기본행위가 소멸되면 인가는 별도의 무효선언이나 처분청의 직권취소 없이도 실효된다.
- ③ 다만, 기본행위에 취소원인이 있는 경우에는 기본행위가 취소되지 않은 한 인가의 효력에는 영향이 없다.

03 기본행위의 하자를 이유로 인가를 다룰 협의의 소익이 있는지

1) 문제점

기본행위의 하자를 이유로 인가를 다룰 협의의 소익이 있는지 문제된다.

2) 학설

- ① 동일사안을 이중으로 심리해야 하는 법원의 부담을 덜고, 기본행위에 대한 분쟁은 기본행위를 관할하는 법원으로 집중시키기 위해 부정하는 견해(다수설)
- ② 반면, 일회적 분쟁해결을 위해 협의의 소익을 인정해야 한다는 견해도 있다.

3) 판례

판례는 인가처분에 하자가 없다면 기본행위의 무효를 내세워 행정청의 인가처분의 취소 또는 무효확인을 구할 법률상 이익이 있다고 할 수 없다고 하여 소극적인 입장이다.(대법원 1994. 10. 14. 선고 93누22753 판결)

4) 검토

취소소송을 담당하는 법원이 인가처분취소소송에서 민사소송 등의 사항인 기본행위 하자를 심리하기는 어렵다고 보아야 하므로, 부정하는 견해가 타당하다.

04 인가행위에 하자가 있는 경우

인가처분의 무효나 취소를 주장할 수 있다.

Ⅲ **사무직원 고용 신고**

01 사무직원 고용 신고

감정평가법인등은 소속 감정평가사 또는 사무직원을 고용하거나 고용관계가 종료된 때에는 국토교통부장관에게 신고하여야 한다.

02 고용 신고의 법적 성질

국토교통부장관은 사무직원이 결격사유에 해당하는지 여부를 확인해야 하므로 수리를 요하는 신고에 해당한다.

01 징계

1) 의의, 취지, 법적 성질

감정평가사가 징계사유에 해당하는 경우 국토교통부장관이 감정평가관리·징계위원회의 의결에 따라 해당 감정평가사를 제재하는 것을 말한다.

2) 종류

① 자격의 취소, ② 등록의 취소, ③ 2년 이하의 업무정지, ④ 견책

02 감정평가관리·징계위원회

1) 감정평가관리·징계위원회 도입배경 및 취지

징계의 공정성을 확보

2) 감정평가관리·징계위원회의 법적 성격

합의제 행정기관, 필수기관, 의결기관

3) 구성

4) 위원의 임기 및 제척, 기피

03 징계의 절차

CASE

甲은 감정평가사 자격을 취득한 후, 2015. 9. 2.부터 2017. 8. 3.까지 '乙감정평가법인'의 소속 감정평가사였다. 또한 甲은 2015. 7. 7.부터 2017. 4. 30.까지 '수협'에서 상근계약직으로 근무하였다. 관할 행정청인 국토교통부장관 A는 甲이 위와 같이 수협에 근무하면서 일정기간 동안 동시에 乙감정평가법인에 등록하여 소속을 유지하는 방법으로 감정평가사 자격증을 대여하거나 부당하게 행사했다고 봄이 상당하여, [감정평가법] 제27조가 규정하는 명의대여 등의 금지 또는 자격증 부당행사 금지에 위반하였다는 것을 이유로 징계처분을 내리고자 한다. 국토교통부장관 A가 甲에 대하여 위와 같은 사유로 감정평가법령상의 징계를 하고자 하는 경우, 징계절차에 관하여 설명하시오. [29회 문2]

징계의결 요구 ➡ 징계위원회 의결 ➡ 국토교통부장관의 징계 처분 ➡ 징계사실을 당사자와 협회에 통보
➡ 징계의 공고

- ① 국토교통부장관은 감정평가사에게 징계사유가 있다고 인정되면, 감정평가관리·징계위원회에 징계의결을 요구해야 한다.
- ② 감정평가사협회는 국토교통부장관에게 징계를 요청할 수 있다.

2) 의결

- ① 감정평가관리·징계위원회는 징계의결의 요구를 받으면 지체 없이 징계요구 내용과 징계심의기일을 해당 감정평가사에게 통지해야 한다.
- ② 당사자는 징계위원회에 출석하여 구술 또는 서면으로 자기에게 유리한 사실을 진술하거나 필요한 증거를 제출할 수 있다.

3) 징계

국토교통부장관은 감정평가관리·징계위원회의 의결에 따라 징계처분을 한다.

4) 징계사실의 통보

국토교통부장관은 징계를 한 때에는 지체 없이 그 구체적인 사유를 해당 감정평가사 등에게 서면으로 알려야 한다.

5) 징계의 공고

(1) 공고의 방법

국토교통부장관은 그 내용을 대통령령으로 정하는 바에 따라 관보 또는 인터넷 홈페이지 등에 게시 또는 공고하여야 한다.

(2) 공고의 내용 및 기간

공고의 내용에는 징계처분을 받은 감정평가사의 이름, 징계처분의 내용, 징계사유 및 징계처분의 효력발생일 등이 포함된다.

04 징계의결의 하자

1) 의결에 반하는 처분

징계위원회의 의결에 반하는 처분은 무효

2) 의결을 거치지 않은 처분

징계위원회의 의결을 거치지 않고 처분을 한다면 무효

05 징계에 대한 권리구제

- ① 처분이므로 행정쟁송 가능
- ② 위법한 징계처분에 대해 국가배상청구도 가능

06 징계 공고(제39조의2)의 처분성

1) 의의

명단의 공표란 행정법상의 의무 위반 또는 의무불이행이 있는 경우에 그 위반자의 성명, 위반사실 등을 일반에게 공개하여 명예 또는 신용에 침해를 가함으로써 심리적인 압박을 가하여 행정법상의 의무이행을 확보하는 간접강제 수단을 말한다.

2) 처분성 여부

(1) 문제점

징계의 공고가 항고소송의 대상인 처분에 해당하는지 문제된다.

(2) 학설

- ① 수인의무를 수반하지 않으므로 비권력적 사실행위
- ② 공표행위는 일방적으로 행해지고 그로 인하여 명예, 신용 등이 침해되므로 권력적 사실행위
- ③ (안중요-삭제)

(3) 판례

판례는 병무청장이 병역의무 기피자의 인적사항 등을 인터넷 홈페이지에 게시한 것을 항고소송의 대상인 행정처분으로 판시하였다.

(4) 검토

- ① 원칙적으로 명단공개 자체는 사실행위
- ② 그러나 예외적으로 공표의 내용이 처분의 실질을 담고 있다면 처분성을 긍정함이 타당

07 징계정보 열람 (시행령 제36조의2)

1) 의의 및 근거

감정평가를 의뢰하려는 자는 협회에 징계정보의 열람을 신청할 수 있다.

2) 열람 신청의 방법

3) 협회의 징계 정보의 제공

CASE

감정평가사 甲은 A법인에 형식적으로만 적을 두었을 뿐 A법인에서 감정평가사 본연의 업무를 전혀 수행하지 않았고 그 법인의 운영에도 관여하지 않았다. 이에 대해 국토교통부장관은 감정평가관리·징계위원회의 의결에 따라 사전통지를 거쳐 감정평가사 자격취소처분을 하였다. 처분사유는 '甲이 A법인에 소속만 유지할 뿐 실질적으로 감정평가업무에 관여하지 아니하는 방법으로 감정평가사의 자격증을 대여하였다'는 것이었고, 그 법적 근거로 감정평가법 제27조 제1항, 제39조 제1항 단서 및 제2항 제1호가 제시되었다.

甲은 사전통지서에 기재된 의견제출 기한 내에 청문을 신청하였으나 국토교통부장관은 '감정평가법 제13조 제1항 제1호에 따라 감정평가사 자격취소를 하려면 청문을 실시하여야 한다는 규정이 있지만, 명의대여를 이유로 하는 감정평가사 자격취소의 경우에는 청문을 실시하여야 한다는 규정이 없을 뿐 아니라 청문을 실시할 필요도 없다'는 이유로 청문을 실시하지 않았다.

甲에 대한 감정평가사 자격취소처분이 적법한지 설명하시오. [33회 문3]

1) 문제점

감정평가법 제45조에서는 징계로서 자격취소처분을 받는 경우를 청문 사유로 규정하고 있지 않으므로, 이 경우 청문을 생략할 수 있는지 문제된다.

제45조 (청문)

국토교통부장관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 처분을 하려는 경우에는 청문을 실시하여야 한다.

1. 제13조제1항제1호에 따른 감정평가사 자격의 취소
2. 제32조제1항에 따른 감정평가법인의 설립인가 취소

2) 청문 요건 (행정절차법 제22조)

- ① 다른 법률등에서 청문을 하도록 규정하고 있는 경우,
- ② 행정청이 필요하다고 인정하는 경우,
- ③ 인허가 등의 취소, 신분·자격의 박탈, 법인이나 조합 등의 설립허가의 취소의 처분을 하는 경우 행정청은 청문을 한다.

[행정절차법]

제22조 (의견청취)

① 행정청이 처분을 할 때 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 청문을 한다.

1. 다른 법령등에서 청문을 하도록 규정하고 있는 경우
2. 행정청이 필요하다고 인정하는 경우
3. 다음 각 목의 처분을 하는 경우
 - 가. 인허가 등의 취소
 - 나. 신분·자격의 박탈
 - 다. 법인이나 조합 등의 설립허가의 취소

3) 예외 사유

- ① 긴급히 처분을 할 필요가 있는 경우
- ② 반드시 일정한 처분을 하여야 하는 경우
- ③ 의견청취가 현저히 곤란하거나 명백히 불필요한 경우
- ④ 당사자가 의견진술의 기회를 포기한다는 뜻을 명백히 표시한 경우

4) 검토

- ① 행정절차법 제22조 제1항 제3호는, 자격을 박탈하는 처분은 청문을 실시한다고 규정
- ② 따라서 행정절차법 등 관련 법령상 청문을 실시하지 않아도 되는 예외적인 경우에 해당하지 않는 한, 반드시 청문을 실시하여야 한다.(취소사유)

[감정평가법]

제13조 (자격의 취소)

- ① 국토교통부장관은 감정평가사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 자격을 취소하여야 한다.
 - 1. 부정한 방법으로 감정평가사의 자격을 받은 경우
 - 2. 제39조제2항제1호에 해당하는 징계를 받은 경우

제27조 (명의대여 등의 금지)

- ① 감정평가사 또는 감정평가법인등은 다른 사람에게 자기의 성명 또는 상호를 사용하여 제10조에 따른 업무를 수행하게 하거나 자격증·등록증 또는 인가증을 양도·대여하거나 이를 부당하게 행사하여서는 아니 된다.

제39조 (징계)

- ① 국토교통부장관은 감정평가사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제40조에 따른 감정평가관리·징계위원회의 의결에 따라 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 징계를 할 수 있다. 다만, 제2항제1호에 따른 징계는 제11호, 제12호에 해당하는 경우 및 제27조를 위반하여 다른 사람에게 자격증·등록증 또는 인가증을 양도 또는 대여한 경우에만 할 수 있다.

(생략)

- 11. 감정평가사의 직무와 관련하여 금고 이상의 형을 선고받아(집행유예를 선고받은 경우를 포함한다) 그 형이 확정된 경우
- 12. 이 법에 따라 업무정지 1년 이상의 징계처분을 2회 이상 받은 후 다시 제1항에 따른 징계사유가 있는 사람으로서 감정평가사의 직무를 수행하는 것이 현저히 부적당하다고 인정되는 경우

01 감정평가

1) 의의와 기준

2) 감정평가 실무기준 (제3조 제4항 등)

02 감정평가서의 심사과 검토제도

1) 개설 (감정평가서)

2) 감정평가서 심사

(1) 의의 및 취지 (제7조 제1항)

감정평가법인은 감정평가서를 의뢰인에게 발급하기 전에 감정평가를 한 소속 감정평가사가 작성한 감정평가서의 적정성을 같은 법인 소속의 다른 감정평가사에게 심사하게 하고, 그 적정성을 심사한 감정평가사로 하여금 감정평가서에 그 심사사실을 표시하고 서명과 날인을 하게 하여야 한다.

(2) 감정평가서 심사의 기준과 의무

감정평가서의 적정성을 심사하는 감정평가사는 감정평가서가 감정평가법 제3조에 따른 원칙과 기준을 준수하여 작성되었는지 여부를 신의와 성실로써 공정하게 심사하여야 한다.(법 제7조 제2항)

03 감정평가서 검토제도 (적정성검토 의뢰)

1) 의의 및 취지 (제7조 제3항)

감정평가 의뢰인 등이 발급된 감정평가서의 적정성에 대한 검토를 일정한 기준을 충족하는 감정평가법인등에게 (해당 감정평가서를 발급한 감정평가법인등은 제외한다) 의뢰하는 것을 말한다.

2) 법적성격 및 효력

감정평가 재평가로 보기 어렵고 감정평가와 관련된 <상담 및 자문> 등의 성격

3) 적정성검토 의뢰인 (시행령 제7조의2 제1항)

4) 적정성검토를 할 수 있는 자 (시행령 제7조의2 제2항)

5) 검토절차 (시행령 제7조의3)

6) 적정성 검토결과의 통보 (시행령 제7조의4)

04 타당성 조사

1) 의의 및 취지 (제8조)

국토교통부장관은 감정평가서가 발급된 후 해당 감정평가가 감정평가법 등의 절차와 방법 등에 따라 타당하게 이루어졌는지를 직권으로 또는 관계 기관 등의 요청에 따라 조사하는 것을 말한다.

2) 실시 및 중지사유 (시행령 제8조 제1, 2항)

3) 절차 등 (시행령 제8조 제4항 내지 6항)

05 감정평가 제도개선을 위한 표본조사와 정보체계의 구축

1) 의의, 근거 및 취지 (제8조 제4항)

국토교통부장관은 감정평가의 방법·절차 등과 실제 감정평가서의 작성 간에 차이가 있는지 여부를 확인하여 감정평가제도를 개선하기 위해 표본조사를 할 수 있다.

2) 표본조사의 방법과 결과 활용

3) 감정평가 정보체계의 구축·운용 (제9조)

01 과징금**1) 제도의 도입 취지 및 근거****2) 과징금 제도****(1) 의의**

과징금이란 행정법규의 위반이나 행정법상의 의무 위반으로 경제상의 이익을 얻게 되는 경우엔 당해 위반으로 인한 경제적 이익을 박탈하기 위하여 그 이익액에 따라 행정기관이 과하는 행정상 제재금이다.

(2) 변형된 과징금

- ① 영업정지처분에 갈음하여 과징금을 부과할 수 있도록 규정하고 있는 경우 영업정지에 갈음하여 부과되는 과징금을 변형된 과징금이라 한다.
- ② 영업정지로 인해 초래될 공익에 대한 침해 등 문제를 고려하여, 영업정지처분을 대신하여 영업으로 인한 이익을 박탈하는 과징금을 부과할 수 있도록 한 것이다.

(3) 법적성질

- ① 금전급부하명으로서 침익적 처분 ② 재량행위

3) 과징금의 성질 및 이중부과 가능성

행정법규 위반에 대하여 벌금이나 범칙금 이외 과징금을 부과하는 것은 이중처벌금지의 원칙에 반하지 않는다. 헌법재판소도 같은 입장이다.

4) 감정평가법상 과징금의 부과 및 징수**(1) 과징금의 부과 (제41조 제1항 및 제2항)**

- ① 국토교통부장관은 업무정지처분이 표준지공시지가의 조사·평가 등의 업무를 정상적으로 수행하는 데에 지장을 초래하는 등 공익을 해칠 우려가 있는 경우에는 업무정지처분에 갈음하여 과징금을 부과할 수 있다.
- ② 국토교통부장관은 과징금을 부과하는 경우 위반행위의 내용과 정도, 위반행위의 기간과 위반횟수, 위반행위로 취득한 이익의 규모를 고려하여야 한다.

(2) 과징금의 승계 (제41조 제3항)**(3) 과징금의 징수 및 체납처분 (제44조)**

- ① 국토교통부장관은 과징금납부의무자가 납부기한 내에 과징금을 납부하지 아니한 경우에는 납부기한의 다음 날부터 납부한 날의 전일까지의 기간에 대하여 대통령령이 정하는 가산금을 징수할 수 있다.
- ② 그 지정한 기간 내에 과징금이나 가산금을 납부하지 아니하였을 때에는 국세 체납처분의 예에 따라 징수할 수 있다.

(4) 권리구제

a. 이의신청 (제42조)

- ① 과징금 부과에 이의가 있는 자는 통보받은 날부터 30일 이내에 사유서를 갖추어 국토교통부장관에게 이의를 신청할 수 있다.
- ② 국토교통부장관은 이의신청에 대하여 30일 이내 결정을 하여야 한다.

b. 행정심판 (제42조 제3항)

이의신청에 따른 결정에 이의가 있는 자는 행정심판을 청구할 수 있다.

c. 행정소송 및 부당이득반환청구소송

과징금은 처분이므로 행정소송을 제기가능

과징금 부과처분이 무효인데 이미 납부한 경우 민사상 부당이득반환청구소송을 제기가능

02 과태료

1) 과태료 의의 (제52조)

행정법에서 일정한 의무를 이행하지 않거나 가벼운 벌칙을 위반한 사람에게 부담해서 국가에 납부하게 하는 돈(처분X)

2) 불복절차

3) 과태료, 과징금, 벌금 비교

구 분	과태료	과징금	벌금
개념	경미한 위반행위에 대한 금전적 제재	불법이익 환수 또는 영업정지 대체의 금전적 제재	범죄인에 대한 금전지불의무 부과 형벌
종류	행정질서벌(형벌X)	금부하명(처분)	행정형벌
부과주체	행정청	행정청	법원
불복절차	이의신청/비송사건절차법	행정소송	형사소송

03 한국감정평가사협회 (안중요)

제1절 정비사업의 기초

01 정비사업의 의의 및 종류

02 정비사업의 절차



01 추진위원회

1) 추진위원회의 구성과 승인

토지등소유자 과반수의 동의를 받아 조합설립을 위한 추진위원회를 구성하여 시장·군수 등의 승인을 받아야 한다.

2) 추진위원회 구성승인의 법적성질

판례는 추진위원회 구성승인처분은 조합의 설립을 위한 주체인 추진위원회의 구성행위를 보충하여 그 효력을 부여하는 처분이라고 판시하여 강학상 인가로 본다.(2011두11129)

3) 조합설립인가 후 추진위원회 구성승인처분을 다룰 수 있는지

판례는 추진위원회 구성승인처분을 다투는 소송 계속 중에 조합설립인가처분이 이루어진 경우에는, 직접 조합설립인가 처분을 다투어야 하고, 이와는 별도로 추진위원회 구성승인처분에 대하여 다룰 법률상의 이익은 없다고 보았다.

02 조합설립

1) 설립절차

토지등소유자로부터 조합설립 동의(결의)를 받고 시장등에게 조합설립인가(강학상 특허)를 받은 후 등기함으로써 법인으로 성립한다.

2) 조합의 법적지위

관할 행정청의 감독 아래 정비사업을 시행하는 목적 범위 내에서 행정작용을 행하는 행정주체로서의 지위를 갖는다.

03 조합설립인가의 법적성질

1) 학설

- ① 조합설립행위는 기본행위로, 조합설립인가는 이를 보충하는 행위로서 강학상 인가로 보는 견해
- ② 조합설립행위는 조합설립인가를 받기 위한 요건으로 보고, 조합설립인가는 정비사업을 시행할 수 있는 권한을 갖는 행정주체로서의 지위를 부여하는 강학상 특허로 보는 견해가 있다.

2) 판례

(1) 종전 판례 (강학상 인가)

종전에는 조합설립인가는 조합설립행위를 보충하여 그 법률상 효력을 완성시키는 보충행위라고 하여 인가설을 취했다.

(2) 최근 판례 (설권적 처분)

최근에는 입장을 바꾸어 조합설립인가처분을 도시정비법상 재건축사업을 시행할 수 있는 권한을 갖는 행정주체로서의 지위를 부여하는 설권적 처분으로 보고, 조합설립행위는 인가처분을 위한 요건 중에 하나라고 판시했다.

3) 검토

도시정비법상 조합설립인가처분은 조합이 정비사업을 시행할 수 있는 권한을 부여하여 행정주체로서의 지위를 설정하는 능력설정행위이므로 강학상 특허로 보는 것이 타당하다.

04 조합설립행위(결의)에 대한 소송

CASE

S시의 시장 A는 K구의 D지역을 도시정비법상 정비구역으로 지정·고시하였다. 그러자 이 지역의 주민들은 조합을 설립하여 주택재개발사업을 추진하기 위해 도정법에서 정한 절차에 따라 조합설립추진위원회를 구성하였고, 동 추진 위원회는 토지등소유자의 동의, 정관, 공사비 등 정비사업에 드는 비용과 관련된 자료 등을 첨부하여 A로부터 X조합 설립인가를 받아登記하였다. X조합은 조합총회를 개최하고 도정법상 토지등 소유자 동의를 얻어 지정개발자로서 Y를 사업시행자로 지정하였다.

D지역의 토지소유자 중 甲이 “추진위원회가 주민의 동의를 얻어 X조합을 설립하는 과정에서 ‘건설되는 건축물의 설계의 개요’ 등에 관한 항목 내용의 기재가 누락되었음에도 이를 유효한 동의로 처리하여 조합설립행위에 하자가 있다.”고 주장하며 행정소송으로 다투려고 한다. 이 경우 조합설립인가의 법적 성질을 검토한 다음, 이에 기초하여 쟁송의 형태에 대해 설명하시오. [25회 문1]

구 분	조합설립행위 법적성질	조합설립인가 법적성질	소송수단 (조합설립행위의 하자)
변경 전	기본행위	강학상 인가	민사소송으로 기본행위의 무효확인의 소 제기
변경 후	인가처분에 필요한 요건	강학상 특허	항고소송으로 조합설립인가의 취소 또는 무효확인의 소 제기

05 조합설립인가처분 취소판결 등으로 인한 법률관계

01 개설**02** 법적성질

1) 사업시행계획

사업시행계획은 인가·고시를 통해 확정되면 이해관계인을 구속하는 행정계획으로서 독립된 행정처분에 해당한다.

2) 사업시행계획인가

조합이 수립한 사업시행계획을 인가하는 행정청의 행위는 사업시행계획을 동의로써 보충하여 법률상 효력을 완성시키는 강학상 인가에 해당한다.

03 소송 유형

1) 사업시행계획인가를 다투는 경우

사업시행계획 (기본행위)	사업시행계획인가 (보충행위)	소송내용
하자X	하자O	인가처분을 대상으로 하는 항고소송
하자O	하자X	기본행위를 대상으로 하는 항고소송

2) 조합총회결의에 대한 소송제기 가능여부

다툼의 대상	다투는 시점	소송내용
조합총회결의의 하자	사업시행계획인가 전	조합총회결의의 무효확인을 구하는 당사자소송
	사업시행계획인가 후	사업시행계획(기본행위)을 대상으로 하는 항고소송

01 관리처분계획의 의미

포괄적 행정계획으로서 사업시행의 결과 설치되는 대지를 포함한 각종 시설물의 권리귀속에 관한 사항과 그 비용 부담에 관한 사항을 정하는 행정처분이다.

02 절차

- 1) 분양공고
- 2) 분양신청
- 3) 관리처분계획수립 및 인가

분양신청의 현황을 기초로 관리처분계획을 수립하여 총회의결을 거친 후 시장·군수등의 인가를 받아야 한다.

03 법적성질

1) 관리처분계획 (행정계획)

관리처분계획은 인가·고시를 통해 확정되면 이해관계인에 대한 구속적 행정계획으로서 독립적인 행정처분에 해당한다.

2) 관리처분계획인가 (강학상 인가)

사업시행자가 수립한 관리처분계획을 인가하는 행정청의 행위는 관리처분계획을 동의로써 보충하여 법률상 효력을 완성시키는 강학상 인가에 해당한다.

04 소송 유형

1) 관리처분계획인가를 다투는 경우

관리처분계획 (기본행위)	관리처분계획인가 (보충행위)	소송내용
하자X	하자O	인가처분을 대상으로 하는 항고소송
하자O	하자X	기본행위를 대상으로 하는 항고소송

2) 조합총회결의에 대한 소송제기 가능여부

다툼의 대상	다툼의 시점	소송내용
조합총회결의의 하자	관리처분계획인가 전	조합총회결의의 무효확인을 구하는 당사자소송
	관리처분계획인가 후	관리처분계획(기본행위)을 대상으로 하는 항고소송

05 하자의 승계 여부

1) 사업시행계획과 관리처분계획 간의 하자의 승계 여부

서로 독립하여 별개의 법률효과를 발생시키는 것 → 불가

2) 관리처분계획과 청산금부과처분 간의 하자의 승계 여부

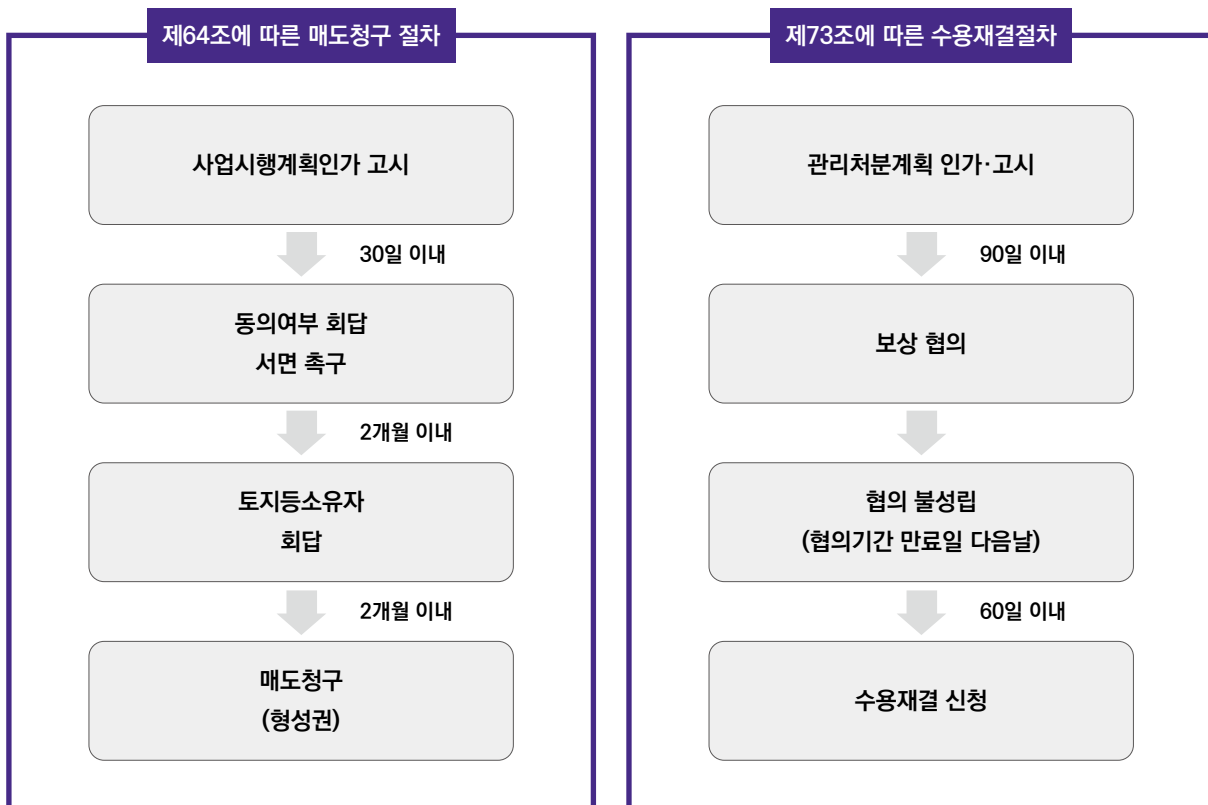
서로 독립하여 별개의 법률효과를 발생시키는 것 → 불가

01 재건축사업의 매도청구 (도시정비법 제64조, 제73조)

- ① 재건축사업의 사업시행자는 도시정비법에서 정한 절차를 거쳐 조합설립 또는 사업시행자 지정에 동의하지 않은자 (제64조), 분양신청을 하지 않은 자 등(제73조)을 상대로 건축물 또는 토지의 소유권과 그 밖의 권리를 매도할 것을 청구할 수 있다.
- ② 형성권의 성질

02 재개발사업의 수용재결 (도시정비법 제73조)

재개발사업의 사업시행자는 도시정비법에서 정한 절차를 거쳐 분양신청을 하지 않은 자 등을 상대로 토지, 건축물 또는 그 밖의 권리에 대해 수용재결을 신청할 수 있다.



03 매도청구소송과 보상금증감청구소송의 차이점

1) 소송형태 및 관할법원

- ① 매도청구소송 : 민사소송
- ② 보상금증감청구소송 : 형식적 당사자소송

2) 절차 및 제소기간

(1) 매도청구

(2) 보상금증감청구소송

3) 당사자

- ① 매도청구소송 : 원고는 사업시행자, 피고는 부동의자, 분양신청을 하지 않은 자 등이 된다.
- ② 보상금증액청구소송 : 원고는 피수용자, 피고는 사업시행자(감액소송은 반대)

4) 감정평가의 기준시점 (가격시점)

- ① 매도청구소송 : 매매계약체결 의제일
- ② 보상금증감청구소송 : 수용재결일

5) 감정평가 시 개발이익 반영 여부

- ① 매도청구 : 현실화·구체화된 개발이익은 반영, 그러나 미실현 개발이익이나 조합원의 비용부담을 전제로 한 개발이익은 배제
- ② 보상금증감청구소송 : 개발이익 배제

6) 사실상 사도의 평가기준

- ① 매도청구 : 재건축사업이 시행될 것을 전제로 할 경우의 인근 대지 시가와 동일하게 평가하되 형상 등을 개별요인에서 반영
- ② 보상금증감청구소송 : 인근토지에 대한 평가액의 1/3 이내로 평가

CASE

X는 도시정비법에 따른 재개발정비사업조합이고, 甲은 X의 조합원으로서, 해당 정비사업구역 내에 있는 A토지와 B토지의 소유자이다.

X는 도시정비법 제72조 제1항에 따라 분양신청기간을 공고하였으나 甲은 그 기간내에 분양신청을 하지 않았다.

이에 따라 X는 甲을 분양대상자에서 제외하고 관리처분계획을 수립하여 인가를 받았고, 그에 불복하는 행정심판이나 행정소송은 없었다. X는 도시정비법 제73조 제1항에 따른 甲과의 보상협정이 이루어지지 않자 A토지와 B토지에 관하여 관할 토지수용위원회에 수용재결을 신청하였고, 관할 토지수용위원회는 A토지와 B토지를 수용한다는 내용의 수용재결을 하였다.

甲이 수용재결에 대한 취소소송을 제기하면서, 'X가 도시정비법 제72조 제1항에 따라 분양신청기간과 그 기간 내에 분양신청을 할 수 있다는 취지를 명백히 표시하여 통지하여야 하는데도 이러한 절차를 제대로 거치지 않았다'고 주장할 경우에, 甲의 주장이 사실이라면 법원은 그것을 이유로 수용재결을 취소할 수 있는지 설명하시오. (단, 사실심 변론 종결 전에 도시정비법에 따른 이전고시가 효력을 발생한 경우와 그렇지 않은 경우를 구분하여 설명할 것) [33회 문1]

01 분양신청기간의 통지 등 절차를 이행하지 않은 채 한 수용재결의 위법성 여부

통지 등의 절차를 제대로 거치지 않고 이루어진 수용재결은 위법하다.

02 이전고시의 법적 성질

관리처분계획에서 정한 바에 따라 분양받을 자에게 소유권을 이전하는 공법상 처분이다.

03 이전고시의 효력발생 후 관리처분계획 등을 다룰 수 있는지 여부

1) 관련 판례

이전고시의 효력 발생으로 대다수 조합원 등에 대하여 권리귀속 관계가 획일적·일률적으로 처리되므로, 이전고시의 효력이 발생한 이후에는 조합원 등이 해당 정비사업을 위하여 이루어진 수용재결이나 이의재결의 취소 또는 무효확인을 구할 법률상 이익이 없다고 해석함이 타당하다.

2) 검토

(1) 이전고시 효력이 발생하기 전

관리처분계획의 하자로 인하여 자신의 권리를 침해당한 조합원 등으로서는 그 관리처분계획이나 수용재결에 대해서 다룰 수 있다.

(2) 이전고시 효력이 발생한 후

① 이전고시 효력 발생 후 관리처분계획이 변경되거나 무효로 확인되는 경우, 다수의 이해관계인들에게는 예측하지 못한 피해가 초래하게 된다.

② 따라서 이전고시의 효력이 발생한 후에는 관리처분계획, 해당 정비사업과 관련된 수용재결이나 이의재결에 대해 다룰 수 없다.